



Formation

Master 1 AP

DROIT ET SCIENCE ADMINISTRATIVE



Cours



Grégory Houillon

Maître de conférences, Ipag de Poitiers

Laurent Bouchard

Maître de conférences en Droit public Directeur des études IPAG-CIMP de Poitiers

Les cours du Cned sont strictement réservés à l'usage privé de leurs destinataires et ne sont pas destinés à une utilisation collective. Les personnes qui s'en serviraient pour d'autres usages, qui en feraient une reproduction intégrale ou partielle, une traduction sans le consentement du Cned, s'exposeraient à des poursuites judiciaires et aux sanctions pénales prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Les reproductions par reprographie de livres et de périodiques protégés contenues dans cet ouvrage sont effectuées par le Cned avec l'autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

Cned, BP 60200, 86980 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France

Le Cned remercie les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce document. Qu'elles trouvent ici l'expression de toute sa reconnaissance.



SOMMAIRE

INTRODUCTION

BIBLIOGRAPHIE POUR LA PARTIE SCIENCE ADMINISTRATIVE

PARTIE 1 SCIENCE ADMINISTRATIVE : LES ORIGINES DE L'ADMINISTRATION ET LES ÉVOLUTIONS DE L'ACTION ADMINISTRATIVE

TITRE 1. La sphère administrative	page 7
CHAPITRE 1 L'émergence de l'administration publique	page 8
SECTION 1. L'apparition d'un cadre étatique	page 8
Notions clefs	page 12
À retenir	page 12
SECTION 2. L'évolution libérale de l'État	page 13
Notions clefs	page 17
À retenir	page 17
CHAPITRE 2 L'autonomisation de l'administration publique	page 18
SECTION 1. Le particularisme statutaire de l'administration	page 18
Notions clefs	page 22
À retenir	page 22
SECTION 2. La spécificité de l'appareil administratif	page 23
Notions clefs	page 27
À retenir	page 27
TITRE 2. L'action administrative	page 28
CHAPITRE 1 La rationalisation des processus de décision	page 29
SECTION 1. L'exigence de cohérence	page 29
Notions clefs	page 33
À retenir	page 33
SECTION 2. Le contrôle comme garantie d'efficacité	page 34
Notions clefs	page 37
À retenir	page 37

CHAPITRE 2 La réforme du management public au service de l'efficacité de l'action administrative	page 38
SECTION 1. La volonté de décloisonnement	page 38
Notions clefs	page 42
À retenir	page 42
SECTION 2. Le maintien de caractéristiques traditionnelles	page 43
Notions clefs	page 47
À retenir	page 47

PARTIE 2 DROIT ADMINISTRATIF : LES MOYENS ET LES CONSÉQUENCES L'ACTION ADMINISTRATIVE

TITRE 1. Les moyens de l'action administrative	page 48
---	---------

SOUS-TITRE 1. L'acte administratif unilatéral	page 48
--	---------

CHAPITRE 1 La notion d'acte administratif unilatéral	page 48
SECTION 1. La définition de l'acte administratif unilatéral	page 48
SOUS-SECTION 1. Les actes émanant d'une personne publique	page 48
L'acte de gouvernement	page 50
SOUS-SECTION 2. Les actes émanant d'une personne privée	page 51
SECTION 2. La classification des actes administratifs unilatéraux	page 51
À retenir	page 56

CHAPITRE 2 Le régime juridique de l'acte administratif unilatéral	page 57
SECTION 1. L'élaboration de l'acte administratif unilatéral	page 57
La Délégation	page 59
SECTION 2. L'exécution de l'acte administratif unilatéral	page 62
SECTION 3. La disparition de l'acte administratif unilatéral	page 67
Abrogation d'un acte administratif unilatéral	page 70
Retrait	page 72
À retenir	page 72

SOUS-TITRE 2. Le contrat administratif	page 73
---	---------

CHAPITRE 1 La notion de contrat administratif	page 73
SECTION 1. Les critères d'identification du contrat administratif	page 73
Les critères jurisprudentiels du contrat administratif	page 77
SECTION 2. Les différentes catégories de contrat administratif	page 77
À retenir	page 78

CHAPITRE 2 Le régime juridique des contrats administratifs	page 79
SECTION 1. Les règles régissant les contrats administratifs	page 79
Le droit à indemnisation du cocontractant	page 85
SECTION 2. Le contentieux des contrats administratifs	page 86
À retenir	page 90

TITRE 2. Les conséquences de l'action administrative :le principe de responsabilité	page 91
SOUS-TITRE 1. L'étendue de la responsabilité de l'administration	page 91
CHAPITRE 1 La responsabilité pour faute	page 91
SECTION 1. Les différents types de faute	page 91
SECTION 2. Les hypothèses de cumul	page 95
À retenir	page 96
CHAPITRE 2 La responsabilité sans faute	page 97
SECTION 1. La responsabilité pour risque	page 97
SECTION 2. La responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques.	page 101
À retenir	page 104
SOUS-TITRE 2. Les effets de la responsabilité de l'administration	page 105
CHAPITRE 1 Les conditions de la réparation	page 105
SECTION 1. Les caractères du préjudice.	page 105
SECTION 2. L'imputabilité du préjudice.	page 106
Les causes d'exonération	page 108
À retenir	page 108
CHAPITRE 2 Les modalités de la réparation	page 109
SECTION 1. L'évaluation du préjudice	page 109
SECTION 2. La nature de la réparation	page 109
À retenir	page 109



L'administration est traditionnellement définie comme l'ensemble des moyens mis à disposition d'un gouvernement, visant à assurer l'application et le respect des normes élaborées par la puissance souveraine (ou ses représentants).

Cette vision très classique renvoie essentiellement à deux caractéristiques :

- ≡ **D'une part à la nature juridique de l'administration qui découle de celle de l'État. Ce dernier a été perçu depuis ses origines comme l'incarnation juridique de groupements humains appelés des nations. Il a alors vocation à pallier l'instabilité de l'état de nature. Instrument de coercition, il se doit d'assurer la régulation des rapports sociaux. Le droit va ainsi canaliser l'exercice de la force sous l'égide de l'intérêt commun et donc régenter l'ensemble des processus administratifs.**
- ≡ **D'autre part, à l'importance du lien hiérarchique qui la relie aux gouvernants. L'administration est ainsi perçue comme un instrument (on parle d'ailleurs d'une autorité administrative et pas d'un pouvoir administratif) dont le fonctionnement doit être contrôlé intégralement par le pouvoir politique.**

Cette double caractéristique a amené historiquement à un cloisonnement de l'étude du fonctionnement administration. Objet de droit, l'administration a longtemps été envisagée comme un champ d'étude spécifique aux juristes publicistes. Nombreuses sont ainsi les matières juridiques qui abordent ses problématiques (Histoire de l'administration publique, Institutions administratives, droit administratif (général/spécial), droit administratif des biens...).

Or, depuis la seconde moitié du XX^e siècle, de nouvelles perspectives de recherche se sont ouvertes. Ainsi des chercheurs non issus de la sphère juridique ont-ils commencé à s'intéresser aux modalités de fonctionnement de l'administration. Ces travaux issus de l'ensemble du spectre des sciences sociales ont contribué à élargir la compréhension des mécanismes d'organisation des pouvoirs publics.

C'est dans ce mouvement général d'ouverture qu'est apparue la « science administrative ». Dans une approche symétrique à celle de la « science politique », cette matière vise justement à élargir les perceptions traditionnelles en intégrant, non seulement l'ensemble des matières juridiques concernant l'administration, mais aussi de multiples éléments issus des autres sciences sociales. Elle vise ainsi à dresser un tableau le plus général possible du fonctionnement de l'administration. Carrefour de multiples domaines d'investigation, la « science administrative » a donc vocation à offrir un point de vue le plus transversal possible afin d'offrir la mise en perspective la plus globale. Évidemment, une telle démarche a fait l'objet de critiques. On lui reproche sa dispersion, un caractère trop abstrait ou trop général, une tendance à la superficialité ou encore son manque de technicité.

Si certains éléments peuvent (comme pour tout domaine de recherche) évidemment être considérés, il n'en demeure pas moins que cette matière est devenue incontournable pour toute personne souhaitant approfondir ses connaissances en matière de fonctionnement de la chose publique.

Sortant de sentiers tracés, cette matière aura ainsi vocation à apporter un regard différent, susceptible de créer ou de souligner, aux yeux du candidat à un master administration et management publics, les points de connexion entre les différentes matières qui lui sont enseignées, mais aussi de mieux mettre en perspective les théories administratives avec les problématiques du concret.

À ce titre, la description des mécanismes internes à l'administration sera appréhendée en commençant par le cadre institutionnel administratif (I) avant d'essayer de percevoir les caractéristiques de son action (II).

BIBLIOGRAPHIE

POUR LA PARTIE SCIENCE ADMINISTRATIVE



- ≡ B. Abate. La Nouvelle gestion publique, Paris, LGDJ, 2000
- ≡ E. Aubin. L'essentiel du droit de la fonction publique, Issy-les-Moulineaux, Lextenso éditions, Gualino, 13^e édition, 2019 [À jour de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique]
- ≡ F. Burdeau. Histoire de l'administration française du 18^e au XX^e siècle, 2^e édition, Paris, Montchrestien, 1994
- ≡ J. Chevallier. Science administrative, Paris, PUF, Thémis, 6^e édition, 2019
- ≡ Y. Gaudemet. Droit administratif, Paris, LGDJ, 20^e édition, 2012
- ≡ B. Gournay. Introduction à la science administrative, Paris, A. Collin, 1966
- ≡ E. Gristi. La réforme de l'État, Paris, Librairie Vuibert, 2007
- ≡ G. Guglielmi. Histoire et Service public, Paris, PUF, 2004
- ≡ L. Rouban. La fonction publique, La Découverte, 3^e édition, 2009

PARTIE 1 SCIENCE ADMINISTRATIVE : LES ORIGINES DE L'ADMINISTRATION ET LES ÉVOLUTIONS DE L'ACTION ADMINISTRATIVE

TITRE 1. La sphère administrative

L'administration peut être définie par son cadre juridique et l'organisation structurelle qui en découle. Dans cette optique, elle est avant tout un cadre institutionnel de l'action publique, légitimé et organisé par le pouvoir politique. Celui-ci lui délègue ses prérogatives de puissance publique (liée à l'exercice de la souveraineté) en lui confiant la gestion pratique des territoires placés sous son autorité. La conjonction de cette double boucle institutionnelle, politique et administrative, sur un territoire et une population donnés, permet d'évoquer l'existence d'un État.

Ce schéma de l'État-Nation, devenu la référence en Europe depuis le XVI^e siècle, puis dans le reste du monde, a été le fruit d'une construction progressive incarnée par un processus historique de longue durée. Il a ainsi fallu près de mille ans pour qu'après la fin de l'Empire romain, les territoires européens fassent d'abord émerger des structures susceptibles d'assumer leurs différents pouvoirs publics (Chapitre I) avant que leur perfectionnement permette véritablement d'évoquer une administration au sens moderne (Chapitre II).

CHAPITRE 1 L'émergence de l'administration publique



Objectif

- Connaître et comprendre la genèse de l'État.

Avant même de pouvoir aborder la question administrative en tant que telle, il est indispensable de comprendre comment le pouvoir s'est institutionnalisé pour permettre l'émergence d'un cadre public (Section 1). Sous la pression de la réflexion politique libérale, ce dernier va progressivement devoir s'autoréguler, et donc fixer un cadre administratif contraignant, pour assurer une protection des droits naturels individuels (Section 2).

SECTION 1. L'apparition d'un cadre étatique

L'État, au sens juridique, peut être défini comme « une personne morale titulaire de la souveraineté ». Ainsi, de ce point de vue, c'est avant tout la souveraineté (« puissance absolue et perpétuelle » d'un État selon la célèbre définition de Jean Bodin dans ses célèbres *Six livres de la République* (1576)), qui caractérise l'existence d'une organisation étatique sur un territoire et une population. Dans cette logique, le processus historique qui a contribué à façonner les États-nation contemporains trouve ses origines dans l'Europe médiévale, lorsque la souveraineté royale succéda à la suzeraineté féodale, elle-même issue du démembrement de l'Empire carolingien (1). À partir de là, le pouvoir monarchique (et avec lui celui de l'État) ne va cesser de croître pour aboutir à un modèle extrêmement concentré et, dès lors, sans possibilité de contrôle. Ce fut alors l'âge d'or de la monarchie absolue (2).

1. La restauration de la souveraineté

La mise en place d'une administration moderne nécessitait au préalable l'émergence d'une structure politique étatisée. Celle-ci fut le fruit d'une évolution historique qui prit comme point de départ l'écroulement de l'Empire romain (1A), avant de renaître sous une forme nationale à la faveur de la restauration d'une souveraineté royale dans la seconde moitié du Moyen-Âge (1B).

1A. L'effondrement du monde romain

L'origine de l'organisation du continent européen contemporaine prend ses racines dans l'effondrement de l'Empire romain à la fin du V^e siècle. Pendant plus d'un demi-millénaire, l'administration républicaine puis impériale romaine avait fixé l'organisation publique sur un territoire qui atteint à son apogée plus de 5 000 000 km².

Ce processus de colonisation du monde européen et méditerranéen se fit à la faveur d'une organisation fondée sur la notion de *res publica* (chose publique). Si la forme républicaine fut abandonnée au tournant de notre ère, l'héritage de la pensée juridique qui s'y était épanouie survécut par-delà l'évolution impériale. Après la scission de ce dernier au IV^e siècle, et l'effondrement de l'Empire d'Occident en 476, cet ensemble de concepts et de réflexions juridiques se perpétua grâce au maintien de l'Empire romain d'Orient (en particulier à la faveur du code justinien).

En Europe occidentale, la disparition de l'ordre romain ouvrit une période d'incertitudes politiques dont la conséquence fut un net recul de toute forme d'organisation publique. La multiplicité des monarchies germaniques qui s'installèrent sur les ruines d'une organisation décapitée ruinait l' ancestrale perception d'une harmonie unitaire européenne. Désormais, seule l'Église catholique pouvait incarner cette unité pluriséculaire en tant qu'héritière du modèle romain. Elle avait ainsi calqué son organisation sur ce modèle aux III^e et IV^e siècles (voir édit de Milan puis de Thessalonique qui aboutirent à faire du culte catholique la religion officielle). Sa disposition en provinces avait repris le modèle impérial (voir par exemple les diocèses ou encore les métropoles). De forme de plus en plus pyramidale, l'Église catholique constitua ainsi un continuateur, et donc un témoignage, d'un monde politique désormais disparu.

Implantée sur l'ensemble du territoire continental, elle avait dès lors vocation à devenir l'interlocuteur principal de monarchies germaniques peu préparées à assurer la gestion des immenses territoires qui venaient d'être conquis.

Aussi romanisés qu'ils aient pu l'être (surtout leurs élites), ces peuples venus du nord et de l'est du continent avaient une perception bien différente de l'organisation politique communément qualifiée de patrimonialité du pouvoir. Dans ce cadre, on ne retrouvait absolument pas l'élément fondamental autour duquel tournait l'ensemble du droit public romain, à savoir la notion de *Res publica*.

En effet, celle-ci permettait de justifier l'existence d'un ordre juridique supérieur à tous les individus, y compris ceux qui exerçaient des prérogatives de puissance publique, et régi par un droit spécifique (droit public). L'Empereur romain était ainsi « seulement » le premier des romains (princeps) au service du bien public (tout du moins en théorie). À l'inverse, le roi franc, conformément aux traditions germaniques, se considérait propriétaire de son royaume (pas de distinction droit public / droit privé). Il possédait vis-à-vis de ce dernier exactement les mêmes prérogatives que n'importe quel propriétaire privé sur son patrimoine (en particulier, il était totalement libre d'en disposer à sa guise et pouvait ainsi aliéner des terres sans procédure particulière ou diviser son territoire entre ses différents héritiers selon son bon vouloir).

1B. La restauration progressive d'une souveraineté royale

Avec les monarchies franques (V^e-X^e siècles), on assiste à une sorte de « privatisation » de la chose publique. L'idée même d'une distinction entre biens publics et biens privés, entre droit public et droit privé a disparu. Il n'y a plus de trésor public, plus d'agents publics, plus de procédures normatives, autrement dit plus d'État, mais uniquement des coffres où le prince va puiser indifféremment pour ses besoins personnels et pour ceux de son royaume, des hommes liés au chef par un contrat *intuitu personae* de nature privée et le bon vouloir royal régissant son royaume comme un propriétaire gérerait son patrimoine personnel.

Cette confusion est particulièrement visible au sein du pouvoir franc à travers les modalités de transmission du pouvoir qui étaient définies par la célèbre loi salique. Avec elle, la succession royale était réglée comme une succession ordinaire. C'est ainsi que, conformément à cette loi, à la mort du roi, l'ensemble de ses biens (dont son titre et l'ensemble des droits qui y étaient afférés) devaient être partagés à parts égales entre ses fils (la loi salique excluant les filles en présence d'héritiers mâles). Les Mérovingiens pratiquèrent donc le partage du royaume. Ainsi, à la mort de Clovis en 511, le *regnum francorum* fut divisé entre ses quatre fils. Chacun reçut respectivement le titre de roi des Francs et se vit attribué une part égale du royaume de leur père. Ce partage obéissait à une logique géographique qui épousait un processus de territorialisation du pouvoir. Malgré cette partition survenue à la mort de Clovis (et facilitée par ses conquêtes), l'idée d'une communauté franque se perpétua. Le royaume était alors considéré comme appartenant collectivement à la famille mérovingienne. Celui-ci était donc tout à la fin « un (le royaume franc) et multiple (les sous-royaumes comme l'Austrasie, la Neustrie ou la Burgondie... qu'on va dénommer à partir de 561 des « regna », dont le nombre et les limites vont se modifier au gré des évolutions dynastiques) ». Ce royaume franc ne sera dès lors plus rassemblé en pratique que sous l'autorité de Clotaire Ier entre 558 et 561.

Ces partages sont des phases délicates de l'exercice du pouvoir car ils donnent souvent lieu à d'importantes difficultés. Un (ou des) héritier(s) s'avère(nt) souvent mécontents de la répartition effectuée. C'est ainsi qu'une telle pratique engendrait fréquemment de graves conflits internes qui débouchaient sur une violence interne à la famille mérovingienne comme plus tard à la carolingienne (multiplication des assassinats). *Ces faiblesses structurelles du pouvoir franc contribuaient ainsi à affaiblir ces dynasties et à renforcer l'autonomie de leurs agents locaux.* Ce phénomène aboutit à la dislocation progressive du pouvoir central dont l'une des étapes fondamentales fut l'émergence d'une nouvelle entité territoriale, la « *Francie occidentalis* » avec le traité de Verdun de 843.

Après un siècle d'incertitudes dynastiques, l'arrivée des Capétiens à la fin du X^e ne modifiera en rien ce processus qui se caractérise par une disparition de l'administration centrale au profit d'agents locaux de plus en plus autonomes (« les comtes carolingiens ») aboutissant à un émiettement de l'autorité. Se met ainsi en place, aux alentours de l'an 1000, la féodalité. D'un point de vue organisationnel, celle-ci consiste dans une pyramide politico-juridique fondée sur un engagement personnel (lien vassalique) motivé par l'attribution d'une terre (le fief).

L'autorité royale devient alors de plus en plus théorique et indirecte en dehors du domaine (terres sur lesquelles le roi est seigneur direct) tant l'absence de structures administratives et de moyens humains rendent ce pouvoir éloigné. À ce titre, l'organisation administrative royale se limite logiquement à ce seul domaine royal. Sur tout le reste du royaume, on voit se développer des structures alternatives (seigneuriales ou urbaines). À ce titre, la lente conquête par les Capétiens de la souveraineté, qui s'achèvera avec le Moyen-Âge, sera justement marquée

par une forte expansion de leur administration qui va progressivement concurrencer les structures locales, avant de les dominer (XII^e–XV^e siècles). Les agents publics se multiplient alors dans tout le royaume pour accompagner l'extension de la puissance royale. La gestion de ce vaste territoire qui avait été soustrait à toute emprise du pouvoir central français depuis des siècles se présentait donc comme un immense défi administratif.

2. La monarchie absolue, une monarchie administrative ?

Les bases du modèle administratif français se sont mises en place au moment où les prétentions politiques des Capétiens se sont réalisées. S'inspirant du droit public romain redécouvert, le roi devait être « empereur en son royaume ». Pour cela, il avait fallu exporter les quelques structures administratives au-delà du domaine pour les substituer aux organisations alors en place (2A). Dans un second temps, leur perfectionnement fut l'instrument d'une volonté d'expansion de l'autorité centrale (2B).

2A. La mise en place d'une administration étatique

Si l'accession au trône d'Hugues Capet en 987 fut l'élément déclencheur d'une accapuration du pouvoir politique français par une dynastie pendant plus de 800 ans, elle n'en fut pas pour autant le point d'origine de l'administration française moderne. Les premières réalisations d'envergure n'arrivèrent que 150 ans plus tard avec les règnes de Philippe II (1180-1223) et de Louis IX (1226 à 1270). Celles-ci témoignaient d'une volonté de contrôle accru du territoire en répandant les agents royaux (baillis, sénéchaux...) et en affirmant leur domination sur les structures préexistantes (administrations seigneuriales, urbaines ou ecclésiastiques). Cette domination se fit avant toutes choses par *le prisme de la justice, alors compétence fondamentale de l'exercice du pouvoir* (à l'image de la légende de Saint Louis rendant la justice sous un chêne). Ainsi, l'administration royale est prioritairement, voire exclusivement, une administration judiciaire délégataire de l'autorité royale et le pouvoir royal une puissance hiérarchique de régulation des rapports sociaux.

Si la modernisation de l'appareil étatique imposait l'extension des frontières périphériques du système administratif royal, l'administration centrale connut de son côté une phase de spécialisation lui permettant justement de mieux contrôler la complexification des affaires publiques. Alors que depuis la fin de l'ère carolingienne, l'entourage royal s'était caractérisé par son indétermination au sein de la « *curia regis* » (la cour du roi, au sein de laquelle on retrouvait l'entourage familial, les relations vassaliques et des juristes), avec le XII^e siècle on commence à voir émerger des structures spécialisées permettant d'accompagner la croissance de l'administration pour assurer sa cohérence et donc son efficacité. C'est ainsi que vont progressivement apparaître, et se perfectionner, le Conseil royal, le Parlement ou encore les États généraux.

Le premier est une instance de gouvernement, où s'expriment la puissance politique du roi mais aussi son contrôle hiérarchique de toutes les structures publiques, justifié par l'affirmation d'une délégation de pouvoir (les administrateurs, quelles que soient leurs fonctions, prennent des décisions au nom du roi). On y retrouve la prééminence de liens personnels (hors les Princes du sang, seuls peuvent siéger des membres convoqués par brevet royal), témoignant de la force de l'héritage féodal mais aussi une spécialisation progressive par thématique d'actions publiques (affaires de justice, de politique intérieure ou extérieure, de correspondances administratives).

Le second, à savoir l'institution parlementaire, est une Cour de Justice souveraine, œuvrant également sur délégation royale qui avait pour mission d'assurer la cohérence jurisprudentielle des tribunaux et l'enregistrement des principaux actes royaux (les lettres patentes). Son extension à de nombreuses villes du royaume (Rennes, Bordeaux, Aix-en-Provence, Grenoble...) incarnait la domination toujours plus forte de son territoire par la monarchie capétienne.

Les États généraux, fondés à l'occasion du conflit entre Philippe IV et le pape Boniface VIII au début du XIII^e siècle devaient, quant à eux, incarner une représentation des sujets auprès du roi lorsque celui-ci avait des besoins (financiers ou de soutien politique) exceptionnels (les réunions n'intervenant que sur convocation royale).

Si ce système permit l'implantation d'une autorité royale plus étendue, ses limites interdisaient à terme son maintien en l'état. Les questions de fiscalité, de compétence et de statut des agents publics allaient constituer les défis à relever pour le pouvoir royal à l'aube de son entrée dans l'ère moderne (XVI^e–XVIII^e siècles).

2B. L'émergence d'une administration moderne

L'administration centralisée et hiérarchisée qui constitue le modèle français traditionnel s'implante en même temps que la conception absolutiste du pouvoir royal. Il la devance même. En effet, alors même que les théories absolutistes n'émergeront qu'avec les guerres de religion (1562-1598), comme moyens de sortir de la guerre

civile, l'expansion de l'administration royale se met en place au début du XVI^e siècle. Déjà initiée avec le règne de ses prédécesseurs, celle-ci sera particulièrement marquée sous le règne de François I^{er} (1515-1547). On voit en particulier les revenus de l'État croître sensiblement et durablement du fait de la fusion des recettes ordinaires et extraordinaires. En effet, l'appréhension des modalités de financement de la monarchie avait jusque-là interdit un tel développement. On considérait ainsi depuis le Moyen-Âge que le roi devait uniquement vivre des revenus de son domaine (revenus ordinaires) et ne pouvait solliciter une contribution des sujets de son royaume que dans des circonstances exceptionnelles (revenus extraordinaires), et avec leur consentement, à travers la convocation des États-généraux. *La pérennisation de l'impôt débuta ainsi à la faveur de la guerre de Cent-ans et se généralisa sous François I^{er}.* Cet afflux de crédits imposa une rationalisation de la gestion du trésor public (création de la fonction de surintendant des finances), annonciatrice de l'émergence d'une administration moderne.

À ce titre, la modernisation se fit d'abord par le centre de l'administration avant de s'étendre, plus difficilement, à sa périphérie. Dans la seconde moitié du XVI^e siècle, on vit ainsi le Conseil royal perfectionner et systématiser son fonctionnement. La fonction de « secrétaire d'État » (marine, affaires étrangères...), en charge d'un portefeuille ministériel, et d'une administration dévouée, fait concurrence à son apparition. On commence à parler de spécialisation des administrations.

À l'inverse, au niveau local, l'administration locale connaît une évolution beaucoup moins importante. Ces carences s'expliquent autant par les difficultés techniques (en particulier pour la circulation de l'information) que par la pesanteur d'une organisation dépassée. En effet, le système des offices qui avait constitué le mode normal d'exercice des charges publiques, soutenu par la monarchie pour des raisons financières, nuisait au bon fonctionnement administratif (les critiques contemporaines étaient déjà nombreuses contre un système jugé inefficace et inadapté aux exigences du temps). La patrimonialité des offices, impliquant notamment l'immovibilité de son titulaire et la vénalité de sa charge, contrevenait autant à la bonne mise en œuvre du pouvoir hiérarchique, si important dans un système centralisé, qu'à la qualité des agents.

Il fallut ainsi attendre le ministériat du cardinal de Richelieu (1624-1642) pour que le système des commissaires se répande au sein du personnel administratif comme une alternative. À la différence des officiers, les commissaires (dont les intendants furent les plus célèbres représentants), nommés par une lettre de commission, étaient en effet révocables selon les mêmes formes et désignés pour un mandat déterminé. Ils s'avérèrent rapidement beaucoup plus utiles et efficaces pour devenir le symbole de la qualité d'une administration qui faisait figure de modèle dans l'ensemble de l'Europe. Agents déconcentrés typiques, ils disposaient à la fois de larges prérogatives (en matière fiscale, de justice et d'ordre public) et d'un pouvoir décisionnel limité (ce modèle inspira Napoléon Bonaparte lors de la création de l'institution préfectorale). Leur statut fragile offrait ainsi une grande flexibilité à la hiérarchie administrative et imposait un zèle important à son titulaire. Cette approche offrait une gestion des ressources humaines beaucoup plus conforme à l'esprit centralisé de la monarchie absolue.

Voilà donc le décor administratif à la veille de la Révolution et des profonds bouleversements qu'elle charriera. Une administration centrale cohérente et efficace mais limitée par les contingences pratiques, comme en témoignent les incertitudes et les incohérences de l'administration territoriale, que l'on pouvait déjà qualifier de millefeuilles (dont la réforme constitue l'une des principales revendications des cahiers de doléances). Surtout, et l'exaspération populaire contre l'intendance en fut un symptôme évident, c'était la légitimité de cette administration qui fit bientôt défaut. Appuyée sur un pouvoir royal dont les fondements et l'organisation politique étaient de plus en plus contestés, l'autorité de l'administration apparaissait, par voie de conséquence, de plus en plus arbitraire.

Notions clefs

Notion	Définition
Patrimonialité du pouvoir	Conception du pouvoir caractéristique des monarchies franques qui vont s'installer sur notre territoire après l'effondrement de l'Empire romain. Elle se définit par une indifférenciation entre droit public et droit privé et donc par une assimilation du royaume à un bien personnel du roi.
Droit public	Ensemble des règles juridiques qui régissent le fonctionnement des personnes de droit public. Droit dérogatoire au droit commun, ce concept est apparu et a été développé sous la république romaine (VI ^e -I ^{er} siècles avant JC).
Cour du roi	Entourage royal présent dès les origines de la monarchie française. Ayant vocation à accompagner le monarque dans ses décisions, son fonctionnement va se spécialiser avec l'émergence d'une véritable administration monarchique (XII ^e -XIII ^e siècles).
Intendants	Symbole du perfectionnement administratif français, le système des intendants va largement se développer à partir du ministériat de Richelieu pour devenir le mode principal d'exercice de l'administration locale jusqu'à la Révolution. Il se caractérise en particulier par un renforcement de la dépendance hiérarchique de l'agent et permettra la mise en place d'une véritable déconcentration.

À retenir

La mise en place d'un cadre étatique français (pouvoir politique et administration) s'est réalisée progressivement par le biais d'un long processus historique. Issu de la volonté centralisatrice de l'autorité royale, celui-ci s'est mis en place dans une logique de domination de territoires parfois réticents à subir une domination perçue comme extérieure. Ils ont ainsi dû conquérir leur propre royaume dont le découpage, largement artificiel, était issu du démembrement de l'empire carolingien (qui se voulait une restauration du bas-empire romain chrétien). S'appuyant sur le corpus idéologique et juridique de ce dernier, les Capétiens vont ainsi développer et structurer l'activité de leur agent pour permettre un enracinement plus fort.

Parvenue à dominer ses concurrentes seigneuriales, ecclésiastiques et urbaines, l'administration royale (à l'origine presque exclusivement judiciaire) va ainsi se perfectionner avec l'émergence de la monarchie absolue aux XVI^e-XVII^e siècles. Cependant, cette modernisation ne sera pas uniforme, affectant beaucoup plus les organes centraux que périphériques.

SECTION 2. L'évolution libérale de l'État



Objectif

- Appréhender le rôle structurant de l'administration et son mouvement de balancier à la fois entre moyen et limite de l'action publique.
- Distinguer l'évolution du droit de l'État à l'État de droit.

Face à la multiplication des critiques contre l'exercice du pouvoir du monarque absolu de droit divin, la pensée libérale contribua à offrir un modèle étatique, et donc administratif, alternatif. Pour mettre fin à l'arbitraire administratif, la mise en place de procédures juridiques contraignantes auprès des institutions publiques constituera ainsi l'objectif principal des hommes de 89 (1). Il s'agissait alors d'une condition d'une mise en œuvre de la souveraineté nationale, et donc, de l'intérêt général (2).

1. L'encadrement du pouvoir de l'État

La pensée libérale est une réflexion politique issue de la contestation contre les excès de la puissance royale permis par le développement et l'implantation de la pensée absolutiste en Europe. En changeant le regard sur le rôle et les missions de la puissance publique, et surtout son rapport aux individus, ce mouvement va ainsi emporter une adhésion croissante, faisant des droits naturels la justification d'un encadrement à la puissance étatique (1A), par le biais d'une soumission de l'appareil administratif au droit (1B).

1A. Les droits individuels, limites à l'autorité publique

Dans l'Europe du XVII^e siècle, la **pensée libérale** apparaît comme une réaction contre le modèle de monarchie absolue, portée par une France en pleine expansion diplomatique, qui se répand alors à travers le continent européen. Dans la vision politique absolutiste, le pouvoir royal dispose, au nom du principe d'unicité de la souveraineté, de l'entier contrôle des institutions publiques. Elle justifie, et présente même comme nécessaire, la concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un monarque qui peut les déléguer à sa guise. Si l'autorité de l'État connaît bien des limites (lois naturelles, divines, ou encore fondamentales), celles-ci ne peuvent donc être contrôlées par aucune institution. Ces dernières ne peuvent être considérées que comme de simples freins et pas comme des contre-pouvoirs. Complétée par les théories de l'institution divine immédiate (communément appelée « droit divin »), cette théorie politique aboutit à affirmer que le roi n'a vocation à assumer la responsabilité de ses actes que devant Dieu. Les limites à l'autorité publique, cadre encore exclusif de la perception de l'action publique, apparaissent ainsi théoriques et même incertaines.

L'exigence d'un contrôle plus rigoureux du respect des limites à la puissance de l'État justifiera les revendications des Lumières visant à l'élaboration d'une constitution. Celle-ci s'avère indispensable car elle doit permettre de fixer les modalités de fonctionnement des institutions politiques ainsi que les principes fondamentaux justifiant la limitation de la puissance publique (selon le modèle fixé par la constitution américaine de 1788 et repris par la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) d'août 1789). Ainsi, l'idée de constitution va-t-elle rapidement se joindre à celle de séparation des pouvoirs susceptible de permettre, à l'inverse du modèle de monarchie absolue, une autolimitation (article XVI de la DDHC : « *Toute société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution* »). Cette idée s'appuie sur l'existence de droits individuels préexistants à l'État lui-même, et donc qualifiés de droits naturels, qui constituent à la fois la cause et l'objet de son établissement (article II de la DDHC : « *Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme* »). Cet encadrement juridique trouve son origine dans l'affirmation d'un contrat de société, établi entre gouvernants et gouvernés. Héritière du thomisme médiéval et de la réflexion monarchomane au début de la période moderne, cette vision contractualiste permet de répondre aux excès autoritaires de la monarchie absolue. Elle fait de l'État un mal nécessaire. Nécessaire, car il constitue le moyen et le cadre de régulation des rapports sociaux dans une vision hiérarchique verticale (on parle d'« État-gendarme ») permettant à chacun de se voir reconnaître ses droits. Un mal, car l'État est aussi un danger permanent qui pèse sur les individus et leurs droits. Dans la vision

libérale, qui consiste à reconnaître une spécificité à l'individu dans le tout, la présence de l'État protège les droits mais opprime aussi. Ainsi plus on étend la sphère de l'État, plus celle-ci entame la liberté des individus. On le comprend bien dans les rapports contemporains entre sécurité et liberté. Les extrêmes étant le totalitarisme (plus d'individu et tout jusqu'à l'intime relève de l'État) et l'anarchie (plus d'État et liberté intégrale de chacun).

Cette vision libérale ne remet pas en cause la perception de l'action administrative comme étant, avant toutes choses, un instrument de domination. Sa caractéristique première est toujours l'exercice de la souveraineté à travers la mise en œuvre d'un pouvoir de coercition. Pour autant, en changeant la légitimité de cette action publique, inscrite désormais dans la logique de souveraineté nationale, la pensée libérale va contribuer à soumettre l'action de l'État, et donc de son administration, à l'emprise du droit (article XV de la DDHC :

« *La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration* »).

1B. L'État de droit

La notion d'État de droit, fondamentale pour comprendre la logique administrative des pays s'en revendiquant, est une conséquence de l'affermissement de l'État libéral à la fin du XIX^e et au début du XX^e siècle. En effet, dans la logique libérale, l'un des principaux champs de réflexion réside dans les modalités d'encadrement de l'État. *Le droit, qui donne à ce dernier la capacité d'agir et d'assurer la défense de l'intérêt général, doit aussi encadrer son autorité pour protéger les intérêts particuliers. D'instrument d'action de l'État, le droit se mut alors en instrument de limitation de sa puissance.* C'est ainsi que la doctrine allemande fit émerger la notion d'État de droit (« Rechtsstaat »). Or, cette notion justifie d'abord la soumission de l'administration au droit défini comme un cadre pyramidal, induisant une hiérarchie institutionnelle. Développé par Hans Kelsen, le positivisme juridique impose ainsi l'exigence du respect par toute norme publique de celle qui lui est supérieure, car elle en tire nécessairement sa propre légitimité. On parle à ce propos du principe de légalité. Celui-ci suppose également que l'administration ne peut agir de son propre chef, mais seulement si elle est habilitée à la faire par l'autorité politique (notion de « compétences d'attribution »), seule délégataire légitime de la souveraineté nationale de par le système de représentation électoral. Ainsi, on garantit la cohérence du corpus législatif et on s'assure que la production administrative restera conforme aux principes qui ont guidé la mise en place de l'organisation publique et aux orientations fixées par le pouvoir politique.

Un tel système suppose une double exigence : tout d'abord, la mise en place d'une justice administrative, indépendante de l'administration, qui devra vérifier le respect par l'administration du droit. Ce contrôle juridictionnel devra ainsi vérifier la conformité de l'action administrative avec l'ordonnancement juridique. D'autre part, le développement d'un véritable droit administratif, qui ne doit plus être simplement une compilation des privilèges de l'administration sur les administrés, mais le support d'une véritable science. Celle-ci permettra de dégager les grands principes de l'action administrative et donc d'éclairer l'administré, lui garantissant l'absence d'arbitraire. Ce double phénomène se mit en place en France à la fin du XIX^e siècle, lorsque le Conseil d'État devint, avec la loi du 24 mai 1872, une véritable cour souveraine. Par ce biais on consacra la naissance d'un second ordre de juridiction (aux côtés de l'ordre judiciaire), lieu d'exercice autonome de la justice administrative. Cette évolution institutionnelle initiera un rééquilibrage du rapport entre administration et administré, dont le point d'orgue sera le basculement dans « l'État-providence » à la Libération.

Dès lors, ce mouvement aboutira à une mutation du droit administratif, droit dérogatoire, dont le critère d'application ne sera plus seulement l'exercice de la puissance publique (école de Maurice Hauriou), mais aussi d'un service public (basculement historiquement interprété comme une conséquence du fameux arrêt Blanco rendu le 8 février 1873 par le Tribunal des conflits, et fortement influencé par l'école du service public de Léon Duguit). L'administré devient alors un usager. Cette évolution était justifiée pour mieux faire correspondre l'armature juridique de l'administration avec sa raison d'être issue des valeurs portées par la Révolution un siècle plus tôt : l'intérêt général. En effet, l'administration ne saurait être assimilée, ou même comparée, à toute autre forme d'organisation en raison de sa finalité. Celle-ci n'est pas particulière mais collective. Placée au service de tous, l'administration se voit toujours octroyer un statut exorbitant du droit commun. Mais désormais, il n'implique plus seulement la détention de moyens d'actions privilégiés, mais aussi des contraintes spécifiques.

2. L'administration au service de l'intérêt général

Face à l'inflexion de son rôle institutionnel, l'administration républicaine issue de l'État de droit dut s'inscrire dans une réflexion sur son rôle social. La distinction entre l'État et la société portée par les valeurs de 1789 faisait mécaniquement de l'administration le point de contact entre l'abstraction et le réel, entre la parole et l'action, entre le particulier et le général. Pour autant, le service public n'a pas fait disparaître la puissance publique et l'exercice de la souveraineté suppose toujours la régulation des rapports sociaux, fondée désormais

sur la supériorité de l'intérêt général sur les intérêts particuliers (A). Malgré tout, l'émergence de la notion de service public, renforcée par celle « d'État-providence », infléchira cette perception d'une administration séparée de la société civile pour, au contraire, insister sur sa participation, et donc son intégration, à la vie sociale (B).

2A. L'administration, défenseur de l'intérêt général contre les intérêts particuliers

Depuis ses origines les plus lointaines, l'État a toujours constitué un moyen de domination justifié par un pessimisme anthropologique. La nature mauvaise de l'Homme induit l'instabilité de l'état de nature qui commande la socialisation et donc la régulation des comportements au sein de la communauté. Or l'autorité politique, comme le rappelait l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ne peut que « remonter à l'une de ces deux sources : ou la force et la violence de celui qui s'en est emparé, ou le consentement de ceux qui s'y sont soumis par un contrat fait ou supposé entre eux et celui à qui ils l'ont déferée »¹.

Dès lors, cette représentation érige l'État en instance transcendante et supérieure du reste de la société, aboutissant d'un point de vue juridique à la séparation fondamentale entre droit privé et droit public.

Elle génère également une distinction entre les intérêts particuliers et l'intérêt général. L'État apparaît ainsi comme un instrument légitime de régulation sociale car il incarne juridiquement l'existence de cet intérêt général. Or, dans la tradition rousseauiste française, ce dernier ne peut correspondre à la somme des premiers. Il constitue un concept autonome, localisé dans un cadre spécifique, l'espace public, et fixe un horizon qui arrache l'homme à son individualité naturelle. Dans cette perspective, ce n'est pas la conjonction d'intérêts aléatoires des différents membres de la société qui fixe la mission de l'État et son administration. L'intérêt général se distingue alors non seulement des intérêts particuliers mais il est même souvent amené à entrer en conflit avec eux et doit s'imposer.

Contrairement à la tradition libérale anglo-saxonne qui développe une inspiration utilitariste et pragmatique de la notion (sous l'influence de la puissance du libéralisme économique perçu comme un corollaire nécessaire de la version politique), l'approche classique française isole donc la sphère publique qui ne peut être que parasitée par les intérêts particuliers. À l'unité de la nation répond alors l'autonomie de l'intérêt général².

Comment cet intérêt général peut-il donc être cerné ? C'est ici la mission de l'État et de son administration qui bénéficie d'un monopole de sa définition. La loi, incarnation de la volonté générale, en sera l'expression privilégiée. En effet, désigné par la volonté générale, exprimée par le suffrage universel, le pouvoir politique (cumulant les puissances législatives et exécutives) est seul habilité à assurer une telle charge. Il va donc fixer les moyens et les objectifs de l'action administrative. Ainsi dictée par la raison, cette dernière se doit à une neutralité absolue. C'est même la condition de sa légitimité.

Non seulement il convient de protéger l'intérêt général du particularisme perçu comme corrupteur, mais il convient également d'assurer sa domination. C'est la mission confiée à l'État par le contrat social.

Cette vision d'un « État-gendarme » s'est cependant infléchie avec la notion de service public. L'État n'est plus seulement un arbitre extérieur et transcendant de la société civile, il en devient un acteur en lui fournissant ses services.

2B. L'administration, acteur social

Le glissement évoqué précédemment de la notion de puissance publique vers celle de service public traduit une inflexion plus générale de la compréhension du rôle et des missions de l'État. À la faveur de la montée de la question sociale, provoquée par l'approfondissement de la révolution industrielle tout au long du XIX^e siècle, il est ainsi apparu de plus en plus évident que l'État ne pouvait demeurer dans une simple position d'arbitre. Sous l'influence de la pensée socialiste, l'idée que l'État devait devenir un véritable acteur social s'est progressivement enracinée. Ce mouvement (dont témoigne en particulier l'apparition d'une législation sociale à la fin du XIX^e et au début du XX^e siècle) aboutira, à la faveur de la Libération de 1945, à l'établissement d'un « État-providence » qui connaîtra son âge d'or pendant les « trente glorieuses » (1945-1974). En effet, les difficultés de la reconstruction, la crise sociale engendrée par l'occupation et les besoins de planification suscités par le plan Marshall vont permettre un compromis historique. Celui-ci aboutira à la mise en œuvre, certes partielle, du programme fixé par le Conseil National de la Résistance. La réalisation la plus emblématique sera la création de la sécurité

1. D. Diderot et JLR D'Alembert (sous dir.), Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Paris, chez Briasson, 1751, Volume 1, p.898

2. Dans cette défiance française historique contre les intérêts particuliers, la puissance du ressentiment des révolutionnaires contre les privilèges d'Ancien régime eurent une influence de premier plan.

sociale (par les ordonnances du 4 et 19 octobre 1945), devant permettre de pallier les risques sociaux (maladie, travail, vieillesse et famille). En droit administratif, par exemple, ce sera l'essor des théories du « socialisme municipal » qui verront des communes intervenir dans des secteurs économiques et sociaux qui avait toujours été laissé à l'initiative privée. Se posera alors le problème du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, notamment lorsqu'une commune crée un dentiste (CE, 1901, *Casanova*), une boulangerie, un service de ravitaillement, plus récemment un réseau de cabloperateurs...

Pourvoyeuse de service, l'administration tire désormais autant *sa légitimité* de son *institution* que de son action. Ce que relèvera le professeur de droit Léon Duguit en 1913 dans son ouvrage sur les transformations du droit public : l'administration n'est plus seulement puissance (théories de Maurice Haurou à Toulouse), mais devient pourvoyeuse de prestations. L'intérêt général a lui aussi évolué : il prend davantage en compte les interdépendances sociales dans le rôle de l'État. Ce sera l'essor de la théorie du service public. Cette mutation engendra autant de conséquences sur l'activité administrative que sur les modalités de sa mise en œuvre.

Dans le premier cas, l'administration va développer sa sphère d'activité pour toujours mieux répondre à l'expression de besoins nouveaux. Elle intervient ainsi progressivement dans des domaines totalement inexplorés jusque-là comme l'aménagement du territoire, la culture, le tourisme ou encore le sport. Dans le second, l'administration va progressivement tirer les conséquences de son rôle d'acteur social pour chercher, non plus à fuir, mais au contraire, à développer ses contacts avec le monde socio-économique. L'idée de neutralité cède alors partiellement le pas à celle d'utilité. La pertinence de son action exige qu'elle développe ses capacités de négociation et que le principe d'autorité s'estompe devant celui d'influence (à l'image de la mutation de la fonction préfectorale dans la seconde moitié du XX^e siècle³).

Cette diversification du champ d'intervention de l'administration va nécessairement aboutir à la complexification de ses missions. Cette situation aura pour conséquence d'autonomiser la structure administrative.

3. Sur ce point, voir Im Tobin, *Le Préfet dans la décentralisation*, Paris, L'Harmattan, 1997

Notions clefs

Notion	Définition
Libéralisme	Courant de pensée apparu au XVII ^e siècle et originaire de Grande-Bretagne visant à contredire les théories absolutistes alors largement dominantes en Europe. Portée notamment par John Locke, cette vision tend à encadrer la puissance de l'État au nom des droits individuels. Elle va se propager en France et dans le reste du continent par le biais du mouvement des Lumières.
État de droit	Issue de la doctrine allemande (« Rechtsstaat ») au XIX ^e siècle, cette notion vise à soumettre entièrement l'État et l'ensemble des personnes publiques aux règles de droit qui auront été préalablement élaborées. Ce système aboutit à une pyramide de normes qui permet de garantir aux administrés le respect de leurs droits individuels.
Intérêt général	Héritière du bien commun médiéval (connotation religieuse), cette notion légitime l'autorité de l'État en charge de défendre les intérêts supérieurs de l'ensemble de la communauté (la nation) face aux revendications individuelles.
Séparation des pouvoirs	Développée par Montesquieu dans son fameux ouvrage « De l'Esprit des lois » (1748), cette organisation de la puissance publique distingue les principaux pouvoirs attribués à l'État (législatif, exécutif et judiciaire) pour permettre la mise en place de contre-pouvoirs internes et donc un contrôle interne (« check and balance »).
État-gendarme / État-providence	Ces deux notions renvoient au rôle global attribué à l'État. Dans le premier cas, l'État n'est considéré que comme un régulateur des rapports sociaux. On va alors le cantonner dans ses missions régaliennes centrées sur son autorité. Dans le second, l'État n'est plus seulement un arbitre mais doit être aussi un acteur social qui répond aux besoins de sa population. Ces deux conceptions se sont succédées en France de part et d'autre de la seconde guerre mondiale.

À retenir

L'État libéral s'est d'abord construit en réaction aux excès de la centralisation des États européens absolutistes. S'appuyant sur une philosophie de droits naturels individuels, cette vision politique va ainsi revendiquer, non seulement une limitation des pouvoirs de l'État, mais surtout la mise en place de véritables moyens de contrôle. Les révolutions anglaises (1688), américaines (1776) et françaises (1789) vont ainsi contribuer à ériger une nouvelle légitimité (nationale) de l'exercice de la souveraineté qui engendrera la soumission de l'État au droit. D'origine contractuelle, ce dernier va ainsi devoir être à la fois producteur de normes, en tant que régulateur de l'ordre social, mais aussi s'y soumettre. C'est le sens de la mise en place d'une constitution organisée sur le modèle de la séparation des pouvoirs.

Dans un second temps (fin du XIX^e siècle) la question sociale est venue infléchir ce modèle initial. L'État ne devait plus être seulement un instrument de puissance et de domination. Il devait également pourvoir aux besoins des membres de la communauté nationale. La transformation républicaine de « l'État-gendarme » en « État-providence » était en route. Dans ce contexte, l'administration, au service de l'intérêt général, vit ses compétences et ses domaines d'intervention largement étendus.



Objectif

- Appréhender les conséquences de l'évolution historique du rapport entre l'administration et ses administrés / usagers (« État-providence »).
- Connaître les grands principes qui guident la mise en œuvre du statut de la fonction publique.

La description de la place de l'administration dans l'architecture juridique de l'État est essentielle à la compréhension de son action. Ce regard extérieur n'est pas pour autant suffisant. Il convient ainsi d'appréhender également son organisation interne. À ce titre, face à la diversification de l'action publique et à l'évolution du rapport entre l'État et les citoyens (cf. « État-providence »), il est apparu nécessaire de préciser et de renforcer les règles statutaires de l'organisation administrative (Section 1) mais aussi de ses agents (Section 2).

SECTION 1. Le particularisme statutaire de l'administration

L'autonomisation de l'organisation administrative s'explique à la fois par la spécificité de son positionnement juridique au sein de l'architecture institutionnelle (Section 1) et par la particularité des principes généraux de son établissement (Section 2).

1. L'exception normative et juridictionnelle

Le statut administratif est particulier à un double titre. D'une part, en raison de son strict encadrement légal assurant la soumission hiérarchique de l'appareil administratif au pouvoir politique (1A). D'autre part, en raison du contrôle du juge administratif garantissant quant à lui la conformité de l'action administrative aux règles de droit (1B).

1A. Le principe de légalité administrative

D'après Yves Gaudemet, « la légalité est un rapport entre des règles limitatives et les activités administratives qu'elles viennent limiter »⁴. Ainsi, l'administration est-elle tenue de conformer son action au principe de légalité. Elle est donc, depuis le légicentrisme révolutionnaire (amour immodéré pour l'acte parfait qu'est la Loi) une grande « agence de mise en œuvre et d'application de la loi ». Ce dernier dépasse d'ailleurs aujourd'hui le seul cadre de la loi au sens strict. Il comprend l'ensemble des sources écrites et non-écrites qui dominent les actes administratifs dans la pyramide des normes (cf. ci-dessus, Section 2, §1, B). On retrouve ainsi au-dessus des actes administratifs, le bloc de constitutionnalité, les traités internationaux, les lois et règlements ainsi que les principes généraux du droit (PGD — CE, 1959 *Syndicat général des ingénieurs-conseils*) pour le niveau national, mais aussi les normes européennes (droit primaire et dérivé — voir les arrêts *Nicolo* en 1989 et *Rothmans* en 1992) en raison du principe de primauté.

Ainsi, l'administration est tenue de respecter l'ensemble de ce corpus juridique dans la mise en œuvre juridique de son action. L'intérêt général domine l'intérêt particulier, mais le droit délimite cette domination. Il fixe par ce biais les capacités d'action de l'administration en lui imposant de multiples conditions permettant de protéger les droits individuels des administrés. La qualité de l'auteur de l'acte, sa forme, son objet ou encore son but doivent ainsi se conformer à ce cadre légal. En fonction de l'importance du domaine concerné, ou de la gravité de la décision administrative, il se peut même que l'administration puisse être liée jusque dans ses mobiles (c'est pour cela que le contentieux administratif distingue l'erreur de droit — analysant les motifs du texte — et le détournement de pouvoir — analysant plus profondément les mobiles afin d'éviter qu'une administration n'utilise pas un pouvoir dans un but autre que celui pour lequel il lui est confié). À ce titre, on distingue les pouvoirs administratifs liés, des pouvoirs discrétionnaires (les deux se conjuguant souvent dans une approche mixte).

4. Yves Gaudemet, *Droit administratif*, Paris, LGDJ, 20e édition, 2012, p.123

Alors que dans le premier cas, c'est la loi (au sens large) qui fixe a priori des motifs qui doivent guider l'acte (les conditions de délivrance du permis de conduire par exemple). À l'inverse, dans le cas de pouvoir discrétionnaire, c'est à l'agent lui-même qu'il appartient d'apprécier la validité de son action, tout en respectant les autres éléments mentionnés précédemment (en matière de police administrative par exemple). Cette seconde catégorie permet d'éviter l'écueil d'une administration trop robotisée et donc au mieux inefficace, au pire, dangereuse. Elle permet ainsi d'adapter le droit aux faits. Mais cette marge d'appréciation soustrait également, au moins en partie, l'administration à ses obligations hiérarchiques issues de l'État de droit. Lorsque cela est possible, un état de droit doit donc doser subtilement ces deux modalités d'action afin de concilier les exigences, parfois contradictoires, de défense des droits individuels et d'efficacité de l'action publique.

À ce titre, on constate aisément l'emprise du droit sur l'administration. Non seulement il fixe son organisation mais aussi ses modalités d'action. L'administration est donc avant toutes choses un sujet et un objet du droit. Plus que toute autre forme d'organisation humaine, l'administration est liée au régime juridique qui lui a été assigné depuis une entité extérieure.

Cette dépendance administrative fait également intervenir un autre acteur, le juge, nécessairement indépendant comme l'expliquait déjà Montesquieu au XVIII^e :

« Il n'y a point de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire : car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur »⁵.

1B. La justice administrative

Le principe de soumission de l'administration au droit – base même d'un « État de droit » – suppose l'existence d'une institution juridictionnelle susceptible de garantir le respect du second par la première et ce, de façon indépendante. À ce titre, deux possibilités sont envisageables. Soit, on soumet le contentieux administratif au juge ordinaire (système des pays anglo-saxons) soit on met en place un second ordre de juridiction, parallèle à l'ordre judiciaire, que l'on va qualifier d'ordre administratif (modèle des pays continentaux européens et spécifiquement français avec la loi des 16 et 24 août 1790 séparant les autorités).

Or, c'est cette seconde voie qui a été choisie par notre pays. En effet, conscient du rôle fondamental joué par les magistrats parlementaires dans l'effondrement de l'Ancien régime, les révolutionnaires vont immédiatement affirmer la nécessité de soustraire le contentieux de l'action administrative à la connaissance des juges judiciaires. En l'espèce, c'est la crainte historique du « gouvernement des juges » qui a inscrit dans la tradition française de séparation des pouvoirs un esprit « anti-judiciaire » et a fixé cette orientation (alors que dans la tradition anglo-saxonne, c'est le principe de spécialisation, c'est-à-dire la séparation entre administration active et son contentieux qui a abouti à une solution inverse). Ainsi la célèbre loi des 16 au 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ont-ils rapidement fixé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires (« Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions »).

Cette solution n'aboutit pas pour autant immédiatement à l'émergence d'un véritable ordre juridictionnel administratif. En effet, conformément à une ancienne maxime du droit français, le législateur français a longtemps considéré que « juger l'administration, c'est encore administrer ». Ainsi, il fallut après la Révolution, un long processus historique de près d'un siècle pour qu'enfin l'indépendance du juge administratif soit consacrée institutionnellement. Dans l'intervalle, et dans la continuité de l'approche d'Ancien régime, le contentieux administratif fut abandonné aux administrateurs eux-mêmes (ministres et plus tard préfets dans les départements). On parle à ce propos du système de l'« administration — juge ». Évidemment, on comprend que cette démarche faisait largement primer les impératifs de puissance publique sur les droits individuels des administrés. Face à une administration juge et partie, ces derniers se retrouvaient clairement dans une position d'infériorité traduisant la permanence de l'attachement à la notion de puissance de l'État dans les esprits français, par-delà même la Révolution française.

Pour que se mette en place le principe de spécialisation, exigeant la séparation entre administration active et contentieux administratif, il fallut ainsi attendre la III^e République. C'est la loi du 24 mai 1872 (complétée par l'arrêt Cadot du 13 décembre 1889) qui affirma l'indépendance du Conseil d'État, dans sa section contentieuse (article 9) : « Le Conseil d'État statue souverainement sur les recours en matière contentieuse et sur les demandes en annulation pour excès de pouvoir ». Par ce biais, la loi entérinait l'indépendance du juge administratif et l'émergence d'un véritable ordre juridictionnel administratif.

5. Montesquieu, De l'esprit des lois, in Œuvres complètes, Paris, Édition de Ch. Lahure, 1859, t. I, p.130

Elle permet ainsi de rééquilibrer le rapport jusque-là très vertical entre administration et administrés et d'appréhender de manière plus équilibrée la conjonction entre les nécessités de l'intérêt général et la protection des droits individuels. Il s'agit d'un élément clef du basculement, évoqué précédemment, entre puissance publique et service public (ce qui explique que le droit administratif contemporain soit toujours essentiellement d'origine jurisprudentielle).

2. La diversification de l'établissement administratif

Comme nous l'avons vu précédemment, l'administration constitue un point de contact entre l'abstraction et la pratique, entre le droit et les réalités de terrain. Face à la complexité croissante des problématiques qui lui sont soumises depuis l'approfondissement de « l'État-providence », cette dernière a été amenée à rompre, partiellement, avec ses traditions unitaires jacobines. Il s'agissait là d'une notion cardinale puisque l'administration se présente nécessairement comme un ensemble cohérent, hiérarchisé et intégré, devant permettre la mise en œuvre de la décision politique. Or, cette vision classique s'est largement atténuée depuis près de cinquante ans pour laisser place à un morcellement administratif. Celui-ci se matérialise autant au niveau organique (2A) que territorial (2B).

2A. La fragmentation organique

À mesure du développement et de la diversification de l'action administrative, sa structure a connu une complexification croissante. Il a fallu s'adapter, non seulement à des problématiques nouvelles, mais aussi aux exigences nouvelles des populations nées de l'intervention publique dans des champs sociaux jusque-là inexplorés. En tant que producteur de services, l'administration dut ainsi répondre à des contraintes que l'approche antérieure « d'État-gendarme » n'avait jamais soulevées. Alors que la recherche d'uniformité avait guidé les réformes administratives originelles (au nom du principe d'égalité juridique), ce bloc monolithique s'est par la suite fissuré (certains évoqueront un « démembrement de l'État »). L'hétérogénéité a progressivement repris le pas sur l'homogénéité. C'est ainsi, qu'aux côtés des traditionnelles structures de l'administration générale, de nouveaux organismes, chargés de missions nouvelles, sont venus s'agréger (agences, Haut Conseil, comités...).

Il convient ici de mentionner des structures mises en place sous forme de délégations, devant permettre de répondre à des nécessités spécifiques et/ou ponctuelles que la rigidité des structures ministérielles classiques rendait inadaptées. On évoque à leurs propos des administrations de missions (qu'on va opposer à l'administration de gestion, tournée autour de tâches quotidiennes et générales)⁶. On les retrouve, en fonction des priorités gouvernementales, dans les domaines de la recherche scientifique, de l'aménagement du littoral ou encore de la condition féminine... (parmi les premières structures créées, on peut citer l'Office national des forêts en 1964 ou l'Agence Nationale Pour l'Emploi en 1967). La particularité de ces organes réside à la fois dans leur transversalité, devant permettre de surmonter les blocages de la sectorisation de l'administration générale, mais aussi dans leur spécialisation matérielle, ayant vocation à répondre à un programme précis. L'objectif poursuivi est alors la flexibilité du système, puisque dépourvues d'attributions de gestion, ces entités ont vocation à impulser des actions auprès des organes préexistants.

Aux côtés de ces administrations de missions, mais toujours liées à la croissance de l'activité administrative, se sont développées les administrations indépendantes. Connues sous l'acronyme d'AAI (autorités administratives indépendantes), ces structures extérieures à la hiérarchie administrative traditionnelle ont pour mission première de répondre à l'aspiration d'amélioration des rapports entre public et privé en permettant notamment une meilleure garantie des droits individuels. Ces AAI ont ainsi pour mission première de permettre une meilleure régulation sectorielle. L'intervention des AAI, plutôt que celle de l'administration de gestion, se justifie alors par la particularité des domaines concernés qui exige une garantie renforcée des droits particuliers (par exemple le CSA dans le domaine de l'audiovisuel, la CNIL en matière informatique ou encore l'ASN pour la sûreté nucléaire). Leur mission de contrôle de l'activité administrative justifie leur indépendance vis-à-vis de l'appareil administratif et donc leur soustraction, partielle, à l'emprise du pouvoir politique.

Enfin, il convient de citer ici les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et les établissements publics à caractère administratif (EPA) qui constituent des personnes morales de droit public ayant la charge d'assumer une activité de service public spécifique. Alors que les premiers ont vocation à assurer un service public de nature commerciale (RATP), les seconds assument un service public de nature administrative (Pôle emploi). Ils constituent tous deux des témoignages du développement de « l'État-providence » et de la notion de service public. À leurs côtés, figurent également des sociétés anonymes à capital partiellement ou totalement public (SNCF, EDF...).

6. Sur cette distinction, voir Edgar Pisani, « Administration de gestion, administration de mission », in *Revue française de science politique*, 6^e année, n° 2, 1956, pp. 315-330

2B. La fragmentation territoriale

À côté de cet émiettement fonctionnel, figure également une inflexion organique au principe d'unité de l'administration. Celle-ci est, cette fois, liée à une atomisation territoriale de la structure administrative. Ainsi, l'appareil bureaucratique est-il multipolaire. À ce titre, il s'appuie sur différentes légitimités politiques permettant l'émergence de plusieurs personnes morales de droit public au sein même de l'administration générale. On retrouve, d'une part, une administration centrale subordonnée au pouvoir politique désigné par la nation dans son ensemble et, d'autre part, des administrations locales au service de pouvoirs limités à des territoires déterminés. Ces deux entités cohabitent et collaborent, en particulier par l'entremise du préfet, pour assurer la présence publique sur l'ensemble du territoire national.

L'administration centrale déconcentrée et l'administration locale décentralisée forment ainsi un double niveau d'implantation administrative. Cette logique a été mise en place à l'occasion des lois n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux « droits et libertés des communes, des départements et des régions » et n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la « répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ». La décentralisation de 1982, complétée par un acte II en 2003 puis par les réformes de 2010, 2013 et 2015, constitue, elle aussi, une évolution de la tradition jacobine hexagonale. Ce processus de décentralisation administrative, initié dès la Monarchie de juillet et approfondi par la IIIe République avec ses lois départementales et municipales de 1871 et 1884, s'est appuyé sur la reconnaissance d'une nouvelle légitimité, locale et plus seulement nationale, d'exercice du service public.

Ainsi, l'organisation administrative française s'est-elle appuyée de part et d'autre des lois Defferre de 1982 et 1983 sur deux cadres organiques différents. À partir de là, les services de l'État ne disposent plus sur les collectivités territoriales et sur leurs structures administratives (communes, départements et régions) de pouvoir hiérarchique avec la fin du contrôle d'opportunité préfectorale (ne reste plus qu'un contrôle de légalité a posteriori). Constitués uniquement des structures bénéficiant d'une délégation de pouvoir de l'autorité publique étatique, les organes publics locaux ne se situent donc plus dans le cadre d'un modèle de régulation croisée entre le centre et la périphérie. Ainsi, la déconcentration, longtemps « comprise comme un substitut à la décentralisation, en est aujourd'hui la conséquence et le complément »⁷.

7. G. Marcou, « II. Bilan et avenir de la déconcentration », in *Annuaire des collectivités locales*, tome 22, 2002, p.26

Notions clefs

Notion	Définition
Administration active	Groupe de services placés sous la direction d'un ministre nommé par le pouvoir exécutif selon une classification thématique libre (affaires étrangères, intérieur, éducation...). Chaque ministère est composé d'un cabinet, d'une administration centrale et de services déconcentrés (appelés jusqu'en 1992 « services extérieurs ») situés dans les diverses circonscriptions.
Principe de légalité	Ce principe peut se définir comme l'expression de la soumission de l'administration aux règles de droit. Il se traduit généralement par une pyramide des normes (appelée également pyramide de Kelsen) qui fait qu'une norme ne peut produire des effets juridiques que si elle est conforme à celle qui lui est supérieure.
Juge administratif	Magistrat de l'ordre administratif en charge de contrôler la soumission de l'activité administrative aux règles de droit. L'indépendance de cette justice administrative, indispensable à une réelle garantie des droits des administrés, s'est faite tardivement dans l'histoire de France (loi du 24 mai 1872).
Administration déconcentrée	Mode de gestion administrative consistant à attribuer, sous le contrôle du pouvoir central, aux autorités administratives une capacité de décision au sein des différentes circonscriptions administratives (ex : Intendant, Préfet...). Il s'agit alors d'une adaptation d'un système demeurant centralisé.
Administration décentralisée	Système d'administration consistant à permettre à une structure publique locale (décentralisation territoriale) ou à un service (décentralisation technique) de s'administrer eux-mêmes en les dotant de la personnalité juridique, d'autorité et de ressources propres. Pour le pouvoir central, il n'existe plus de contrôle d'opportunité mais simplement un contrôle de légalité.

À retenir

Face à une exigence renforcée de soumission aux règles juridiques (avec l'émergence d'une justice administrative séparée de l'administration active), l'administration s'est réformée dans une logique bureaucratique. Désormais l'administré n'était plus assujéti au système de « l'administration-juge ». Il se présente comme un usager d'un service public (et moins comme un administré soumis à la puissance publique), et voit le respect de ses droits garantis par une autorité indépendante.

Cette évolution de son cadre institutionnel va évidemment avoir un impact sur l'activité administrative. Face à une complexification croissante, il a fallu adapter son mode de fonctionnement à cette nouvelle relation avec son environnement social. C'est ainsi que la vision jacobine d'une administration uniforme s'est progressivement fissurée pour laisser place à une diversité d'acteurs administratifs. Qui plus est, certains de ces acteurs vont même s'extraire du giron étatique. Sans basculer dans le fédéralisme, la décentralisation va ainsi faire apparaître une nouvelle administration, soumise à une légitimité non plus nationale mais locale.

SECTION 2. La spécificité de l'appareil administratif



Objectif

- Connaître les caractéristiques de la professionnalisation de la fonction publique.
- Maîtriser les avantages et les inconvénients de la bureaucratisation de la fonction publique.

Non seulement l'administration connaît des règles spécifiques en matière d'organisation mais aussi quant au statut et aux modalités de gestion de ses agents. Évidemment, cela ne peut rester sans conséquence sur les principes généraux qui guident à l'organisation de ce que l'on appelle l'appareil administratif. Ainsi, ce dernier est-il professionnalisé (1) et bureaucratique (2).

1. La professionnalisation administrative

L'administration publique, en dépit d'un objectif unique qui est le service de l'intérêt général, ne constitue pas un bloc homogène. La confrontation de cette unicité avec la multiplicité de ses domaines d'intervention impose une stratification (1A) et une hiérarchisation (1B) de son organisation des ressources humaines.

1A. La profession de fonctionnaire

Comme l'a souligné Jacques Chevallier : « La substitution du professionnalisme à l'amateurisme marque une transformation très profonde dans la conception de la fonction publique : elle signifie que l'exercice des tâches administratives incombe désormais à des agents spécialisés, dotés d'une qualification particulière et formant de ce fait un groupe spécifique »⁸. Devenu permanent, le service de l'administration va ainsi constituer une activité qui va nécessiter un savoir spécialisé et être encadrée par un ensemble de règles.

Ce schéma n'a pas toujours été en œuvre depuis l'origine de la fonction publique. Ainsi, les révolutionnaires vont le rejeter, en généralisant l'élection par la population des fonctionnaires. Par ce biais, leur objectif était de les soustraire à l'autorité hiérarchique d'un roi, chef du pouvoir exécutif et donc de l'administration, dont l'adhésion aux valeurs de 1789 était suspecte. Évidemment, dans un tel modèle de désignation il ne peut y avoir le caractère de permanence indispensable à l'émergence de professions publiques. Cette approche fut assez rapidement décriée (problème de compétences, politisation de l'administration) et l'arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte en l'an VIII (1799) marquera l'abandon définitif d'une telle approche (il convient d'ailleurs ici de noter que l'administration retombera sous la pleine et entière autorité du pouvoir exécutif, marquant une volonté de reprise en main du pays afin d'assurer le retour de l'ordre).

Cette permanence de l'agent, incarnée aujourd'hui par son statut, se justifie avant tout par une exigence de compétence. Face à la diversification des tâches, à des procédures complexes et à la recherche toujours plus forte d'efficacité de l'action publique, il est ainsi apparu évident que l'administration avait besoin de professionnels adaptés et formés. C'est ainsi que les critères de sélection ont évolué avec le temps. Sous l'Ancien régime, et alors que l'État disposait de prérogatives encore limitées, l'apport financier constitua longtemps le principal critère de recrutement. Ce fut dans cette logique que se mit en place, de manière empirique, le système de patrimonialité des offices, dont l'atout essentiel était de permettre le renflouement des caisses du Trésor royal avec l'affairement d'une taxe (la célèbre Paulette mise en place par un édit de 1604). Si ce système assurait des rentrées considérables, permettant de financer le développement de l'action publique, il fut pourtant très rapidement complété par celui des commissaires, au nom justement de l'efficacité administrative.

Au XIX^e siècle, les opinions politiques jouèrent un grand rôle dans les modalités de sélection des agents publics. En effet, l'instabilité politique caractéristique de cette période contribua à développer le favoritisme administratif afin de mieux enraciner des régimes souvent instables. Il fallut attendre la République pour qu'une sélection uniquement centrée sur les compétences, avec le système des concours, se généralise. Cependant, ce ne fut pas un processus simple à mettre en œuvre puisqu'il faudra attendre la Libération pour que les autorités politiques se résolvent à mettre fin à ces pratiques anciennes avec la systématisation des concours comme moyen d'accès

8. Jacques Chevallier, Science administrative, Paris, PUF, Thémis, 4^e édition, 2007, p. 311

à la fonction publique. Les réticences de la classe politique s'appuyaient sur les nécessités de la flexibilité de l'appareil administratif que le statut en général, et le concours en particulier, risquait de ruiner (Il convient d'ailleurs de noter que ces dernières années, à la faveur du grand mouvement de modernisation administrative (RGPP, MAP, AP 2022) les concours publics ont évolué. Ils cherchent davantage à mettre en avant la personnalité et les compétences professionnelles des candidats au détriment des connaissances théoriques). Dans le même sens, les initiatives visant à développer la formation continue doivent permettre d'accroître la mobilité des agents et donc l'efficacité des structures, sans véritablement atteindre pour l'instant les objectifs fixés.

1B. La catégorisation du personnel administratif

La pyramide institutionnelle, instrument de concrétisation de la décision politique, se reproduit jusque dans l'organisation sociologique du personnel administratif. Les catégories d'emplois publiques, en tant que classement social, engendrent ainsi de grandes diversités au sein de la fonction publique. L'accession à ce statut, par le biais du concours, traduit d'ailleurs cette classification. Les emplois de catégorie A (avec une sous-division A+) correspondent ainsi aux missions de conception, ceux de catégorie B à des fonctions d'application et enfin ceux de catégorie C à des tâches d'exécution (cette classification est en place depuis les origines de la fonction publique puisque, dès la Révolution, on distinguait le fonctionnaire qui disposait d'un pouvoir de décision de l'employé public, simple exécutant). Depuis la mise en place d'un statut général en 1946, l'agent est donc placé à son entrée dans un corps qui constitue un cadre relativement hermétique dont on ne peut s'arroger qu'en répondant aux exigences de la promotion interne. Ainsi, ce n'est pas un emploi qui est affecté au fonctionnaire et qui détermine son positionnement dans la classification des ressources humaines, mais un titre (on parle de fonction publique de carrière et pas d'emploi) qu'on appelle un grade (et à l'intérieur duquel l'agent pourra évoluer en fonction de son ancienneté avec le système des échelons qui fonctionnent avec l'ancienneté. En général, un agent est recruté à l'échelon le plus bas de son grade).

Parallèlement à cette première hiérarchie, apparaissent des spécialités professionnelles, correspondant aux différents secteurs d'activité administrative, qu'on appelle des corps (pour la fonction publique d'État. Dans la fonction publique territoriale, on évoque des « cadres d'emploi ») et qui vont déterminer le statut, les attributions et le traitement de l'agent (par exemple : corps d'inspection ou corps supérieurs de l'éducation et de la recherche (A+) ; corps des attachés de l'administration de l'État ou corps des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale (A) ; corps des contrôleurs du travail ou corps des secrétaires administratifs (B) ; corps des adjoints administratifs ou corps des magasiniers de bibliothèque (C). Ces différentes catégories sont déterminées par des décrets en Conseil d'État.

Il convient ici de noter que l'accès à certains corps d'élite (catégorie A+ : missions de direction ou d'inspection) est globalement réservé aux agents issus de grandes écoles de formation (ENA, Polytechnique...). Ces individus, qui sont au cœur des processus décisionnels de l'administration se trouvent ainsi, dès leur formation, dans une situation de proximité avec le pouvoir politique, souvent issu des mêmes filières. Cela permet d'assurer une forte cohérence de la vision et de l'action publiques mais contribue également à scléroser les initiatives, et surtout, à mettre en place une frontière très hermétique entre la « haute fonction publique » et le reste des agents. Qui plus est, malgré l'introduction des concours comme mode ordinaire de recrutement des agents, ce filtre des grandes écoles contribue à entretenir et à reproduire, voire à renforcer, la perception de l'appartenance à une élite sociale.

L'administration devient alors une représentation fidèle, et même un moyen de consolidation, de la stratification sociale⁹ consacrant aux yeux de la population la perception d'une caste verrouillant l'autorité publique et bénéficiant de privilèges.

2. La bureaucratisation des corps administratifs

Le caractère bureaucratique de l'administration est incontestable. Défini par le célèbre sociologue Max Weber, cette particularité se traduit par plusieurs traits caractéristiques : hiérarchie des fonctions, définition précise des sphères de compétence de chaque agent, rémunération fixe en fonction du positionnement hiérarchique, dépersonnalisation des fonctions assurées...

Ainsi, l'ensemble des traits marquants de l'administration qui viennent d'être évoqués correspondent à ce modèle. L'unité des structures, l'organisation fortement hiérarchisée et la professionnalisation des agents sont logiquement au cœur de l'évolution administrative française. Or, pour mieux comprendre ce modèle bureaucratique, il conviendra d'aborder le processus historique qui en a été à l'origine (2A). Il nous permettra de comprendre comment le statut général des agents, si longtemps repoussé, a pu devenir aujourd'hui l'un des fondements de cette architecture institutionnelle (2B).

9. Voir sur ce point, Pierre Bourdieu, *La noblesse d'État*, Grandes écoles et esprit de corps, Les Éditions de minuit, 1989

2A. La bureaucratisation, fruit d'un processus historique

La bureaucratisation de l'administration française apparaît souvent comme un défaut. Ce modèle organisationnel a, depuis ses origines révolutionnaires, fait l'objet de vives critiques. On lui reproche ainsi sa lenteur, sa complexité, son inefficacité, voire son aveuglement. Dès les premiers temps de la fonction publique, l'image de l'agent public est souvent effacée derrière la déshumanisation d'une machine trop rigide. L'administré se sent tenu à distance et dépourvu de toute prise sur un processus de décision apparaissant comme obscur. L'administration apparaît alors comme inaccessible.

Ainsi, la distance installée avec l'administré place systématiquement ce dernier en position de demandeur d'une prestation standardisée. La complexité des systèmes institutionnels et procéduraux semble même permettre un secret susceptible d'autoriser l'iniquité. L'utilisateur paraît alors soumis au bon vouloir d'un agent qui, par le jeu hiérarchique et celui d'une procédure souvent écrite, s'anonymise et dépersonnalise donc leur relation. L'administré, individu isolé et par nature élément extérieur à la sphère administrative se trouve donc souvent démuni pour comprendre les motifs de la décision qui s'applique à lui. Cela nuit évidemment à sa légitimité et favorise les revendications de transparence des citoyens. Le développement de la dématérialisation a encore renouvelé cette problématique même si elle a contribué, d'un autre côté, à diminuer les délais administratifs qui constituent, eux aussi, des facteurs de tension entre l'administré et l'administration. D'autre part, l'administration fait depuis plus de trente ans des efforts pour améliorer la communication avec les administrés et donc la transparence de ses processus de décision (voir par exemple la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ou encore la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016).

Par ce biais, l'État tente de mettre en œuvre un mouvement de dé-distanciation qu'il a lui-même contribué à mettre en place. Cependant, ces efforts ne pourront jamais aboutir à une transparence intégrale érigée en mythe¹⁰. En effet, celle-ci charrie l'idée d'une administration ayant vocation à dialoguer avec des administrés replacés sur un pied d'égalité. Cela ne peut se réaliser car il s'agirait d'un basculement total de l'action administrative vers l'idée de service public. Or, la puissance publique demeure un élément structurel de l'appareil administratif, garante de l'ordre public et donc de la cohérence collective. Qui plus est, la distanciation bureaucratique de l'administration, dépositaire de l'intérêt général, constitue pour elle une protection contre les immixtions particulières. L'un des enjeux actuels de la relation administration / administrés réside donc surtout aujourd'hui dans la simplification de ses procédures de décision¹¹. Celle-ci permettrait de renforcer la compréhension des processus décisionnels, et donc leur légitimité, tout en préservant la notion d'intérêt général.

2B. Le statut général, clef de voûte de la bureaucratisation

L'une des principales justifications à la bureaucratisation administrative opérée au XX^e siècle réside dans la volonté d'atténuer l'exposition de cette organisation aux fluctuations du pouvoir politique. La stabilisation républicaine, désormais irréversible, mais aussi le contexte particulier et unificateur de la reconstruction permettaient enfin cette réforme évoquée depuis tant d'années. L'administration devait pleinement se placer au service de l'État, défendre l'intérêt général et ne plus être un outil de clientélisme. À ce titre, la neutralité politique de l'administration est un élément essentiel de la légitimité de son action. Cela est d'ailleurs d'autant plus vrai dans les démocraties représentatives qui impliquent nécessairement l'alternance politique. Dans cette optique, l'administration doit être un moyen fiable et efficace de la mise en œuvre de la volonté générale. La neutralité qui la caractérise doit donc autant la protéger des intérêts particuliers des administrés que des formations politiques.

Or, cette conception est relativement récente. L'histoire administrative française penche même largement dans une autre direction. Dès l'Ancien régime, la personnalisation du pouvoir, corollaire de la centralisation institutionnelle, avait enraciné la domination du pouvoir politique sur les structures administratives. L'État était alors perçu comme un corps dont l'autorité royale était la tête et dont tout dépendait directement.

Après la Révolution, l'instabilité des régimes en place et les nécessités d'affermir l'emprise administrative sur le territoire national ont justifié la perpétuation de cette tradition (sous la Monarchie de juillet (1830-1848), l'usage de nommer des parlementaires comme fonctionnaires afin de s'attirer leurs bonnes grâces était extrêmement répandu). Il fallut ainsi attendre la III^e République et l'administration républicaine pour qu'une frontière plus nette

10. Sur ce point, voir Jacques Chevallier, « Le mythe de la transparence administrative », in *Information et transparence administratives*, PUF, 1988, pp. 239-275

11. Voir Éric Gristi, *La réforme de l'État*, Paris, Librairie Vuibert, 2007, p. 444 et suiv.

permette de définir plus clairement les sphères respectives de ces deux entités. Qui plus est, la mise en œuvre d'une réelle séparation des pouvoirs a permis depuis, à l'exception de la parenthèse vichyste, d'encadrer les velléités accaparatrices des pouvoirs gouvernementaux et parlementaires.

C'est ainsi que l'exigence démocratique de clarification des relations entre l'administration et l'autorité politique accompagne les revendications d'élaboration d'un statut général depuis le début de l'« ère républicaine ». Il s'agissait alors de protéger l'agent de l'emprise absolue de sa hiérarchie pour lui permettre, dans le respect de ses obligations générales, de se soustraire aux immixtions partisans.

Cependant, les discussions achoppèrent longtemps sur les réticences de la classe politique (voir par exemple la présidence du conseil de G. Clémenceau (1906-1909) ou l'entre-deux-guerres)¹², et de la haute-fonction publique. Ces deux sphères où les activités politiques et administratives se rejoignent étaient réticentes à rompre avec la flexibilité managériale et hiérarchique que leur conférait l'absence de statut. Il en allait de l'unité, de la cohérence et de la continuité de l'État. Ce dernier point était particulièrement sensible puisque les revendications statutaires contenaient des sonorités syndicales. Or le droit syndical avait toujours été rejeté depuis sa reconnaissance (loi Waldeck-Rousseau de 1884) pour les fonctionnaires.

Les adversaires du statut général, qui parvinrent à repousser toutes les tentatives pendant près de cinquante ans, y voyaient donc la réintroduction d'une autre forme de politisation, aussi pernicieuse, voire davantage, que la politisation hiérarchique.

Finalement, il fallut donc attendre l'autoritarisme vichyste, et surtout, le consensus politique de la Libération pour que ces réticences soient écartées.

Ainsi la loi du 19 octobre 1946 a introduit ce cadre juridique contraignant. Limité à la fonction publique d'État, il sera partiellement modifié par l'ordonnance du 4 février 1959. Enfin, il sera étendu par les lois du 13 juillet 1983, du 11 et du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986. En plus de la fonction publique d'État, ce statut sera ainsi appliqué aux agents de la fonction publique territoriale (particulièrement exposée à la problématique de politisation) et hospitalière. L'ensemble de ces textes fixent désormais les droits et obligations des fonctionnaires (hors quelques exceptions justifiées par le positionnement stratégique des missions confiées à ces catégories socio-professionnelles comme les préfets, les magistrats ou encore les militaires).

S'il est parvenu, partiellement, à ses objectifs de dépolitisation hiérarchique et donc de stabilisation de la sphère administrative, le statut général reste l'objet de critiques et de remises en cause. On lui reproche son iniquité dans une société exposée à la crise mais, surtout, de nuire à l'efficacité administrative par sa rigidité. Or, dans un contexte de contraintes budgétaires, et face aux exemples d'évolutions d'autres pays européens, le poids de ces arguments ne peut que croître.

12. Voir Luc Rouban, La fonction publique, La Découverte, 3e édition, 2009

Notions clefs

Notion	Définition
Fonction publique	Ensemble du personnel permanent de l'État et des collectivités territoriales. Ces derniers sont classés en catégories relevant de régimes juridiques divers.
Statut général de la fonction publique	Cadre légal fixant les conditions d'accès et d'évolution de l'ensemble des fonctionnaires et personnels assimilés. Ce cadre juridique fixe les droits et les obligations des agents publics.
Principe de neutralité	En tant qu'agent au service de l'intérêt général, le fonctionnaire doit respecter une obligation de neutralité, à la fois, vis-à-vis des autorités politiques qui peuvent se succéder à la tête de l'État, et vis-à-vis des administrés (renvoie également à la notion de laïcité).
Grades et échelons	Système d'avancement généralisé à l'ensemble de la fonction publique par le statut général. Chaque grade comporte plusieurs échelons qui déterminent la grille indiciaire de l'agent. Si l'évolution au sein des échelons se fait de droit, il n'en est pas de même pour le changement de grade qui dépend d'une décision hiérarchique.
Bureaucratization	Phénomène lié à la croissance d'une structure et qui aboutit la mise en place de procédures fixes visant à assurer la soumission de l'action des différents services aux règles de droit. Désigne également une dérive qui tend à l'auto-nomie de ces mêmes services.

À retenir

La pression croissante de la soumission aux impératifs juridiques, mais aussi, la diversification de son action vont contribuer à développer une inflexion « weberienne » de l'appareil administratif. La volonté d'écarter toute forme d'arbitraire et la nécessité de répondre à des besoins plus importants et plus variés imposeront ainsi la professionnalisation des agents de la fonction publique. Entérinée à la Libération par la mise en place d'un statut général de la fonction publique (complété par la suite à l'occasion de la mise en place de la décentralisation), cette vision bureaucratique va maintenir une hiérarchisation des personnels. Titulaires de droits et de devoirs, le fonctionnaire se veut désormais un agent neutre de la mise en œuvre de l'intérêt général. Il reste, malgré tout, le maillon d'une chaîne de commandement et doit permettre le passage de l'expression de la volonté générale à son application concrète.

TITRE 2. L'action administrative

Pour avoir une approche globale de l'entité administrative, il convient évidemment de compéter la représentation de ses principes architecturaux par la description de ceux régissant ses mécanismes internes de décision. En effet, l'administration n'est pas qu'un simple outil au service de la décision politique. En tant qu'ensemble institutionnel, des équilibres particuliers se mettent en place pour que des critères de détermination de son action, nécessairement multiples et reliés, s'élaborent.

De la même manière qu'il n'est pas possible de comprendre le fonctionnement d'un appareil politique sans appréhender les relations entre ses composantes, une vision limitée à la structure de l'administration serait donc tronquée. Évidemment, les deux notions (cadre et action) ne peuvent être séparées. L'institutionnalisation permet l'action comme l'action légitime l'institutionnalisation. Dès lors, les principes guidant les pratiques administratives ne peuvent être, comme ceux concernant son organisation, qu'au service de l'intérêt général. Tout est censé être orienté, pensé et organisé dans cette direction. La capacité à atteindre cet objectif est alors la boussole de l'activité administrative. Dans cette optique, l'optimisation des modalités de mise en œuvre de l'action de l'administration est une exigence moderne fondamentale (Chapitre 1), que la gestion du personnel doit permettre d'accompagner et même de faciliter (Chapitre 2).



Objectif

- Identifier les éléments d'entrée et de sortie du processus décisionnel administratif.
- Comprendre que garantir l'État de droit nécessite une mise sous contrôle de la chaîne de décision, et a pour corollaire une certaine forme de complexité qui paradoxalement peut apparaître comme de l'absence de transparence.

Toute action administrative s'inscrit nécessairement dans une logique qui la dépasse. Cela est lié au sens même des missions de l'administration. Soumises à l'État de droit et à l'intérêt général, les décisions administratives doivent s'intégrer par nature dans une logique juridique et sociale contraignante.

L'organisation décisionnelle de l'administration est le reflet de cette double nécessité. Elle se caractérise par un cadre strictement délimité dont elle doit garantir la cohérence (Section 1), mais aussi l'efficacité (Section 2).

SECTION 1. L'exigence de cohérence

La logique de mise en œuvre de l'action administrative doit garantir sa nécessité. L'État, et donc l'administration, ne doit intervenir dans le champ social que si cela est nécessaire à l'intérêt général. L'objectif ici doit être d'assurer au citoyen qu'il ne se trouve pas soumis à l'arbitraire. C'est ainsi que se sont mis en place, et développés, de véritables systèmes procéduraux (1) qui engendrent une forme de sectorisation institutionnelle (2).

1. La systématisation de la décision

Un processus décisionnel, qu'engendre nécessairement l'institutionnalisation, est par nature la résultante d'un ensemble complexe d'interactions qui vont permettre à la « machine institutionnelle » de se mouvoir. Dans ce cadre, une décision administrative ne peut jamais constituer un acte isolé. Ainsi, si sa nature juridique permet de l'identifier et donc de l'isoler, elle ne retranscrit pas pour autant la totalité des forces qui l'ont produite.

Ainsi peut-on décrire le processus décisionnel comme une forme de cheminement encadré, où la collaboration des structures compétentes (1A) produit une réponse standardisée (1B).

1A. La multiplicité des acteurs

L'État de droit, engendré par la souveraineté nationale, implique nécessairement que les gouvernants fixent les modalités et les objectifs des décisions administratives. À ce titre, c'est le pouvoir exécutif qui est en charge de la gestion administrative depuis la période napoléonienne. Aujourd'hui l'article 20 alinéa 2 de la constitution de 1958 précise : « Il (le gouvernement) dispose de l'administration et de la force armée ». Un ministère est donc un lieu où se rencontrent (symboliquement et physiquement) le politique et l'administratif. Un ministre est d'ailleurs, depuis l'Ancien régime, à la fois un acteur politique et le gestionnaire d'une administration placée sous son autorité. De plus, depuis l'instauration de la démocratie représentative, il est comptable devant la représentation nationale de sa gestion (en général c'est le gouvernement qui assume collectivement la responsabilité des politiques menées. Il convient de noter que ce schéma n'est valable que dans le cadre d'un régime parlementaire où est mise en place une séparation souple des pouvoirs).

Afin de préciser aux administrations leurs missions, des décrets répartissent les attributions du gouvernement entre les ministres. Aux termes du décret du 22 janvier 1959 : « Les attributions des ministres sont fixées par décrets délibérés en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État ». Ces décrets d'attribution distinguent :

1. les administrations sur lesquelles le ministre a autorité,
2. celles sur lesquelles le ministre a autorité conjointement avec un ou un (des) autre(s) ministre(s),
3. celles placées sous l'autorité d'autres ministères mais dont un ministre « dispose » pour l'exercice de ses attributions (il n'est pas le supérieur hiérarchique de ces agents), et enfin,
4. celles auxquelles le ministre peut faire « appel » (pas possible de donner des instructions).

Aux côtés du ministre, on va retrouver des collaborateurs librement choisis par le ministre (nommés par arrêtés publiés au JO) qui vont l'accompagner pour accroître la pertinence de son action, formant son « cabinet » (cette liberté du ministre est relative et dépend souvent de son poids politique dans la majorité). En général, on retrouve dans ces équipes ministérielles un directeur de cabinet (qui dirige l'action du ministère et organise son fonctionnement), un chef de cabinet (en charge de l'agenda politique ministériel) et des conseillers (chargés de mission) qui vont se voir attribuer des tâches spécifiques. Le décret du 18 mai 2017 fixe à dix maximum les effectifs du cabinet de chaque ministre (ce nombre peut être dépassé en raison de la création de structures de missions rattachées à un cabinet). Le ministre du budget informe chaque année le Parlement du nombre de membres des cabinets. C'est ensuite le ministre qui propose le décret d'organisation de son ministère. Celui-ci doit décrire comment seront réparties les différentes directions générales des administrations dont il a la charge. Il existe trois hypothèses :

- un schéma à direction générale unique ;
- un schéma à plusieurs directions générales sans directions subordonnées ;
- un schéma à plusieurs directions générales avec directions subordonnées.

Dans la logique hiérarchique de l'administration, ce centre hybride va communiquer aux services placés sous son autorité leurs missions et en surveiller la mise en œuvre par un jeu de délégation de pouvoirs (les administrations territoriales se voyant placées sous la responsabilité de leurs exécutifs locaux dans une logique identique). L'ensemble de ces éléments constituent les « acteurs administratifs » qui peuvent influencer sur la nature de la décision administrative. Leurs relations sont formalisées et soumises à des étapes successives (étude, concertation, décision) qui laissent la place à des échanges souvent plus verticaux que transversaux (il s'agit d'une conséquence de la forte sectorisation des politiques publiques).

Une fois les choix effectués, depuis le centre, il convient d'assurer la cohérence de leur mise en œuvre. *Par définition, la décision centrale ne peut être que générale et est incapable de répondre a priori à la diversité de la réalité sociale.* C'est ici qu'un travail de concertation devant intégrer l'ensemble des structures concernées doit intervenir. Il a vocation à préserver à la fois l'intégrité de la volonté politique et l'uniformité de l'action administrative. Réalisé sous forme de commissions, de réunions ou de simples échanges, il intervient à la fois lors de l'initiative, avec un rôle d'impulsion, et lors de l'application, avec un rôle de contrôle.

Cette boucle tend à éloigner l'utilisateur de la décision administrative. En effet, à la fois fermée et complexe, elle rend parfois difficile la compréhension des motifs de l'administration. Pour répondre à ces difficultés, l'appareil administratif tend depuis plusieurs années à ouvrir ses procédures décisionnelles. Tout d'abord, il cherche à davantage intégrer l'expertise privée (solicitation de cabinets d'audits ou d'experts, présence d'extérieurs dans des commissions de sélection...) afin de mieux collaborer avec son environnement socio-professionnel (notion d'État acteur social lié à l'« État-providence »). Mais l'administration souhaite aussi améliorer sa communication avec ses usagers. Elle cherche par ce biais à renforcer sa légitimité (de plus en plus contestée) par la proximité (aspiration à la transparence et à la participation citoyenne). On assiste ainsi depuis plusieurs années au développement de la présence des usagers (par le biais de représentants) dans de nombreuses structures décisionnelles ou consultatives publiques (commissions d'attributions de droits aux personnes handicapées, conseils d'administration d'hôpitaux...).

Ce contact, sur lequel peut s'appuyer l'agent d'exécution, contribue à faire évoluer les rapports internes en contrebalançant l'habituel système hiérarchique, sans pour autant le remettre en cause.

1B. Une interaction hiérarchisée

Dans cet ensemble, de plus en plus complexe et hétérogène, la cohésion du système décisionnel est assurée par l'affirmation de la hiérarchisation des rapports entre ces différents acteurs. Ceux-ci ne sont pas indifférenciés, mais, au contraire, jouent un rôle fixé a priori par le cadre légal. Ainsi l'ordre hiérarchique répond-il à l'ordre juridique. La hiérarchie dans l'administration s'affirmera avec Napoléon à la fin de la Révolution lorsque l'on mettra fin à l'élection généralisée des fonctions publiques.

Tout d'abord, les acteurs de la décision publique sont donc hiérarchisés quant à leur positionnement institutionnel. Le pouvoir, attribué au titre, fournit à son titulaire son autorité hiérarchique. Dès lors, comme le dit le professeur Lochak :

« La hiérarchie n'est pas simplement un principe d'organisation ; elle correspond à un certain vécu de la part des agents, dont elle imprègne et détermine les attitudes et les comportements »¹³.

13. Danièle Lochak, « Le sens hiérarchique », in Psychologie et science administrative, Paris, PUF, 1985, p. 147

Ce « sens hiérarchique » contribue ainsi à encadrer les rapports personnels au sein de l'entité bureaucratique. En pratique, un agent appliquera donc davantage une décision parce qu'elle a été validée par son supérieur hiérarchique que par la valeur juridique du texte originel. D'ailleurs, il y trouve un intérêt personnel puisque, dans la fonction publique, c'est davantage de la décision du supérieur que de ses résultats dont dépend l'évolution de la carrière d'un agent (évolution de grades, primes...). Ainsi le statut lui-même, principale garantie du fonctionnaire, affirme-t-il dans l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :

« Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».

Cet article, tout en offrant une protection au fonctionnaire contre l'abus hiérarchique, renforce incidemment le principe général. Le terme « manifestement illégal » caractérise, en effet, la limitation du pouvoir d'interprétation du subordonné renvoyant à la domination du supérieur. Ce principe montre que le fonctionnaire n'est pas totalement cantonné à une mission d'obéissance mécanique mais doit aussi analyser sa tâche en contexte, c'est pourquoi ce principe est appelé celui des « baïonnettes intelligentes ».

Cette hiérarchisation peut apparaître comme essentiellement valorisante pour les strates les plus élevées de l'administration (la multiplication des textes et la complexification qu'elle engendre sont même parfois interprétées comme une conséquence de la volonté permanente d'incarner une forme de domination au sein de l'organisation)¹⁴. En réalité, elle s'imprègne au sein de l'intégralité des ressources humaines publiques. Non seulement elle se renforce avec les agents intermédiaires (subordonnés d'un côté, et supérieurs d'un autre, le zèle à appliquer l'ordre descendant se consolide, voire se fortifie chez eux), mais elle permet aussi à chacun de se percevoir comme un représentant de la puissance publique.

Malgré tout, si le principe hiérarchique, légal et comportemental, contribue à assurer la cohérence et l'efficacité d'ensemble du système, il nuit également parfois à son fonctionnement. En effet, il favorise la déresponsabilisation et limite l'innovation des agents.

2. La fragmentation de la décision

La bureaucratisation wébérienne implique une forme de division du travail. Ainsi la décision administrative est-elle éclatée en une suite d'épisodes. Ces derniers fragmentent le mouvement administratif aussi bien dans son organisation (2A) que dans sa temporalité (2B).

2A. La fragmentation matérielle

De la même manière qu'il existe une pluralité d'acteurs hiérarchisés, la décision administrative est multiple et parfois même plurivoque. En tant que résultante d'un jeu d'interactions entre les différents intervenants associés à sa formation, elle est plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. À ce titre, elle constitue un ensemble de liens permettant de basculer de la préparation à l'exécution, de la réflexion à l'action.

Pour autant, on ne peut isoler dans la pratique ces différents éléments qui s'enchevêtrent. Une multitude d'actions anticipatrices ou rétroactives viennent complexifier l'ordonnancement de la procédure juridique. Ainsi la décision doit-elle prendre en compte non seulement les résultats de sa préparation mais également anticiper ses effets. Elle ne suit donc pas systématiquement un courant linéaire, mais est susceptible d'allers-retours entre l'amont et l'aval et entre le centre et la périphérie.

L'enchevêtrement territorial de l'administration étatique, ou encore les incertitudes de compétences entre les administrations décentralisées, contribue encore à complexifier ces processus (voir ci-dessous).

Dans cette optique, il peut apparaître extrêmement complexe d'identifier la décision et de dissocier hermétiquement chacune des étapes et donc, pour l'administré ou l'utilisateur, de comprendre sa légitimité. Ainsi, alors même que cette diversité d'intervenants a vocation à offrir davantage de garanties du respect des droits individuels, elle apparaît fréquemment aux yeux des administrés comme un facteur, au mieux, superfétatoire et, au pire, perturbateur.

14. P. Legendre, *Jouer du pouvoir*, Minuit, 1976, pp. 175-176

Intervenant pour répondre à une requête, à un besoin, dénouer un conflit ou encore pour mettre fin à un abus, la décision administrative s'avère donc souvent beaucoup plus complexe que ne le laisse penser sa simple caractérisation juridique. Qui plus est, une décision s'intègre souvent dans un historique juridico-administratif. Elle renvoie potentiellement à d'autres décisions qui la devancent, l'orientent ou la lient.

Dans cette logique, elle ne peut être considérée comme un aboutissement et une fin. Elle n'est qu'une étape, elle-même complexe, d'un processus décisionnel permanent qui la rattache à l'administration en général (en tant qu'instrument de régulation sociale). Or, si sa localisation est moins identifiable qu'il n'y paraît aux premiers abords, sa temporalité répond elle aussi à une logique complexe et divisée.

2B. La fragmentation temporelle

Si la décision administrative est éclatée d'un point de vue matériel, en raison de la pluralité d'acteurs intervenant dans son élaboration, son application ou son contrôle, le sont nécessairement d'un point de vue temporel.

Du pouvoir politique, initiateur des orientations et des cadres de l'action publique à travers l'exercice de la souveraineté, jusqu'à l'agent public exécutant pratique des actions administratives, il existe nécessairement un temps administratif permettant la circulation de la volonté nationale de haut de la pyramide jusqu'à sa base.

Chacune des phases décisionnelles (élaboration, application, contrôle) fait l'objet d'un propre cheminement. Celui-ci est hiérarchique (consultation de son supérieur et validation) mais aussi horizontal (sectoriel ou transversal). Ce parcours n'est donc ni linéaire ni totalement prédictible. Délimité par le cadre juridique, il permet un jeu d'influences et même souvent de rapports de force internes à l'administration où les relations hiérarchiques et sectorielles jouent un rôle majeur. La collaboration / confrontation s'y épanouit souvent de manière plus aléatoire que l'ordonnancement institutionnel le laisse penser. L'informel et les rapports personnels, que la bureaucratisation cherche à éviter afin d'évacuer l'arbitraire, joue ici un rôle fondamental et contribue à maintenir une part d'aléatoire dans les comportements administratifs. Régulée par le droit, l'administration se présente comme une organisation spécifique mais qui, comme toutes structures humaines, ne peut fonctionner sans cette partie informelle¹⁵.

Cet aléa n'est d'ailleurs pas nécessairement attentatoire à l'intérêt général.

Dans la limite du respect des procédures décisionnelles, il peut même contribuer à le renforcer grâce à une meilleure prise en compte du réel. À ce titre, il constitue un élément pratique d'atténuation de la hiérarchisation théorique des rapports entre les différents agents de l'administration.

D'ailleurs, cette part d'informel se retrouve également dans les relations externes de l'organisation administrative. Si les échanges avec les administrés sont souvent encadrés par des procédures fixes déterminées par le droit (accusé de réception d'une demande, recueil d'informations, traitement, transmission...) qui assigne à chaque étape des délais (à noter que depuis la loi du 12 novembre 2013 habilitant à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, le silence gardé par l'administration sur une demande vaut acceptation), eux aussi laissent fréquemment une place à une approche plus informelle. Celle-ci peut permettre d'améliorer l'échange entre le général et le particulier, et donc la qualité du service produit par l'administration.

15. Sur ce point, voir F.G. Farris, « The informal organisation in strategic decision making », in *International Studies in Management and Organisation*, n° 9, pp. 37-62

Notions clefs

Notion	Définition
Ministère	Groupe de services placés sous la direction d'un ministre nommé par le pouvoir exécutif selon une classification thématique libre (affaires étrangères, intérieur, éducation...). Chaque ministère est composé d'un cabinet, d'une administration centrale et de services déconcentrés (appelés jusqu'en 1992 « services extérieurs ») situés dans les diverses circonscriptions.
Hierarchisation des agents publics	Au sein de la fonction publique, les différents acteurs voient leurs relations hiérarchisées. Chacun a vocation à jouer un rôle déterminé par les conditions de son entrée (concours de catégorie A, B ou C) et par son statut. Ce dernier impose à tout agent une obéissance conditionnée envers son supérieur hiérarchique.
Décision administrative	Terme qui désigne un acte administratif unilatéral. Ce dernier est un acte, qui une fois devenu exécutoire, fait grief en modifiant l'ordre juridique préexistant. Il est présumé légal mais peut faire l'objet d'un recours d'un administré si ce dernier l'estime contraire à la pyramide des normes.
Délai administratif	Temps dont dispose l'administration pour répondre à une situation ou à une demande d'un administré. Ce dernier permet à la structure de mettre en place des procédures décisionnelles horizontales et verticales devant à la fois permettre la pertinence et la légalité de la décision rendue.
Formel / informel	Dans le cadre du fonctionnement administratif, la prise de décision est réglementée par une procédure hiérarchique fixée par un cadre légal. Cette démarche bureaucratique n'est cependant pas exclusive et laisse la place à des échanges moins formatés que l'on qualifie généralement d'informels.

À retenir

À partir de la fin du XIX^e siècle, la soumission de l'administration à l'État de droit a engendré le développement d'une logique « wébérienne » en son sein. Pour éviter de retomber dans l'arbitraire d'Ancien régime, l'administration républicaine a ainsi formalisé divers outils devant rendre son action légitime, et donc conforme aux règles de droit préétablies. C'est ainsi qu'un système hiérarchique de relations entre une pluralité d'acteurs s'est progressivement mis en place comme cadre de l'action publique. En rationalisant ainsi les comportements administratifs, en cherchant même à les « objectiviser », les représentants politiques ont été amenés à façonner progressivement des processus d'action administrative fragmentés aussi bien matériellement que temporellement. En ont découlé, au grand dam des administrés, complexités et lenteurs qui constituent une sorte de « revers de la médaille » de la garantie de l'État de droit.

SECTION 2. Le contrôle comme garantie d'efficacité



Objectif

- « La confiance n'empêche pas le contrôle »
- Connaître les types de contrôles et de recours administratifs.

La question d'un contrôle de l'action administrative est centrale dans la mise en œuvre de l'État de droit. En effet, la soumission au droit des structures publiques est indissociable d'une exigence de vérification. Or, s'il appartient en bout de chaîne au juge administratif d'effectuer cette tâche, des systèmes de contrôle non-juridictionnels ont également été mis en place. Ils ont évidemment vocation, comme le juge, à renforcer les garanties du respect de la légalité, mais aussi plus largement à vérifier la pertinence et l'efficacité de l'action publique. Ces contrôles non-juridictionnels s'opèrent tant au niveau externe (1) qu'au niveau interne (2).

1. Le contrôle externe

Le maintien de l'emprise politique sur la bureaucratie administrative est une nécessité démocratique. L'administration étant au service de l'intérêt général, elle est comptable de son action devant la représentation de la souveraineté nationale (ou locale dans le cas des administrations territoriales). Ce contrôle donnera des résultats qui permettront une évaluation. Celle-ci fera intervenir des acteurs extérieurs à l'administration, au nom du principe d'équilibre des pouvoirs (1A). Cette démarche tend à rechercher l'optimisation de l'action publique (1B).

1A. Les acteurs du contrôle externe

Si, comme nous l'avons vu précédemment, c'est le gouvernement qui « dispose de l'administration » selon l'article 20 de notre constitution, la responsabilité de son contrôle ne peut lui incomber. En ce sens, la notion de contrôle ne réside pas dans le pouvoir de commandement possédé sur le sujet mais dans la capacité à lui demander des informations et à évaluer son action. Cette prérogative, facteur de limitation, ne peut être, dans la double logique de la notion de séparation des pouvoirs (équilibre et contrôle), qu'un attribut d'un autre pouvoir, en l'occurrence le législatif (article 24 alinéa 1 de la Constitution de 1958 : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques »). C'est donc aux parlementaires qu'il revient de superviser l'activité administrative, prioritairement à travers le vote du budget (fondamental pour toute action publique qui par nature nécessite une dépense publique).

Mais il peut également exercer un contrôle plus ciblé et concret. Celui-ci va s'incarner, soit avec des commissions d'enquête parlementaires (article 51-2 de la Constitution de 1958), soit par le biais de délégations parlementaires (créées par la loi) qui ont un caractère de permanence (on peut citer par exemple la délégation parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes créée par la loi n° 99-585 du 12 juillet 1999 et plus récemment la Conférence des présidents a créé, le 17 juillet 2012, la délégation aux Outre-mer qui a été consacrée par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, puis le 28 novembre 2017, la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation).

Pour assister le Parlement dans cette mission centrale, mais aussi le gouvernement dans sa gestion, figure également comme instrument de contrôle extérieur à la hiérarchie administrative la Cour des comptes. Juridiction de l'ordre administratif, elle est chargée de contrôler les comptes publics (État, établissements et entreprises publics, organismes de sécurité sociale). Elle est complétée par des chambres régionales chargées du contrôle de la boucle institutionnelle décentralisée. Son indépendance, garantie institutionnellement et statutairement, est renforcée par l'usage de désignation par les Présidents de la République d'un Président issu de l'opposition parlementaire. Contrepartie de cette soustraction à l'ordre administratif, ses rapports ne possèdent pas de caractère contraignant mais bénéficient de leur publicité pour exercer une pression sur les autorités par le biais de l'opinion publique.

1B. Le développement de l'évaluation des politiques publiques

L'évaluation des actions administratives est opérée par les acteurs institutionnels qui viennent d'être évoqués. Il s'agit essentiellement d'un contrôle d'opportunité qui vise à contrôler la bonne gestion gouvernementale des affaires administratives et mettre fin aux dysfonctionnements potentiels. Elle se présente alors comme un instrument de bonne gouvernance qui ne vise pas la sanction (rôle de la hiérarchie et / ou du juge) mais la réorientation de l'action publique.

D'après l'article 1er du décret n° 90-82 du 22 janvier 1990 relatif à l'évaluation des politiques publiques :

« L'évaluation d'une politique publique [...] a pour objet de rechercher si les moyens juridiques, administratifs ou financiers mis en œuvre permettent de produire les effets attendus de cette politique et d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés ».

Sont ainsi évaluées la pertinence, l'efficacité, l'utilité ou encore la durabilité de l'action menée.

Ce contrôle de bonne gestion des deniers publics constitue un instrument de gouvernance moderne, soucieuse de son efficacité au nom de l'optimisation des dépenses publiques. Cette approche, ancienne dans les pays anglo-saxons (où l'on évoque la notion d'« accountability » qui signifie à la fois être responsable juridiquement et comptable financièrement de son action) est plus récente dans notre pays. Favorisée par les difficultés budgétaires, elle s'est systématisée en France depuis l'adoption de la loi organique relative aux lois de finances de 2001 (LOLF), qui débouchera ensuite sur la réforme générale des politiques publiques (RGPP) et désormais la modernisation de l'action publique (MAP) et depuis octobre 2017 un programme spécifique « action publique 2022 ». Ces éléments traduisent un basculement de la légitimité de l'action de l'État engendré par l'approfondissement individualiste de nos sociétés modernes. *La soumission des gouvernés aux gouvernants s'incarne donc de moins en moins dans une logique de transcendance mais plutôt d'efficacité.* Le service public a pris le pas sur la puissance publique. La décision et l'action publiques sont ainsi appréhendées d'un point de vue plus utilitariste. C'est leur pertinence qui les valide davantage que l'autorité de son auteur. L'intérêt général n'apparaît plus alors comme un espace collectif supérieur mais comme le vecteur d'une somme d'intérêts particuliers (atténuation de la vision française traditionnelle rousseauiste pour une vision plus « utilitariste » proche du modèle anglo-saxon). Il faut ajouter ici l'influence de l'intégration européenne qui tend à progressivement éroder les particularités nationales au profit de l'uniformité européenne (en la matière, l'attribution de fonds européens, dont l'utilisation est contrôlée par les institutions de l'UE, a aussi joué un rôle dans cette évolution en exigeant des administrations une telle démarche d'évaluation).

2. Le contrôle interne

Au contrôle parlementaire des politiques publiques, s'ajoute au sein même de l'administration un contrôle de légalité administratif des actes qui découlent de ces politiques (2A), auquel se superpose un contrôle financier (2B).

2A. La permanence du contrôle de légalité

L'objectif est ici la cohérence de l'action collective et la garantie des droits particuliers. L'approche est donc nécessairement plus juridique puisqu'elle doit se faire par rapport à l'ordonnement du droit français (et européen). Il est donc moins question ici de pertinence ou d'efficacité mais plutôt de régularité et de conformité. Si cette mission de contrôle revient évidemment au juge administratif, l'administration active peut elle aussi constater et sanctionner l'illégalité.

Ce contrôle est d'ailleurs en premier lieu opéré par l'agent qui a pris une décision ou par son supérieur hiérarchique. L'acte peut alors être revu soit par le biais d'une abrogation (plus d'effets dans l'avenir) soit d'un retrait (effet rétroactif). Cette procédure peut être spontanée (cas du contrôle de légalité préfectoral sur les collectivités territoriales) ou le fruit d'un recours d'un administré qui, logiquement, peut s'adresser au supérieur (recours hiérarchique) ou à l'agent lui-même (recours gracieux). Il peut porter sur tous types d'actes, qu'ils soient explicites ou implicites. Instruments de dialogue entre l'administration et la société civile, ces recours ne sont pas soumis aux mêmes règles de forme que les recours contentieux (devant le juge administratif) et ne lient absolument pas le juge si un recours contentieux s'engage par la suite.

Cette possibilité est très ancienne et a même longtemps constitué la seule voie de recours pour les administrés (voir ci-dessus)¹⁶. À ce titre, l'apparition d'un véritable recours contentieux (permis par la reconnaissance de l'indépendance hiérarchique du magistrat administratif) va contribuer à rééquilibrer les rapports entre

16. 1. Partie 1, chapitre 1, section 2, §1, B

l'administration et ses administrés. Dès lors, elle va avoir une incidence sur le recours gracieux. Celui-ci sera désormais moins marqué par la domination de la puissance publique appuyée sur l'intérêt général. Ainsi, pendant longtemps l'administré qui formait une telle demande se trouvait en position d'infériorité, soumis et dépendant du bon vouloir administratif. Désormais, le recours gracieux constitue davantage un lieu d'échanges, voire de négociations, préalables à un hypothétique affrontement juridique (le délai du recours gracieux, 2 mois, prorogeant celui du contentieux). Cette profonde mutation des rapports entre gouvernants et gouvernés incarne l'une des inflexions de « l'État-gendarme » vers « l'État-providence ».

Enfin une dernière structure de contrôle de conformité des comportements administratifs aux normes les encadrant se trouve dans les corps d'inspection. Ces derniers sont scindés entre trois inspections générales interministérielles (inspection générale des finances, de l'administration, des affaires sociales) d'un côté ; et les inspections générales ministérielles d'un autre (il existe une vingtaine de ces corps d'inspection, dont certains sont bien connus, comme l'Inspection générale des affaires étrangères, l'Inspection générale de la justice, l'inspection générale des armées, l'inspection générale de la police nationale...).

Quels qu'ils soient, ces corps d'inspection, placés sous l'autorité d'un ministre, ont la charge de vérifier le bon fonctionnement des services relevant de ce dernier. À ce titre, ils contribuent à proposer au gouvernement des réformes dans leur secteur, à en fixer l'économie et à sensibiliser l'opinion publique à leur nécessité. Leur approche dépasse le seul contrôle de légalité et porte également sur le respect des instructions et normes techniques (à travers des audits). Ces structures disposent d'un pouvoir de sanction mais peuvent également opérer des enquêtes générales ou des diagnostics de dysfonctionnements particuliers (production de rapports), voire proposer des solutions aux organes concernés (rôle de conseil). Leur approche dépasse le seul contrôle de légalité et porte également sur le respect des instructions et normes techniques (à travers des audits). Ces structures disposent d'un pouvoir de sanction mais peuvent également opérer des enquêtes générales ou des diagnostics de dysfonctionnements particuliers (production de rapports), voire proposer des solutions aux organes concernés (rôle de conseil).

Composés de hauts fonctionnaires sortis essentiellement des grandes écoles (Ponts-et-chaussées, ENA...), ces corps sont également présents dans la gestion administrative publique. Ainsi, on les retrouve dans le fonctionnement des ressources humaines (participation à des jurys de recrutement ou encore aux procédures disciplinaires).

2B. Le contrôle financier

Le contrôle financier administratif interne constitue un aspect particulier, mais fondamental, du contrôle administratif. Il a ainsi vocation à contrôler le respect des règles comptables et financières dans l'ensemble du domaine public.

L'origine de la systématisation de ce contrôle remonte véritablement à la promulgation le 1^{er} août 2001 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), déjà évoquée précédemment (et complétée par le décret du 27 janvier 2005). En large partie inspirée des principes de la nouvelle gestion publique (voir ci-dessous), cette norme fixe un cadre financier général inscrit dans une logique de performance et de transparence. Ainsi, elle a cherché à préciser (dans une volonté d'optimisation de l'action publique) la répartition des compétences dans les services de l'administration publique en s'appuyant notamment sur une séparation plus nette entre les ordonnateurs et les comptables (le principe était déjà inscrit dans l'article 20 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique).

D'un côté l'ordonnateur doit donc ordonner la dépense en signant un engagement juridique avant de le constater et donc le liquider en certifiant le service fait. D'un autre côté, le comptable doit intervenir en réservant les fonds au moment de l'engagement et en les débloquant après la liquidation pour permettre le paiement. Ce principe de séparation se justifie par une exigence en matière de sécurité de gestion des fonds publics permettant de distinguer la décision de son opération comptable et financière.

Le contrôle du respect de cet ordonnancement, qui s'impose à toutes les structures publiques (administration d'État, des collectivités territoriales, des établissements publics...), est assuré par différents acteurs en fonction du cadre concerné (au nom de l'autonomie des personnes morales extérieures à l'État central). Ce sont ainsi les contrôleurs budgétaires de Bercy qui traitent l'activité des services centraux alors que les services déconcentrés sont placés sous la compétence des trésoriers- payeurs généraux de région. Quant aux services décentralisés, ils voient leurs finances contrôlées par les Chambres régionales des comptes et leurs magistrats indépendants. Enfin, les établissements publics sont soumis à la supervision financière du contrôle général économique et financier (CGEFI).

Quel que soit l'organe contrôleur ou contrôlé, l'ensemble de cette armature vise à renforcer la performance de l'action publique via une optimisation des finances publiques. Cette question est ainsi devenue fondamentale pour « l'État-providence » dont la qualité et la légitimité du service dépendra, aux yeux de l'utilisateur/administré, de sa capacité à atteindre ses objectifs (introduction de la culture du résultat aux dépens de la culture hiérarchique). Dans cette optique, la réforme de l'approche budgétaire s'est présentée comme un levier de la modernisation de l'action publique. Cependant, la recherche de performance ne pouvant être que globale, la volonté de modernisation de l'action publique devait également toucher à la gestion des personnels.

Notions clefs

Notion	Définition
Contrôle de légalité / d'opportunité	Le contrôle d'opportunité s'exerce au sein d'une personne morale de droit public par l'autorité hiérarchique afin de vérifier la pertinence de la décision au regard de l'intérêt général. Le contrôle de légalité (effectué in fine par le juge administratif) permet de veiller au bon ordre de l'ensemble du corpus juridique.
Cour des comptes	Juridiction administrative, soumise au contrôle du Conseil d'État, chargée d'exercer un contrôle financier de l'État et de ses établissements publics, de la Sécurité sociale et d'organismes bénéficiant du concours financier de l'État. Les collectivités territoriales sont, quant à elles, soumises au contrôle des Chambres régionales des comptes.
Évaluation des politiques publiques	Évaluer une politique publique consiste à mesurer l'efficacité de l'action publique à l'aide d'indicateurs de performance afin d'en mesurer la pertinence. Outil privilégié de la réforme de l'État, cette démarche s'est largement développée au cours des vingt dernières années.
Recours gracieux / hiérarchique	Toute décision administrative, qu'elle soit explicite ou implicite, peut faire l'objet d'un recours par un administré concerné. Le recours gracieux s'adresse alors à l'agent qui a pris la responsabilité de la décision alors que le recours hiérarchique s'adresse au supérieur hiérarchique de l'auteur de la décision. On les distingue généralement du recours contentieux réalisé devant un juge.
LOLF	La loi organique relative aux lois de finances promulguée en 2001 et entrée en vigueur progressivement entre 2002 et 2006 constitue le fondement d'une nouvelle organisation des budgets publics. Qualifiée par certains de véritable « constitution financière » elle a ainsi contribué à placer la performance au cœur de l'activité administrative dans le cadre d'une volonté de modernisation de l'action publique.

À retenir

Dans la quête vers une plus grande efficacité de l'action publique, l'administration a été soumise à un nombre croissant d'outils de contrôle. Ces derniers peuvent être internes, ou externes, à l'organisation de l'administration active. Quelles que soient leurs formes, ils ont vocation à inscrire l'action de l'administration dans une logique de bonne gestion démocratique. Complémentaires, ils visent ainsi à garantir aux administrés / citoyens le respect des libertés individuelles mais aussi la bonne utilisation des fonds publics. Ainsi, au traditionnel contrôle de légalité (appréhendé au sens large), s'est ajoutée depuis quelques décennies, une évaluation des politiques publiques. Se transmettant par le jeu hiérarchique, cette vision « utilitariste » de l'administration s'est propagée dans toutes les strates de la machine administrative.

CHAPITRE 2 La réforme du management public au service de l'efficacité de l'action administrative



Objectif

- Appréhender les conséquences du développement de la notion de performance au sein de l'administration.
- Comprendre les raisons du maintien d'un certain particularisme de l'organisation publique.

L'enracinement de la quête de performance au sein de l'administration est consubstantiel à la crise de l'« État-providence ». Celle-ci étant essentiellement d'ordre financier (cf. chocs pétroliers des années soixante-dix), la quête d'un meilleur « rendement » de la production de services publics a constitué la réponse politique la plus répandue au sein des démocraties occidentales. Or, cette nouvelle inclinaison s'est exprimée de manière particulièrement visible dans la gestion du personnel public. Le « New Public Management », puis le « post-NPM », sont progressivement devenus les piliers d'une action publique plus « responsable ». Ainsi, par exemple, le programme « Action publique 2022 » détermine cinq « chantiers » interministériels jugés comme prioritaires : simplification et amélioration de la qualité des services, rénovation du cadre des ressources humaines, transformation numérique, modernisation de la gestion budgétaire et comptable et organisation territoriale des services publics.

Les effets les plus visibles de cette inclinaison de la gestion administrative se sont matérialisés dans un renforcement de la flexibilité de l'appareil administratif (Section 1). Cette rénovation n'a pas pour autant permis de rompre avec certaines caractéristiques historiques dans ce domaine (Section 2).

SECTION 1. La volonté de décroisement

La recherche d'une plus grande flexibilité managériale est un corollaire indispensable à un renforcement de l'efficacité administrative. C'est même le principal levier offert par le cadre juridique. Pour assurer une telle évolution, il a fallu d'abord mettre en place une politique des ressources humaines plus affirmée permettant d'infléchir les rigueurs statutaires hiérarchiques (1). Cette première étape a alors contribué à l'introduction de critères de performance originellement absents (2).

1. Le développement d'une véritable politique des ressources humaines

Le « bureaucratisme » a fait l'objet, depuis ses origines, des plus vives critiques (voir le roman de Balzac Les employés ou la femme supérieure publié en 1838). L'insistance qu'il engendre sur la soumission hiérarchique et la dépersonnalisation entraînerait une rigidité excessive de l'ensemble de l'appareil et une forme d'apathie chez des agents déresponsabilisés. Pour autant, il faudra attendre les difficultés financières de la fin des « Trente glorieuses » pour qu'un véritable vent de réforme souffle sur l'administration française (1A) et répande de nouveaux préceptes managériaux (1B).

1A. La quête réformatrice : la modernisation de l'administration

Depuis son implantation définitive au début du XX^e siècle, le système bureaucratique administratif a fait l'objet de multiples projets de réformes. Les revendications décentralisatrices, planificatrices ou encore démocratiques, remettaient toutes en cause ce modèle assimilé à une « maladie administrative » nécessitant un traitement de grande ampleur. Alors qu'il avait permis, au XIX^e siècle, la soumission de l'« État-gendarme » au droit, il semblait incapable de répondre aux besoins du nouveau siècle (en particulier sociaux avec l'approfondissement de l'industrialisation).

C'est ainsi que le thème de la réforme administrative est devenu un lieu commun du débat politique dans la seconde partie de la III^e République (en particulier dans l'entre-deux-guerres). Accompagnant les virulentes critiques à l'encontre d'une représentation politique jugée incompétente ou impuissante, la rénovation administrative visait à inscrire la France dans une vaste modernisation de son appareil d'État.

Avec l'émergence de « l'État-providence » à la Libération, quelques évolutions se mirent en place (favorisées par un certain consensus politique et l'immensité des besoins). La reconnaissance du droit syndical, si longtemps rejeté, permit ainsi d'atténuer un carcan hiérarchique hérité des régimes pré-républicains. En outre, la mise en

place (ou le développement) de nouveaux modèles structurels (administrations de mission, sociétés publiques ou d'économie mixte) contribua à renforcer les moyens administratifs et à faire face aux nouvelles sphères d'intervention (aménagement du territoire, tourisme, culture, sport...).

Malgré tout, il s'agissait davantage ici d'inflexions ponctuelles liées à une modification de l'environnement social que d'une remise en cause générale de traditions internes de plus en plus dépassées (passage des théories du gouvernement traditionnel à celle de la « gouvernance », voire de la « bonne gouvernance »¹⁷). Il fallut les difficultés des finances publiques liées à la fin de la période des « Trente glorieuses » pour accélérer ce processus et lancer une véritable démarche réformatrice sur l'autel de la rationalisation des choix budgétaires (RCB). C'est ainsi que les politiques de modernisation administrative des années 1980 constituèrent véritablement un point de rupture systémique. En effet, mises en œuvre progressivement dans l'ensemble des démocraties européennes (en commençant par le Royaume-Uni de Margaret Thatcher pour ensuite gagner l'Allemagne, l'Italie ou encore la France), elles traduisirent une véritable révolution de la philosophie organisationnelle publique.

L'objectif était clair : offrir davantage de capacités d'adaptation à l'administration pour lui permettre d'être plus efficace. Autrement dit, passer d'un management de type vertical et rigide à une organisation plus souple et plus horizontale. La grande différence avec les initiatives passées était qu'il ne s'agissait plus d'une démarche ponctuelle mais véritablement d'une logique d'ensemble. Celle-ci visait à faire passer les administrations dans une nouvelle ère de performance publique, perçue comme indispensable à la survie de « l'État-providence ». Avant même le développement de la mondialisation post-guerre froide, cet aggiornamento consacrait la prise en compte d'un plafonnement des ressources de ces pays confrontés à un environnement de plus en plus ouvert. Il fallait ainsi rapprocher la gestion publique des modèles managériaux privés centrés sur des indicateurs de performance et, évidemment, mettre en place des dispositifs d'évaluation interne (avec comme conséquence une érosion de la spécificité du domaine public et donc une altération de la notion d'intérêt général). Cette évolution s'incarna dans une doctrine globale : la « Nouvelle gestion publique » (dérivée du « New management public » apparu dans les années 1970).

Si ce processus divergea en Europe quant à sa célérité et son intensité, la vision se répandit partout. D'ailleurs, en France, malgré les alternances politiques et les appellations diverses qu'elles ont engendrées, cette recherche d'une meilleure productivité publique s'est maintenue avec une remarquable continuité. Déjà présente dans la « Nouvelle société » de Jacques Chaban-Delmas au début des années 1970, on la retrouve dans la « simplification administrative » voulue par le gouvernement Chirac en 1986, mais aussi dans la fameuse circulaire du 23 février 1989 de Michel Rocard sur le « renouveau du service public » ou encore dans la « Réforme générale des politiques publiques » du gouvernement Fillon en 2007 et de la « Modernisation de l'action publique » du gouvernement Ayrault en 2012. Elle s'est ainsi systématiquement basée sur trois piliers :

- l'ouverture aux administrés (participation, simplification) ;
- la responsabilisation financière des structures administratives (LOLF, autonomie...) ;
- la transformation des rapports internes à travers l'évolution de la gestion des ressources humaines.

1B. L'ouverture de l'administration à de nouveaux principes managériaux

L'inflexion du modèle d'organisation des rapports internes au sein de la fonction publique est liée à une recherche de performance¹⁸. Elle s'inscrit parallèlement dans une volonté globale de raccourcir la distance et de rééquilibrer le rapport avec l'usager. L'enjeu n'est donc plus uniquement dans la conformité mais aussi dans l'efficacité. Dans cette logique, l'approche managériale doit évoluer. Si elle ne peut être la seule réponse, et doit généralement être accompagnée de mesures complémentaires (comme l'amélioration du dialogue et de l'accueil des usagers, l'évaluation des politiques publiques...), elle en constitue, malgré tout, un élément essentiel.

Or, l'organisation wébérienne semble présenter de nombreux obstacles à cette évolution. La rigidité hiérarchique, fonctionnelle et statutaire apparaît comme un facteur de déresponsabilisation et d'apathie.

17. Voir G. Houillon, « Performance publique et ordre juridique », Mélanges en l'honneur de F. Hervouet, LGDJ-Presses de l'université des sciences sociales de Poitiers, 2015, p. 597

18. Voir Y. Chevalier, « La gestion des ressources humaines dans le contexte de la LOLF », in Les Cahiers de la fonction publique et de l'administration n° 255, Berger-Levrault, avril 2006, p. 8-12

Il a donc fallu mettre en place une approche plus collaborative permettant d'impliquer davantage les agents dans les résultats de leurs services. Cette idée ressort clairement de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :

« Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics [...] et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière ».

La coopération, le travail en équipe et une plus grande responsabilisation individuelle vont par ailleurs permettre une meilleure adaptation des décisions administratives aux réalités pratiques. L'autonomie renforcée des différentes structures publiques, conjuguée avec la mise en place de projets de pilotages et de structures de perfectionnement vise ainsi à renforcer une vision plus participative et à infléchir le rôle hiérarchique. *Le supérieur ne constitue alors plus seulement une autorité devant assurer la transmission verticale des impulsions centrales mais aussi un associé à des desseins communs.*

La vocation d'une telle évolution est d'arriver à une meilleure productivité administrative. Or, au fur et à mesure de l'approfondissement des difficultés de l'« État-providence », l'évaluation des politiques publiques a exigé l'importation de critères permettant de piloter l'action administrative. Cela était loin d'être une évidence, tant la tradition administrative n'allait pas dans ce sens.

2. L'introduction de critères de performance dans la GRH publique

La reconnaissance d'éléments d'évaluation liés à la performance des agents administratifs n'est pas une nouveauté absolue uniquement liée à la « nouvelle gestion publique ». On peut même dire que de manière informelle et partielle, ces critères d'évaluation ont toujours été présents dans notre système administratif. Le statut de 1946 avait d'ailleurs contribué à une officialisation (primes au mérite, avancement de grade...). Malgré tout, les profondes réformes lancées dans les années 1980 vont ériger cette approche en système global (2A). Ce dernier va alors s'accompagner d'une volonté d'améliorer la qualification des agents (2B).

2A. L'évaluation des fonctionnaires

Les premières interventions réglementaires en matière d'évaluation des fonctionnaires remontent au décret du 14 février 1959. Cette approche managériale originelle fut approfondie à l'occasion de la refonte statutaire de la décentralisation. Elle fut ensuite profondément revisitée pour la Fonction publique d'État (FPE) avec un nouveau décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement. Ce texte va suivre les recommandations d'un rapport du Comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics sur la période 1999-2001. Celui-ci préconisait notamment la systématisation de l'entretien annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct et la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC).

Le décret de 2002 a partiellement suivi ces recommandations en établissant un lien entre la notation et l'accession à l'échelon supérieur, et donc indirectement, la rémunération de l'agent qui en découle (avec un système de bonification d'ancienneté pour les fonctionnaires les plus méritants).

Ce système, apparu trop mécanique pour aboutir à la souplesse recherchée (automaticité du lien qui ne laissait pas les marges nécessaires à une véritable GRH), sera modifié par la loi du 2 février 2007 sur la modernisation de la fonction publique. Complétée par le décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation professionnelle des fonctionnaires de l'État, cette nouvelle étape réglementaire va remplacer la notation dans la FPE par l'évaluation professionnelle. Cette dernière est fondée sur un entretien individuel qui devra donner lieu à un compte rendu transmis à l'agent et auquel il peut apporter ses remarques. Il s'agit alors d'un acte administratif, juridiquement opposable et susceptible de recours. Les résultats y sont pris en compte dans l'attribution de primes et d'avancement par l'autorité hiérarchique. Donnant davantage de souplesse, ce système sera étendu à la fonction publique territoriale (FPT) par un décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Ces profondes évolutions n'ont pu être mises en place que par le biais d'un accord entre le pouvoir exécutif et les représentants syndicaux des fonctionnaires, devenus de véritables co-gestionnaires avec les autorités hiérarchiques (protocole d'accord du 25 janvier 2006 sur l'amélioration des déroulements de carrière et l'évolution de l'action sociale dans la fonction publique signée par la CFDT, l'UNSA et la CFTC). Cette « contractualisation » est révélatrice du rapprochement des méthodes managériales administratives du modèle privé (alors qu'en théorie les droits et devoirs des fonctionnaires sont soumis à un cadre statutaire dépendant uniquement de la loi et, donc, de la volonté politique). Elle va également permettre d'améliorer la formation des fonctionnaires pour permettre, dans l'intérêt de tous les partenaires, de renforcer les compétences publiques.

2B. Le renforcement de la formation des agents

La loi de février 2007 sur la modernisation de la fonction publique évoquée précédemment a été le pilier de la mise en place d'une « formation professionnelle tout au long de la vie », selon l'expression officielle. Elle visait à mieux accompagner le déroulement des carrières et à une meilleure prise en compte de l'expérience professionnelle. L'intérêt est ici mutuel. D'un côté, l'agent bénéficie d'outils supplémentaires pour permettre une meilleure évolution ou une réorientation judicieuse de sa carrière, et d'un autre côté, la structure bénéficie d'agents plus compétents et épanouis, et donc plus productifs.

Ainsi, la loi de 2007 a-t-elle introduit dans l'administration un droit individuel à la formation (DIF), reconnu à tous les agents de la fonction publique (y compris les agents non titulaires s'ils bénéficient de plus d'un an d'expérience dans leur service). Celui-ci se traduisait en crédit d'heures mises à disposition de l'agent qui pouvait s'en réclamer pour lui permettre de suivre des formations continues inscrites au plan de formation, des préparations aux concours de la fonction publique, des bilans de compétence ainsi que des validations des acquis de l'expérience (VAE). Ces différentes formations peuvent se faire sur son temps de travail ou en dehors selon la préférence de chacun.

Depuis 2017, le DIF a été intégralement remplacé dans l'ensemble de la fonction publique par le compte personnel de formation (CPF) qui s'intègre désormais dans le dispositif plus général du compte personnel d'activité (CPA). Cette démarche a cherché à renforcer encore les possibilités de mobilités au sein des fonctions publiques, mais aussi entre-elles, voire vis-à-vis de l'extérieur. Le CPF a ainsi cherché à approfondir l'universalité et la portabilité des droits qui s'y rattachent. Il convient ici de noter que la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de « transformation de la fonction publique » a transformé le fonctionnement du CPF afin de renforcer encore la portabilité des droits à la formation qui ne sont plus, depuis 2020, comptabilisés en heures mais en euros.

Si l'agent est le premier sujet de ces droits à la formation, la structure administrative en est l'autre bénéficiaire. Cependant, pour qu'un tel système porte tous ses fruits, il convient également de desserrer les cloisonnements structurels (à l'intérieur des différentes fonctions publiques mais surtout entre ces différentes fonctions publiques où les passerelles sont très rares) qui gênent la mobilité. Facteur de flexibilité, et donc de performance améliorée, celle-ci s'incarne à travers plusieurs mécanismes qui offrent à l'agent une multitude de possibilités (détachement, disponibilité, mobilité en position d'activité, mise à disposition). Pour autant, l'insistance des gouvernements successifs sur ces questions depuis plus de quinze ans n'a pas permis de répondre à toutes les attentes. Les pesanteurs historiques et comportementales contreponds à cette modernisation, sont toujours présentes et les mesures évoquées ne sont parvenues que partiellement à les réduire.

Notions clefs

Notion	Définition
Réforme(s) de l'État	Depuis les années 1970, la question de la réforme de l'État est récurrente. Les difficultés budgétaires engendrées par les deux chocs pétroliers ont contribué à faire de cette question un point essentiel pour la survie du « modèle français » (Réformes de 1986, 1989, 2007, 2012). L'objectif est systématiquement le même : renforcer la « performance publique » pour en atténuer les coûts afin de préserver l'État-providence.
Performance publique	Capacité des institutions publiques à atténuer leurs poids budgétaires tout en maintenant une qualité de service équivalente.
Nouvelle gestion publique	Minimisant les différences entre les secteurs public et privé, cette vision tend à rapprocher la gestion publique des modèles managériaux privés centrés sur des indicateurs de performance afin de mettre en place des dispositifs d'évaluation interne.
Modernisation de l'action publique	Nom donné à la dernière vague de réformes administratives (2012) qui reprend en réalité une argumentation ancienne ayant déjà soutenu toutes les réformes administratives depuis plus de vingt ans. Également plébiscitée par les institutions européennes, cette idée s'appuie sur le postulat qu'une administration moderne ne peut être qu'attentive à ses coûts pour chercher constamment à les diminuer.
Droit individuel à la formation	Bien connu sous l'acronyme de DIF, il s'agit d'un ensemble de dispositifs devant permettre aux agents de développer leurs possibilités d'évolution afin de rendre la gestion des ressources humaines publiques plus souple. Il faut noter que cette appellation a été remplacée dans le secteur privé depuis le 1 ^{er} janvier 2015 par le CPF (Compte personnel de formation).

À retenir

Objet depuis toujours de nombreuses critiques, la gestion des ressources humaines au sein de la fonction publique a connu depuis plusieurs années d'importantes modifications. Devant accompagner, et même favoriser, le mouvement de modernisation de l'action publique, ces réformes ont globalement cherché à atténuer un cadre statutaire fixé dans la foulée de la décentralisation et désormais jugé utile mais trop lourd. C'est ainsi qu'une politique de décroisement, influencée par des exemples extérieurs au domaine public, s'est largement développée dans une grande partie de la fonction publique. Modifiant les cadres traditionnels en la matière, elle a contribué à introduire, ou à renforcer, l'évaluation de la performance des agents ainsi que leur mobilité.

SECTION 2. Le maintien de caractéristiques traditionnelles



Objectif

- Identifier les permanences organisationnelles.
- Comprendre la complexité des rapports entre pouvoir politique et structures administratives.

La modernisation de l'organisation professionnelle administrative, dérivée de l'enracinement des principes de la nouvelle gestion publique, se heurte à différentes caractéristiques historiques de l'administration. Liées à certaines particularités structurelles (service de l'intérêt général, exercice d'un pouvoir de coercition, caractère juridique dérogatoire...), elles continuent à jouer un grand rôle dans l'organisation et le fonctionnement de l'« ordre » administratif. Or, leur impact négatif sur le mouvement de modernisation de la gestion publique se traduit, soit par une soustraction de certains éléments à son emprise justifiée par des contingences politiques (1), soit par une altération de la mise en œuvre de ses préceptes (2).

1. La porosité politique

Outil de gouvernement, l'administration se trouve particulièrement exposée à l'immixtion des rivalités politiques partisans qui actionnent l'exercice du pouvoir souverain (quelles que soient leurs formes). L'appareil administratif a donc, depuis toujours, cherché à se prémunir (de manière formelle ou informelle) de cette « dérive », que ce soit au nom du service du bien commun (Ancien régime), de la volonté générale (depuis la Révolution), ou encore des intérêts locaux (depuis la décentralisation) : instrument de régulation des rapports sociaux, l'État ne peut être qu'au service d'une communauté sociale dont il est l'incarnation juridique. Pourtant, ces phénomènes perdurent et résistent, car ils sont consubstantiels à l'État lui-même.

Aujourd'hui, le contrôle souverain de l'administration par les représentants de la nation engendre proximité et porosité entre les sphères politiques et administratives. Évidemment, les éléments les plus exposés sont les plus proches des centres de décision politique. Il s'agit de la haute administration (1A) et de la fonction publique territoriale (1B).

1A. La haute administration

S'il est un secteur administratif étatique confronté à la problématique de la politisation, c'est bien celui de la haute administration. C'est dans cette zone de la pyramide administrative que les atteintes à la stricte logique professionnelle sont les plus fortes. En charge de traduire la volonté politique en impulsions administratives, la haute administration est logiquement confrontée aux risques de contagion des luttes politiques partisans. Sa proximité la condamne ainsi, à chaque alternance, à subir les velléités accaparatrices des moyens administratifs.

Cette porosité est juridiquement permise par l'exclusion d'une grande partie de la haute administration du statut général de la fonction publique. Ainsi, le recrutement et la gestion de ces personnels sont confiés à la discrétion du pouvoir politique. Au nom de leur caractère stratégique, ces fonctions (directeurs d'administration centrale, préfets, recteurs, PDG de sociétés publiques...) sont donc laissées à la libre appréciation du pouvoir exécutif. Celui-ci va fréquemment être tenté de s'assurer du loyalisme politique de ses agents les plus importants, voire même parfois de récompenser des soutiens et ainsi délaisser les compétences au profit de la fidélité. Longtemps masqué par l'absence d'alternance sous la Ve République, ce phénomène s'est renforcé dans les années 1970 à la faveur de l'érosion du pouvoir gaulliste. On retrouve depuis lors des phénomènes bien connus de la III^e République (et même des régimes antérieurs) d'« épuration » de secteurs clefs en cas de changement de direction politique (par exemple en 1981 et en 1986). Évidemment, l'intensité de ces phénomènes se modifie en fonction des secteurs concernés. Les plus touchés sont traditionnellement l'Intérieur, l'Éducation nationale, les Finances et la Justice.

Conscients des graves dysfonctionnements potentiels engendrés par ce clientélisme, les pouvoirs publics ont tenté depuis maintenant vingt ans d'atténuer sa portée. Ainsi, le pouvoir constituant a-t-il introduit dans notre texte suprême, lors de la réforme du 23 juillet 2008 sur la « modernisation des institutions de la V^e République », plusieurs contrôles parlementaires (via des commissions parlementaires permanentes où siègent les groupes d'opposition) des nominations réalisées par le pouvoir exécutif dans les corps les plus élevés (article 13 alinéa 5 de la Constitution).

Ce mouvement s'inspire du modèle américain du « spoil system » (système des dépouilles). Cette approche pragmatique reconnaît, mais régule aussi, ces phénomènes de politisation de la haute administration. Ainsi, elle conjugue une officialisation d'une large liberté de nomination du pouvoir exécutif avec un encadrement strict des procédures par le biais d'un contrôle indépendant. Ce dernier a alors vocation à garantir la compétence effective de l'impétrant (par le biais du Sénat notamment). Ainsi, chaque changement de présidence des États-Unis voit-il de vastes mouvements de personnels s'opérer dans les administrations fédérales (qui expliquent également le délai entre l'élection en novembre et l'entrée en fonction en janvier).

1B. La fonction publique territoriale

La mise en place de la décentralisation avec les lois Deferre s'est accompagnée de la volonté de reproduire, pour les agents de la FPT (en prenant évidemment en compte les spécificités de leurs missions) le modèle existant au sein de la FPE. En effet, l'autonomie nouvelle des collectivités territoriales (introduite constitutionnellement avec la notion de « libre administration ») soustrayait leurs agents de l'administration traditionnelle déconcentrée (placée sous l'autorité du préfet et des ministères). Il fallait donc leur donner un nouveau cadre juridique. La loi du 26 janvier 1984 fit le choix de la reproduction du modèle ouvert aux agents de l'État.

Cette démarche s'est appuyée sur deux arguments. Tout d'abord, les importantes disparités au sein de ce vaste ensemble territorial (régions, départements, petites et grandes communes), souvent en concurrence, justifiaient une régulation statutaire, et donc uniforme, des agents locaux pour garantir à la fois l'unité et l'équité républicaine. D'autre part, l'agent local est par définition très exposé aux centres de pouvoir. Dans cette optique, le statut a vocation à prémunir l'agent d'une forme d'obédience politique qui est préjudiciable à sa neutralité.

Pour autant, malgré ces efforts, il est incontestable qu'il existe une grande divergence entre cette neutralité de principe et la réalité pratique¹⁹. La reconnaissance d'une implantation hiérarchique autonome au niveau local, a amplifié des phénomènes de clientélisme que les régimes centralisés antérieurs avaient toujours combattu (missi dominici, intendants, préfets...). Ainsi, il est particulièrement tentant pour l' élu local (en particulier s'il a des ambitions nationales) de se forger « un fief politique » qui lui permettra d'ancrer son installation dans le paysage politique (ce phénomène étant alimenté en France par la faiblesse des structures des partis politiques). Dans cette perspective, la gestion du personnel de la collectivité est dénaturée, au moins partiellement, en cherchant à favoriser ponctuellement des ambitions partisans plutôt que l'intérêt des administrés. Il s'agit donc d'une remise en cause aussi ancienne qu'insidieuse de la neutralité politique du personnel administratif exigée par sa soumission à l'intérêt général.

Au-delà des principes généraux, ce clientélisme présente plusieurs inconvénients pratiques dommageables à la qualité du service public local. Il engendre une surcharge d'effectifs (chaque nouvelle majorité pouvant empiler ses affidés sur ceux de la précédente), la mise en place de système de récompenses détournées du mérite (primes, avantages en nature...) ou encore une démotivation d'agents « placardisés » par une alternance politique « malheureuse ».

Ces phénomènes ancestraux ont été atténués par le statut de la FPT (fixant un système de carrière méritocratique) sans avoir été totalement éradiqués. D'une part, le phénomène continue d'affecter le recrutement d'agents, en particulier à travers les embauches discrétionnaires offertes aux élus locaux (chargés de missions, cabinet particulier...). D'autre part, il continue d'influencer l'évolution des carrières des agents statutaires par le biais de décisions hiérarchiques d'avancement qui restent placées, au sein du statut, dans le champ de compétence des élus (au nom de l'autonomie des collectivités locales).

19. Voir sur ce point, Pierre Sadran, « De l'allégeance à la mobilité : quelle politisation pour la fonction publique territoriale », in Pouvoirs, n° 40, 1987, pp.39-48

2. Les limites de la recherche systématique d'efficacité

L'essentiel des dernières vagues de réformes dans la gestion du personnel administratif a eu pour vocation, directe ou indirecte, l'amélioration la productivité de l'activité publique. Cette quête managériale systématique d'efficacité s'est cependant heurtée à des limites structurelles : externes d'une part, avec la permanence d'une forte sectorisation (2A), et internes d'autre part, en raison de sa propre nature (2B).

2A. La permanence du morcellement des services

À mesure que « l'État-providence » s'est approfondi et a développé la diversité de ses missions, il lui a fallu répondre à des problématiques toujours plus spécifiques. Cette exigence a ainsi engendré un renforcement de la spécialisation de services systématiquement placés sous une autorité politique de tutelle (ministre, vice-président, adjoint...).

Depuis qu'il a été mis en place²⁰, le modèle de gouvernance thématique a engendré concurrence, et donc cloisonnement, des différentes branches administratives, parfois entretenu par l'autorité suprême elle-même comme un mode de domination (en particulier en cas de forte centralisation institutionnelle, comme sous les régimes napoléoniens). Mais la plupart du temps, le centre administratif a cherché, au contraire, à combattre ces phénomènes. La raison en était moins l'altération de l'efficacité de l'action publique, que les risques d'une autonomie synonyme de perte de contrôle de la tutelle.

Ce cloisonnement sectoriel part du centre du pouvoir pour se répandre ensuite dans l'ensemble de l'appareil au niveau déconcentré. En effet, depuis le XIX^e siècle, malgré la toute-puissance juridique du préfet (héritier sur ce point de l'esprit de l'intendance d'Ancien régime), le pouvoir central a continuellement eu d'importantes difficultés à contrôler et à coordonner l'action des divers services ministériels sur ses territoires (y compris pour le simple échange d'informations). La répartition bureaucratique amenait ainsi les « services extérieurs » (appellation antérieure à celle de « services déconcentrés » introduite dans les années 1990) à privilégier l'autorité ministérielle sectorielle à celle d'un préfet omnipotent. En effet, situé dans une position nodale, ce dernier s'inscrit dans une logique transversale qui heurte les traditions sectorielles de l'administration : « Quelle très grande entreprise exerçant dix ou vingt métiers différents ferait diriger ses opérations dans chaque département par un patron local coiffant l'ensemble des métiers et appelé à être muté tous les 18 mois ? »²¹.

Qui plus est, cette logique de cloisonnement aboutit à percevoir toute création de structure nouvelle (souvent interministérielle pour permettre la transversalité caractéristique de l'approche de la nouvelle gestion publique) comme une sorte d'immixtion, voire d'agression. Elle constitue, à ce titre, un puissant vecteur de conservatisme des monopoles établis, et donc d'opposition à l'innovation et à la modernisation administrative.

Enfin, l'impact d'une technicité accrue de l'action de l'« État-providence » (qui a contribué au renforcement du pouvoir technocratique) constitue un facteur matériel aggravant en introduisant des particularismes en matière de compétence, de déontologie ou encore de moyens d'action.

En s'institutionnalisant, par le biais de la verticalité hiérarchique, ces singularités favorisent l'identification de l'agent à son service. Ils enferment alors la destinée des carrières dans une logique sectorielle et donc dans des stratégies corporatives qui nuisent à la flexibilité des ressources humaines et donc à l'efficacité d'ensemble du système administratif. Ainsi, la « nouvelle gestion publique » a tenté de développer la mobilité dans la gestion de la fonction publique (voir par exemple la loi relative à « la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique » du 6 août 2009). Malgré tout, ces mesures restent encore largement insuffisantes pour permettre une véritable fluidification des parcours professionnels publics.

2B. L'illusion de l'optimisation perpétuelle

La démarche d'optimisation de l'action publique portée par les réformes administratives depuis plus de vingt ans a déjà largement modifié le paysage du secteur public français. Or, cette vision, reprise par tous les gouvernements quelle que soit leur obédience politique, s'appuie sur une dialectique rationnelle établissant un lien logique entre les conditions de la prise de décision et ses effets. Elle dresse ainsi le tableau d'un processus idéal où l'agent hiérarchique, en accord avec les directives initiées par sa tutelle et informé exhaustivement par ses services, prend une décision optimale conjuguant parfaitement pertinence financière et matérielle. L'État parviendrait alors à répondre à ses vastes missions d'une manière conforme aux exigences budgétaires.

20. Soit depuis le haut Moyen-Âge où une organisation thématique du Conseil royal prit le relais d'un schéma fondé sur une approche géographique.

21. B. Abate, *La Nouvelle gestion publique*, Paris, LGDJ, 2000, p. 21

Or cet objectif ne peut, par nature, être totalement atteint. Les altérations inéluctables de l'information dans sa transmission, l'impossibilité d'une prise en compte exhaustive de l'intégralité des facteurs en jeu, la part inévitable de subjectivité du décideur, les incertitudes des effets des choix opérés viennent ainsi altérer en pratique la qualité théorique de la décision. Dès lors, elles imposent des corrections et donc des redéploiements budgétaires.

On voit ainsi, qu'en pratique, la modernisation de « l'État-providence » exige une succession d'arbitrages entre les nécessités qualitatives et financières. *La force des contingences financières va inéluctablement engendrer, soit un retrait ciblé de l'action publique pour permettre une concentration des moyens sur des enjeux jugés prioritaires, soit une réduction plus globale de périmètres d'intervention permettant de diluer les efforts. On peut ainsi dire que la « nouvelle gestion publique » constitue en réalité moins une démarche de maintien de la qualité du service public qu'une gestion raisonnée du rétrécissement du périmètre de « l'État-providence »*. En effet, la notion même de service public à la base des théories (héritées de Léon Duguit) du droit administratif français peut venir se heurter frontalement aux nouveaux impératifs modernes de performance. Cette « performance publique » peut aussi être mal évaluée au regard des objectifs selon le choix des indicateurs. La transposition intégrale de la performance privée montre donc nécessairement des limites dans le service public²².

Qui plus est, les arbitrages opérés, du fait des impératifs démocratiques, ne sont pas seulement affectés par la pure recherche d'efficacité, mais aussi par des contingences politiques. De la même manière, l'augmentation de la demande d'informations au sein des services, et la crainte des résultats de leur exploitation, aboutit parfois dans les services à une déformation des réalités de terrain.

Ainsi, comme l'a souligné le professeur Chevallier :

« La rationalité apparaît davantage comme un mythe auquel sont tenus de sacrifier les décideurs, une rhétorique symbolique nécessaire mais artificielle ».

Elle n'en est pas moins indispensable car, si l'objectif paraît parfois idéalisé, lui seul permettra d'adapter la lourde machine administrative française aux défis de la période qui vient de s'ouvrir.

22. Voir par ex. G. Houillon, « Performance publique et ordre juridique », Mélanges en l'honneur de F. Hervouet, LGDJ — Presses de l'université des sciences sociales de Poitiers, 2015, p. 597

Notions clefs

Notion	Définition
Porosité politique de l'administration	Dérive administrative que l'on retrouve essentiellement dans la haute administration et dans la fonction publique territoriale. Elle consiste dans une politisation des services administratifs qui nuit à l'exigence de neutralité et perturbe la continuité de l'État.
Haute administration	Ensemble des services qui sont placés sous la direction immédiate du pouvoir politique et dont la nomination et le cadre juridique d'exercice dérogent généralement au statut général.
Fonction publique territoriale	Ensemble des personnes et des services exerçant de manière permanente leurs missions dans le cadre d'une collectivité territoriale et dont le statut est fixé par une loi du 26 janvier 1984.
Technocratie	Système de gouvernance au sein duquel les experts (fonctionnaires en l'occurrence) supplantent, en fait ou en droit, le pouvoir politique dans la prise de décisions lui revenant.
Sectorisation	Tendance des services à se cloisonner par ministère. Cette pratique nuit à la cohérence et à l'efficacité globale de l'action de l'État.

À retenir

En dépit d'incontestables réalisations, la modernisation de l'action publique reste encore largement un objectif à atteindre. La volonté de rapprocher les modalités de gestion publique de celles du secteur privé s'est ainsi heurtée à d'importants obstacles. Consubstantiels à l'administration moderne elle-même, et donc au modèle jacobin hérité de la Révolution, ces derniers nuisent à la réalisation des réformes mises en place depuis plus de 30 ans. Ainsi la politisation de certains pans de l'administration française (haute administration et FPT), comme la sectorisation excessive dans les autres cas, contribuent-ils à maintenir les perceptions traditionnelles et donc freiner les réformes. Qui plus est, la logique d'accroissement perpétuel de l'efficacité administrative ne peut constituer l'unique objectif de l'action publique, étant par nature illusoire. D'ailleurs, elle aboutit souvent, en pratique, à une baisse qualitative justifiée par les contraintes budgétaires. Introduisant une logique de rentabilité, elle peut donc, si elle fait oublier l'intérêt général, porter atteinte à la mission historique d'une administration qui contribue depuis près de mille ans à assurer la cohérence de la nation française.

PARTIE 2 DROIT ADMINISTRATIF : LES MOYENS ET LES CONSÉQUENCES L'ACTION ADMINISTRATIVE

TITRE 1. Les moyens de l'action administrative

L'administration dispose de moyens juridiques propres pour mener à bien ses missions. À ce titre, elle est essentiellement une institution commandante agissant unilatéralement (sous-titre 1) même si la dimension contractuelle ne doit pas être négligée (sous-titre 2).

Elle dispose aussi de moyens matériels adaptés et propres destinés à lui permettre cette action : il en est ainsi du régime de la domanialité publique (sous-titre 3) ; des travaux publics (sous-titre 4) et de l'expropriation (sous-titre 5).

SOUS-TITRE 1. L'acte administratif unilatéral

L'administration peut être à l'origine de deux types d'actes unilatéraux. Lorsqu'elle se comporte comme une personne privée, elle prend des actes de droit privé. Lorsqu'elle intervient en tant que puissance publique, elle édicte des actes administratifs unilatéraux (chapitre 1) qui obéissent à un régime de droit public (chapitre 2).

CHAPITRE 1 La notion d'acte administratif unilatéral

L'acte administratif unilatéral est une notion complexe en raison des critères multiples qui permettent de l'identifier (section 1) et des diverses catégories qu'il recouvre (section 2).

SECTION 1. La définition de l'acte administratif unilatéral

Il s'agit d'abord d'un acte juridique, c'est-à-dire, d'une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Par conséquent, ne constituent pas des actes juridiques les agissements matériels involontaires de l'administration comme un accident causé par un véhicule administratif.

Ensuite, l'acte juridique doit être édicté unilatéralement pour pouvoir être qualifié d'acte administratif unilatéral. Cette précision vise à distinguer l'acte administratif unilatéral du contrat (acte bi ou multilatéral).

L'acte unilatéral n'est pas un acte élaboré par une seule personne. En effet, il peut faire l'objet d'une concertation (par exemple pour la détermination des honoraires des médecins négociés entre praticiens et caisses de sécurité sociale puis approuvés par le ministre).

L'acte unilatéral est celui qui règle la conduite de personnes même sans leur assentiment. Au contraire, ne sont liés par un contrat que ceux qui le désirent.

Enfin, il s'agit d'un acte administratif qui se définit principalement par un critère matériel. Cependant, le critère organique intervient également dans la mesure où l'appréciation du contenu de l'acte dépendra du fait qu'il a été pris par une personne publique (sous-section 1) ou privée (sous-section 2).

SOUS-SECTION 1. Les actes émanant d'une personne publique

Tous les actes d'une personne publique n'ont pas un caractère administratif. Il faut distinguer selon qu'elle agit (1) ou non (2) en tant qu'organe administratif.

1. Les actes pris par un organe administratif

Lorsqu'une personne publique agit en tant qu'organe administratif, ses actes présentent un caractère administratif (CE 1907 Compagnie des chemins de fer de l'est).

Ce principe admet, cependant, une exception pour les actes qui intéressent les rapports individuels entre un SPIC et ses usagers (CE 1961 Dame Agnesi : refus d'un maire d'autoriser un branchement sur le réseau d'eau potable) ou agents (CE 1957 Jalenques de Labeau).

Lorsqu'une personne publique n'agit pas en tant qu'autorité administrative, ses actes ne peuvent pas avoir un caractère administratif.

2. Les actes pris par un organe non administratif

Ne présentent pas de caractère administratif les actes de gouvernement (2A) ainsi que les actes législatifs (2B) et juridictionnels (2C).

2A. Les actes de gouvernement

La théorie des actes de gouvernement est d'origine jurisprudentielle même si le Conseil d'État n'emploie que rarement ce terme (2A1). L'acte de gouvernement se singularise par l'immunité juridictionnelle dont il bénéficie (2A2).

2A1. La notion d'acte de gouvernement

La plupart des auteurs considèrent qu'il est impossible de trouver un critère expliquant l'acte de gouvernement. C'est pourquoi ils se contentent d'en établir la liste (a). Certains auteurs ont, cependant, tenté de donner une définition de l'acte de gouvernement (b).

≡ La liste des actes de gouvernement (a)

Constituent, d'une part, des actes de gouvernement les actes de l'exécutif dans ses rapports avec les autres « pouvoirs publics constitutionnels ». Tel est le cas, par exemple :

- de la décision du chef de l'État de recourir à l'article 16 de la Constitution (CE 1962 Rubin de Servens),
- de la dissolution de l'Assemblée nationale (CE 1989 Allain),
- de l'opportunité pour le Gouvernement de saisir le Conseil Constitutionnel afin qu'il constate l'empêchement du chef de l'État (CE 2005 Hoffer).

D'autre part, présentent également le caractère d'actes de gouvernement, les actes de l'exécutif relatifs aux relations internationales, tels que :

- la décision de reprendre les essais nucléaires (CE 1995 Association Greenpeace France),
- la décision d'engager des forces militaires en Yougoslavie (CE 2000 Mégret et Mekhantar).

Plusieurs auteurs ont tenté de donner un sens à cette liste.

≡ Les tentatives de définition de l'acte de gouvernement (b)

Une partie de la doctrine a conclu à l'inexistence des actes de gouvernement. Le commissaire du gouvernement Célrier a expliqué que l'immunité dont bénéficie l'acte de gouvernement s'explique par le jeu normal des règles du contentieux administratif. En effet, le juge administratif étant le juge de l'administration française, il est normal qu'il ne puisse pas connaître des « actes mixtes », c'est-à-dire qui intéressent également le pouvoir législatif ou des autorités étrangères.

À l'origine, l'acte de gouvernement semble s'expliquer par la théorie du mobile politique. Cette théorie a été abandonnée après que le Conseil d'État se soit déclaré compétent pour apprécier la légalité du refus d'inscrire le nom d'un général sur l'annuaire militaire malgré le caractère politique invoqué (CE 1875 Prince Napoléon).

Gros a, cependant, invoqué une « survivance de la raison d'État ». Lorsque le juge administratif a développé son contrôle de l'administration, il a dû, en compensation, laisser un domaine réservé : l'acte de gouvernement qui ne se définit plus par son mobile politique mais par sa nature politique intrinsèque.

De même, René Chapus définit l'acte de gouvernement comme celui qui intervient dans une matière de gouvernement (c'est-à-dire politique) échappant donc à la compétence du juge administratif limitée à la fonction administrative. En jugeant que la décision de confier à un parlementaire une mission « constitue le premier acte de l'exécution d'une mission administrative » ainsi « détachable des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif », le Conseil d'État semble valider cette approche (CE 1998 Mégret). Quoi qu'il en soit de tels actes échappent pour l'essentiel au contrôle du juge.

2A2. Le régime juridique de l'acte de gouvernement

L'acte de gouvernement est insusceptible de recours en appréciation de légalité (a) ou en responsabilité (b). Cependant, l'étendue de cette immunité peut être discutée.

≡ L'absence de recours en appréciation de légalité (a)

Le juge administratif se déclare incompétent pour connaître des REP et des recours en exception d'illégalité formés contre un acte de gouvernement (CE 2000 Mégret et Mekhantar).

Le Conseil d'État a jugé que l'article 6 de la CEDH qui prévoit un droit au recours pour les contestations sur les droits et obligations de caractère civil ne concernait pas les actes de gouvernement car ils sont étrangers à ce domaine (CE 2003 Comité contre la guerre en Irak).

Bien que la doctrine tienne cette immunité pour « absolue », elle semble se limiter à la légalité interne de l'acte de gouvernement. Ce choix s'explique par le fait que le contrôle de la légalité externe n'implique pas de porter une appréciation sur le contenu de l'acte. C'est ainsi que le Conseil d'État a vérifié si le Président de la République avait consulté les autorités prévues par la Constitution avant de mettre en œuvre l'article 16 (CE 1962 Rubin de Servens).

L'étendue de l'immunité dont bénéficient les actes de gouvernement dans le contentieux de la responsabilité est également sujet à discussion.

≡ L'absence de recours en réparation (b)

Il a, par exemple, été jugé qu'est irrecevable le recours en indemnité fondé sur une mauvaise exécution par la France de ses engagements internationaux (CE 1962 Prince Slimane Bey à propos du défaut de protection promise à une dynastie étrangère).

Certains auteurs qui considèrent qu'un traité constitue un acte de gouvernement présentent l'arrêt du Conseil d'État qui reconnaît la responsabilité sans faute de l'État du fait d'un traité comme une brèche dans l'immunité juridictionnelle dont bénéficient les actes de gouvernement (CE 1966 Compagnie d'énergie radio électrique).

Cependant, la majeure partie de la doctrine estime qu'un traité n'est pas un acte de gouvernement et que, par conséquent, il n'y a pas d'exception à l'absence de responsabilité pour les actes de gouvernement. D'autres universitaires pensent que le régime contentieux des traités (qui ne sont pas des actes de gouvernement) concerne également les actes de gouvernement.

Finalement on constate que le régime de l'acte de gouvernement est aussi difficile à cerner que la notion. Ne constituent pas non plus des actes administratifs, ceux pris par un organe législatif.

L'acte de gouvernement

	Notion	Régime juridique
Dans la jurisprudence	Actes de l'exécutif dans ses rapports avec les autres pouvoirs publics constitutionnels Actes de l'exécutif relatifs aux relations internationales	Contrôle de la légalité
		Le contrôle de la légalité d'un acte de gouvernement est impossible sauf peut-être pour la légalité externe
Pour la doctrine	Théorie de l'inexistence des Actes de gouvernement : le juge administratif ne peut pas connaître des actes mixtes intéressant le pouvoir législatif ou les autorités étrangères Théorie de la survivance de la raison d'État : le juge administratif ne souhaite pas connaître des actes qui ont une nature politique	Contentieux de la réparation
		Le recours en indemnisation contre un acte de gouvernement est irrecevable sauf peut-être pour les traités si on les considère comme des actes de gouvernement

2B. Les actes pris par un organe législatif

N'ont pas un caractère administratif, les actes pris par un organe législatif, c'est-à-dire une institution qui intervient dans un domaine législatif. Ainsi, par exemple, pour une loi votée par le Parlement (CE 1936 Arrighi) et les actes pris par le chef de l'État sur le fondement de l'article 16 et intervenus dans le domaine de la loi (CE 1962 Rubin de Servens).

A contrario, un acte d'un organe parlementaire qui intervient dans un domaine administratif revêt un caractère administratif (CE 1999 Président de l'Assemblée nationale : décision du président de l'Assemblée nationale de passer un marché public).

La même solution s'applique pour les actes émanant d'une autorité juridictionnelle.

2C. Les actes pris par un organe juridictionnel

Ne sont pas des actes administratifs, les actes pris par un organe juridictionnel, c'est-à-dire remplissant une fonction juridictionnelle comme le montre le cas de l'exercice par le chef de l'État du droit de grâce (CE 1947 Gombert) ou des décisions du CSM en matière disciplinaire (CE 1969 L'Etang).

Au contraire, une juridiction lorsqu'elle « exerce des attributions administratives » prend des actes administratifs (CE 1978 Croissant : avis émis par une chambre d'accusation en matière d'extradition).

Certains actes pris par une personne privée peuvent aussi avoir un caractère administratif.

SOUS-SECTION 2. Les actes émanant d'une personne privée

Il faut distinguer le cas de la personne privée qui gère un SPA de celui de la personne privée qui gère un SPIC (voir supra les développements sur le régime juridique des SPA et des SPIC).

Les actes administratifs unilatéraux peuvent être répartis en différentes catégories.

SECTION 2. La classification des actes administratifs unilatéraux

Il existe 3 distinctions principales entre les actes administratifs unilatéraux : selon qu'ils ont ou non un caractère décisoire (1), selon qu'il s'agit d'actes express ou tacites (2) et selon qu'ils ont ou non une portée réglementaire (3).

1. Les actes administratifs unilatéraux décisores et ceux qui ne le sont pas

L'intérêt de déterminer si on est en présence (1A) ou non (1B) d'une décision administrative est qu'elle seule peut faire l'objet d'un REP.

1A. Le critère de l'acte décisoire

Parmi les actes administratifs unilatéraux, seuls certains constituent des décisions. Ce sont ceux qui font grief, c'est-à-dire qui affectent l'ordonnancement juridique. L'acte peut affecter l'ordonnancement juridique de deux façons. D'une part, par une modification de l'ordonnancement juridique en ajoutant au droit (crée une nouvelle règle ou en précise une ancienne) ou en retirant au droit (par exemple, en abrogeant un texte). D'autre part, avec le maintien de l'ordonnancement juridique par un refus (qui ne change pas les possibilités offertes à l'intéressé).

L'acte administratif unilatéral décisoire est également parfois qualifié de « décision exécutoire ». On peut, cependant, plutôt penser avec René Chapus que seules certaines décisions ont un caractère exécutoire. En effet, dans un arrêt, le Conseil d'État vise « une décision administrative qui a un caractère exécutoire » (CE 1982 Huglo). L'absence de virgule après le terme administratif montre implicitement que toute décision administrative n'a pas un caractère exécutoire.

Il est important de connaître ce qu'est une décision exécutoire car elle seule peut faire l'objet d'un sursis à exécution. Il est pourtant délicat de préciser le sens de ce terme. Pour Hauriou, exécutoire veut dire « qui peut entraîner l'exécution d'office », c'est-à-dire le recours à la force. En principe, une décision administrative n'a pas cette portée, sauf exception. Pour certains auteurs, exécutoire signifie qui provoque en lui-même sa mise en œuvre. Il n'y a pas besoin d'intervention du juge. C'est ce que Hauriou désignait par le terme de « privilège du préalable ». René Chapus considère que cette caractéristique est celle de la décision. Le terme exécutoire signifie aussi entrer en vigueur. C'est en ce sens qu'il est employé dans la loi du 2 mars 1982 qui précise que « sont exécutoires de plein droit, les actes des autorités locales ».

Plusieurs actes administratifs unilatéraux n'ont pas un caractère décisoire.

1B. Les actes administratifs unilatéraux non décisaires

Il s'agit des circulaires (1B1), des directives (1B2), des mesures d'ordre intérieur (1B3), des mesures gracieuses (1B4) et des actes qui précèdent un acte administratif unilatéral décisaire ou lui font suite (1B5).

1B1. Les circulaires

Une circulaire (parfois appelée instruction ou note de service) peut se définir comme l'acte par lequel un chef de service (notamment un ministre) explique à ses subordonnés comment doit être appliqué un texte (entre 10 000 et 15 000 circulaires sont prises chaque année).

Le Conseil d'État distingue deux types de circulaires.

Dans un premier temps, le Conseil d'État distinguait la circulaire interprétative qui se contente effectivement d'expliquer un texte et qui ne fait donc pas grief et la circulaire réglementaire qui modifie en fait l'ordonnancement juridique et qui peut donc faire l'objet d'un REP ou être invoquée par un administré. Une telle circulaire sera annulée dans ses dispositions normatives si son auteur ne dispose pas du pouvoir réglementaire ou si elle est contraire à une norme supérieure (CE 1954 Institution Notre Dame du Kreisker : circulaire du ministre de l'Éducation nationale fixant des règles nouvelles pour les demandes de subventions présentées par les établissements privés).

Aujourd'hui, le Conseil d'État distingue les circulaires selon qu'elles ont ou non un caractère impératif (CE 2002 Mme Duvignères). Si une circulaire entend imposer une règle (peu importe que celle-ci soit ou non présentée comme l'interprétation d'un texte), elle fait grief et est susceptible de faire l'objet d'un REP. Comme auparavant la circulaire impérative sera annulée si la règle est édictée par une autorité incompétente ou contrevient à la hiérarchie des normes mais également si elle « réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure » (circulaire rappelant, par exemple, une règle posée par une loi contraire à un traité). Au contraire, si la circulaire n'impose aucune prescription, elle ne fait pas grief et ne peut donc pas être contestée devant le juge administratif. L'état du droit ne s'en trouve pas simplifié car il peut être délicat de déterminer si la règle énoncée dans la circulaire doit ou peut être mise en œuvre par les agents.

Un décret de décembre 2008 prévoit qu'à compter du 1^{er} mai 2009 les circulaires et instructions (les nouvelles comme les anciennes) doivent être publiées sur un site internet particulier pour être opposables aux particuliers.

Le caractère automatique ou non de la solution prescrite se retrouve pour les directives.

1B2. Les directives

La directive est un texte par lequel un chef de service fixe une ligne de conduite pour prendre des décisions individuelles dans un domaine où l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire. L'idée est de rechercher une cohérence dans l'action administrative et d'éviter un traitement différent des administrés dans la même situation.

Cette directive qui ne concerne que l'administration française se distingue de la directive européenne qui lie ses destinataires quant aux objectifs à atteindre.

La directive doit aussi être différenciée de l'acte réglementaire sur trois points.

D'abord, elle ne décide pas mais oriente. Par conséquent, à la différence du règlement auquel un subordonné ne peut pas déroger sauf si le règlement le prévoit expressément, il est possible de déroger à une directive et il est même obligatoire de le faire si la situation de l'administré où une considération d'intérêt général le justifie (CE 1970 Crédit Foncier de France à propos des critères pour bénéficier de subventions accordées par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat).

Ensuite, elle ne fait pas grief et ne peut donc pas faire l'objet d'un REP.

Enfin, elle ne doit pas être publiée sauf si elle comporte « une interprétation du droit positif ou une description des procédures » (loi du 17 juillet 1978 sur les relations entre l'administration et le public).

La directive doit aussi être distinguée de la circulaire sur trois points.

En premier lieu, elle est opposable aux administrés, c'est-à-dire que l'administration peut expressément se fonder sur une directive pour prendre une décision.

Ensuite, elle est opposable à l'administration ainsi que le rappelle le décret de 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers. Un administré peut donc demander l'annulation d'une décision prise sur la base d'une directive si cette décision déroge à la directive alors qu'elle n'aurait pas dû le faire. L'administré peut également demander l'annulation d'une décision prise sur la base d'une directive si cette décision ne déroge pas à la directive alors qu'elle aurait dû le faire. Cependant, s'agissant d'un domaine où l'administration dispose

d'un pouvoir discrétionnaire, le juge administratif n'exerce qu'un contrôle minimal sur la décision, c'est-à-dire se contente de vérifier que l'administration a procédé à un examen de la situation individuelle de l'administré (CE 1977 Société Marchand).

Enfin, l'administré peut invoquer à l'appui d'un REP formé contre une décision prise sur le fondement d'une directive, l'illégalité de cette dernière (exception d'illégalité). L'illégalité de la directive pourra être retenue parce qu'elle a édicté une condition nouvelle par rapport aux dispositions applicables ou parce qu'elle a méconnu les buts envisagés par la loi ou le règlement (CE 1970 Crédit Foncier de France).

Dans son étude de 2013 sur le droit souple, le Conseil d'État préconisait de remplacer le terme de directive par « lignes directrices ». Ce changement de sémantique a été opéré au contentieux (CE 2014 AEFE).

La directive est parfois confondue avec la mesure d'ordre intérieur.

1B3. Les mesures d'ordre intérieur

Les mesures d'ordre intérieur (a) sont de plus en plus restreintes (b).

≡ La notion de mesure d'ordre intérieur (a)

La doctrine est assez partagée sur le sens à donner à ce terme.

Certains auteurs donnent un sens large à la notion de mesure d'ordre intérieur en désignant par ce terme tous les actes émis par l'administration et relatifs à son fonctionnement interne ce qui englobe les circulaires et directives.

D'autres auteurs n'incluent pas ces deux derniers actes mais considèrent comme des mesures d'ordre intérieur les vœux, les mesures préparatoires et les actes qui sont la suite d'une décision.

Enfin, la plupart des auteurs limitent les mesures d'ordre intérieur aux mesures tendant à assurer l'ordre interne d'un organisme, notamment dans l'armée, l'école ou la prison.

Par ailleurs, une partie de la doctrine considère que les mesures d'ordre intérieur sont des décisions mais qu'elles ne peuvent pas faire l'objet de REP car elles sont porteuses d'enjeux minimes. Pour eux l'effet décisoire d'un acte (affecte la situation juridique d'une personne) est indépendant du fait qu'il peut faire grief (porte atteinte aux droits et libertés d'une personne). Cependant, un autre courant de pensée classe les mesures d'ordre intérieur dans les actes non décisores parce qu'ils ne font pas grief. Le juge administratif a décidé de ne pas accepter le REP à l'égard de ces mesures pour ne pas mettre en cause la discipline dans ces organismes et parce qu'elles sont de menue importance (traduction de l'adage de *minimis non curat praetor*). C'est ce dernier point qui laisse penser que le juge ne les considère pas comme des actes faisant grief et donc comme des décisions.

Selon la jurisprudence, la qualification de mesure d'ordre intérieur dépend « de la nature ainsi que de l'importance des effets de la mesure sur la situation » de l'intéressé (CE 2007 garde des Sceaux c M. Boussouar).

Cependant, l'influence de la convention européenne des droits de l'homme (droit à un recours effectif) et la situation dans d'autres États ont conduit à un rétrécissement progressif de cette catégorie.

≡ La restriction de la catégorie (b)

Ainsi, ne sont plus considérés comme des mesures d'ordre intérieur :

- les jours d'arrêts infligés à un marin rentré en état d'ébriété sur son navire et qui a refusé de se soumettre à un alcootest en raison de leurs conséquences sur la liberté d'aller et venir, l'avancement et le renouvellement du contrat de l'intéressé (CE 1995 Hardouin) ;
- les jours de cellule de punition (entraînant l'isolement et la privation de visites et de certaines correspondances) avec sursis infligés à un détenu qui s'était plaint d'un refus de soins dentaires en raison de la nature et de la gravité de cette mesure (CE 1995 Marie) ;
- le changement d'affectation d'un détenu d'un établissement pour peines à une maison d'arrêt car il entraîne des différences substantielles de régime de détention qui constituent incontestablement un durcissement des conditions de détention (CE 2007 garde des Sceaux c M. Boussouar).

Au contraire, constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de REP :

- le changement de groupe de TD d'un étudiant (CE 1967 Bricq) ;
- des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ou encore des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature (CE 2007 Garde des sceaux c M. Boussouar).

Les mesures purement gracieuses ne sont pas non plus susceptibles de recours.

1B4. Les mesures gracieuses

Le Conseil d'État a récemment restreint cette notion en décidant que si l'administration fait application d'un texte il ne s'agit pas d'une « mesure purement gracieuse » quand bien même elle se serait écartée de la stricte application de la loi (CE 2009 Gerbault : à propos de la délivrance d'un récépissé d'une demande déposée hors délai).

On peut le critiquer dans la mesure où c'est souvent le refus d'accorder un avantage supérieur, le refus ou la suppression d'un avantage qui sont contestés. Par conséquent le caractère totalement positif de la mesure pour l'intéressé est discutable. De plus, il peut paraître contestable de faire échapper au contrôle du juge des mesures prises en dehors du droit (non prévues par un texte). D'un autre côté, admettre la possibilité d'un recours en justice contre de tels actes risquerait de dissuader l'administration de prendre des mesures de bienveillance. La situation des intéressés ne serait pas, au final, plus favorable.

Il existe une dernière catégorie d'actes ne faisant pas grief.

1B5. Les actes entourant un acte administratif unilatéral décisoire

En principe, ces actes n'ont pas de caractère décisoire sauf s'ils s'imposent à leur destinataire. Il s'agit, d'une part, des actes préparatoires, tels l'annonce d'un projet (CE 1988 Ville d'Amiens :

communiqué par lequel un ministre rend public le tracé du TGV) ou une mise en demeure lorsqu'elle laisse l'issue de la procédure incertaine (CE 1987 Département de la Moselle : mise en demeure d'une collectivité locale par une chambre régionale des comptes pour non-inscription d'une dépense obligatoire car l'inscription d'office par le Préfet n'est pas certaine).

D'autre part, ce sont les actes qui sont la suite d'une décision telle que la notification d'une décision.

Une autre distinction importante, parmi les actes administratifs unilatéraux, est celle des actes express et tacites.

2. Les décisions expresses et tacites

Les actes administratifs unilatéraux explicites peuvent prendre une forme écrite (décret, arrêté, délibération, lettre), orale ou gestuelle comme le signe réalisé par un agent qui règle la circulation à un carrefour.

Les actes administratifs unilatéraux peuvent aussi être implicites. C'est ainsi que pendant longtemps le silence gardé par l'administration valait décision de rejet.

Le délai à l'expiration duquel naît le refus est de deux mois depuis la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (autrefois il était de 4 mois) mais il peut être différent. Par exemple, l'absence de réponse à une demande de communication d'un document administratif vaut refus de le transmettre au bout d'un mois en vertu de la loi du 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs.

Par exception, le silence gardé par l'administration pouvait donner naissance à une décision d'autorisation si un texte le prévoit. C'est le cas, par exemple, pour les permis de construire dans certaines conditions.

L'exception est devenue la règle depuis la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens. Cette nouvelle règle entrera en vigueur un an après la promulgation de la loi pour l'État et deux ans après celle-ci pour les collectivités locales.

Toutefois, nombre d'exceptions sont prévues :

- lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;
- lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;
- si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
- dans les cas, précisés par décret en Conseil d'État, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;
- dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

De plus, des décrets en Conseil d'État et en conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter l'application de la nouvelle règle eu égard à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration.

Des décrets en Conseil d'État peuvent également fixer un délai différent de celui de 2 mois, lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie.

Une dernière classification présente un intérêt pratique important.

3. Les décisions réglementaires et celles non réglementaires

La distinction entre les décisions réglementaires (3A) et celles qui n'ont pas ce caractère (3B) revêt un intérêt pratique indéniable car leur régime juridique est différent.

3A. **Les décisions réglementaires**

Un acte réglementaire est un acte qui pose des règles générales et impersonnelles. Il peut concerner une ou plusieurs personnes non précisées, tels l'arrêté d'un maire instaurant un sens interdit ou le décret fixant les conditions d'avancement d'un corps de fonctionnaire.

Un acte relatif « à l'organisation d'un service public » est toujours considéré comme réglementaire même s'il concerne une personne nominativement désignée. Ainsi de l'arrêté portant délégation de signature (CE 1990 de Marin).

L'acte réglementaire doit être distingué d'autres catégories d'actes.

3B. **Les décisions non réglementaires**

Il s'agit des actes individuels (3B1) et de ceux qui ne sont ni réglementaires ni individuels (3B2).

3B1. Les actes individuels

L'acte administratif individuel est celui qui vise une ou plusieurs personnes nominativement désignées comme la décision nommant un fonctionnaire, un décret d'extradition ou la liste des personnes reçues à un concours.

Il existe une catégorie d'actes hybrides.

3B2. Les actes ni réglementaires ni individuels

Ce sont des actes qui appliquent une réglementation préalable à une situation particulière. Comme les actes réglementaires, ils concernent souvent un ensemble indéterminé de personnes. À l'image des actes individuels, ils ne créent pas de règles.

Cependant, il ne s'agit ni d'actes réglementaires, ni d'actes individuels. C'est le cas, par exemple du décret convoquant les électeurs à une élection, de l'arrêté ouvrant un concours ou d'une déclaration d'utilité publique (DUP).

Ces actes obéissent à un régime juridique mixte.

Comme le règlement, ils sont publiés, ne créent pas de droit acquis et ne doivent pas être motivés.

À l'identique des actes individuels, c'est le tribunal administratif qui est compétent pour connaître du recours formé contre un tel acte pris par arrêté ministériel (CE 1971 Ville Nouvelle Est à propos d'une DUP). Leurs conditions de retrait et d'abrogation sont semblables à celles d'un acte individuel.

De même l'exception d'illégalité est, en principe, prohibée comme leur interprétation par le juge judiciaire.

C'est donc le régime juridique des actes administratifs unilatéraux qu'il convient maintenant d'examiner.

À retenir

L'acte administratif unilatéral peut être défini comme l'acte destiné à créer des droits ou obligations à l'égard de ses destinataires et qui est pris par une personne publique agissant en tant qu'autorité administrative, c'est-à-dire dans un domaine administratif (non gouvernemental, législatif ou juridictionnel), exception faite des actes intéressant les rapports individuels entre un SPIC et ses usagers ou agents. Il peut également s'agir de l'acte juridique édicté unilatéralement par une personne privée qui gère un SPA s'il met en œuvre une prérogative de puissance publique ou qui gère un SPIC s'il s'agit d'un acte réglementaire qui concerne l'organisation du service.

Il existe différentes catégories d'actes administratifs unilatéraux. Tout d'abord, seuls ceux qui ont un caractère décisoire, c'est-à-dire qui modifient l'ordonnement juridique peuvent faire l'objet d'un REP. N'ont pas un tel caractère la circulaire non impérative (acte par lequel un chef de service explique à ses subordonnés comment appliquer un texte et ce, sans imposer de prescription), la directive (texte par lequel un chef de service fixe une ligne de conduite pour prendre des décisions individuelles dans le cadre d'un pouvoir discrétionnaire), la mesure d'ordre intérieur (assure l'ordre interne d'un organisme), la mesure gracieuse (prise en dehors d'un texte pour accorder un avantage), l'acte préparatoire ou confirmatif. Ensuite, il existe des actes administratifs unilatéraux express et tacites (résultant du silence de l'administration). Enfin, on distingue les actes réglementaires (actes qui posent des règles générales et impersonnelles) des actes non réglementaires : actes individuels (visent une ou plusieurs personnes nominativement désignées) et actes ni réglementaires ni individuels (appliquent une réglementation à une situation particulière).

CHAPITRE 2 Le régime juridique de l'acte administratif unilatéral

L'élaboration (section 1), l'exécution (section 2) et la disparition (section 3) des actes administratifs unilatéraux sont régies par des règles particulières.

SECTION 1. L'élaboration de l'acte administratif unilatéral

L'édition d'un acte administratif unilatéral est soumise à des règles de compétence (1), de forme (2), de procédure (3), de motivation (4) et de délais (5).

1. Les règles de compétence

Il faut distinguer les règles normales de compétence (1A) de celles qui s'appliquent dans certaines hypothèses particulières (1B).

1A. L'autorité initialement compétente

L'autorité compétente pour prendre un acte peut varier (1) et celle-ci peut être tenue de le prendre (2).

1A1. La désignation de l'autorité compétente

L'autorité compétente pour prendre un acte est celle désignée pour ce faire par les textes à trois points de vue :
D'abord territorialement. Par exemple, un maire ne peut pas prendre un arrêté qui concerne une commune voisine.

Ensuite, matériellement. Une autorité ne peut pas intervenir dans un domaine qui n'est pas le sien. Enfin, temporellement, la compétence n'est valable que pendant l'exercice des fonctions.

Cependant, dans l'attente de l'installation d'une nouvelle autorité, son prédécesseur peut rester en fonction. Ainsi jusqu'à la constitution d'un nouveau gouvernement le gouvernement démissionnaire peut expédier les « affaires courantes », c'est-à-dire prendre les décisions que n'importe quel gouvernement aurait pris (par exemple le tableau d'avancement d'un corps de fonctionnaire).

Dans le silence des textes, l'autorité compétente pour modifier ou faire disparaître un acte administratif unilatéral est celle qui est compétente pour le prendre. C'est la règle du parallélisme des compétences ou principe de l'acte contraire ou inverse. Cette règle ne joue pas pour le refus de prendre une décision (CE 1985 Commune de Digne : un ministre peut refuser le changement de nom d'une commune alors que c'est le Premier ministre qui peut accorder ce changement).

L'autorité administrative n'est pas toujours libre d'exercer ses prérogatives.

1A2. Les pouvoirs de l'autorité compétente

Dans certaines hypothèses, l'administration peut décider d'exercer ou non ses prérogatives et elle peut agir dans un sens ou un autre (tout en respectant, bien sûr, le principe de légalité). Elle bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire (mais non arbitraire). C'est le cas, par exemple pour l'avancement au choix d'un fonctionnaire ou la notation d'une copie.

Dans d'autres cas, l'autorité administrative est en situation de compétence liée, c'est-à-dire qu'elle doit agir dans un sens donné. Ainsi, par exemple, le Gouvernement doit prendre, dans un délai raisonnable, les règlements nécessaires à l'application d'une loi. Si l'administration s'abstient d'agir, un texte peut prévoir une substitution d'action au profit de l'autorité supérieure. Par exemple, le Préfet peut inscrire d'office au budget d'une collectivité locale une dépense obligatoire qu'elle a refusé de voter. Il peut également prendre à la place d'un maire les mesures de police qui s'imposent.

Il existe d'autres situations de substitution de compétence.

1B. Les transferts de compétence

Les pouvoirs d'une autorité absente (1B1) ou surmenée (1B2) peuvent être transférés à une autre autorité. Une théorie d'origine jurisprudentielle valide également d'autres transferts de compétence (1B3).

1B1. L'absence de l'autorité normalement compétente

Une autorité absente peut être remplacée dans le cadre de la suppléance (a) ou de l'intérim (b).

≡ La suppléance (a)

Elle est organisée par un texte qui désigne à l'avance l'autorité qui suppléera celle absente. Par exemple, en cas de vacance ou d'empêchement du chef de l'État, le président du Sénat assure les fonctions de ce dernier en vertu de l'article 7 de la Constitution. Cette hypothèse est une suppléance même si elle est souvent qualifiée d'intérim.

Le suppléant dispose des mêmes pouvoirs que l'autorité qu'il remplace, sauf si le texte qui prévoit la suppléance en décide autrement. Ainsi, le président du Sénat ne peut pas prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale ou organiser un référendum sur le fondement de l'article 11 de la Constitution (en cas d'empêchement temporaire) ni réviser la Constitution (si l'empêchement est déclaré définitif).

La même limite s'applique à l'intérim.

≡ L'intérim (b)

Il est librement organisé par l'autorité supérieure à celle absente. Ainsi le chef de l'État peut désigner un ministre pour remplacer le Premier ministre empêché.

Afin d'alléger sa tâche, une autorité administrative peut déléguer ses compétences à l'un de ses subordonnés.

1B2. La délégation

Elle est soumise à plusieurs conditions (a) et produit différents effets (b).

≡ Les conditions de la délégation (a)

Elle doit, d'abord, être autorisée par un texte. Par exemple, l'article 13 de la Constitution prévoit que le Président de la République peut déléguer au Premier ministre son pouvoir de nomination à certains emplois. Ensuite, elle doit préciser l'autorité délégataire et les pouvoirs qui lui sont transférés. S'agissant de ce dernier point, la délégation ne peut pas concerner l'ensemble des pouvoirs d'une autorité.

Enfin, la délégation doit être publiée.

Lorsque ces différentes conditions sont satisfaites, la délégation emporte plusieurs conséquences.

≡ Les effets de la délégation (b)

S'agissant de sa durée, une délégation de pouvoir ou délégation de compétence qui est toujours conférée à titre temporaire (au titulaire d'une fonction : le secrétaire général de la préfecture, par exemple) ne prend pas fin avec le changement du délégataire ou du délégant.

Au contraire, la délégation de signature qui est réalisée *intuitu personae* (à M. Durand, secrétaire générale de la préfecture, par exemple) prend fin si l'un de ces changements se produit. Toutefois, une telle règle entraîne une certaine lourdeur puisqu'elle implique de refaire toutes les délégations de signature, par exemple, en cas de remaniement ministériel. C'est pourquoi un décret du 27 juillet 2005 est venu décider que certains fonctionnaires d'un ministère (directeur, secrétaire général, directeur adjoint, sous-directeur, chef de service) disposent, à compter de leur entrée en fonction, d'une délégation de signature de plein droit qui concerne tous les actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, à l'exception des décrets et des marchés de l'État.

Concernant l'exercice des pouvoirs délégués, trois précisions doivent être apportées.

En premier lieu, la délégation de pouvoir entraîne le dessaisissement du délégant alors que dans la délégation de signature, le délégant peut toujours décider pour le délégataire.

Ensuite, dans le cas de la délégation de pouvoir, le délégataire prend les décisions en son nom propre alors que pour la délégation de signature le délégataire agit au nom du délégant.

Enfin, sauf texte contraire, le titulaire d'une délégation de pouvoir peut subdéléguer ses prérogatives mais seulement sous la forme d'une délégation de signature alors que le titulaire d'une délégation de signature ne peut pas agir ainsi. Cependant, le décret du 27 juillet 2005 est venu donner cette faculté aux fonctionnaires qui disposent d'une délégation de signature de plein droit.

En cas d'absence d'une autorité administrative une autre théorie peut s'appliquer.

La Délégation

Conditions	1. Doit être autorisée par un texte 2. Doit préciser le délégataire et ses pouvoirs 3. Doit être publiée	
Durée	Délégation de pouvoir Ne prend pas fin en cas de changement du délégant ou délégué	Délégation de signature Prend fin en cas de changement sauf pour certaines fonctions
Étendue des pouvoirs	– Dessaisissement du délégant – Action au nom du délégataire – Subdélégation possible sous forme de délégation de signature	– Le délégant peut toujours décider – Action au nom du délégant – Pas de subdélégation sauf pour certaines fonctions

1B3. La théorie du fonctionnaire de fait

Cette théorie jurisprudentielle permet de valider des décisions qui auraient dû être considérées comme prises par une autorité incompétente. Cette théorie permet ainsi de déclarer légaux les actes pris par une personne dont l'apparence laissait penser qu'elle était régulièrement investie de la compétence pour les prendre (C. Cass. 1883 affaire des mariages de Montrouge : mariages célébrés par un conseiller municipal dont la délégation était irrégulière) et les actes imposés par la nécessité en période de « circonstances exceptionnelles » (CE 1948 Marion : réquisitions prises par des habitants d'un village dont les membres du conseil municipal s'étaient enfuis au cours de la débâcle de 1940).

L'élaboration des actes administratifs unilatéraux est également soumise à des règles de forme.

2. Les règles de forme

La forme d'un acte administratif unilatéral est libre sauf règle contraire. Par exemple, une délégation de pouvoir doit nécessairement être écrite puisqu'elle doit être publiée.

Un acte écrit doit être signé par son auteur et être contresigné pour certains actes du chef de l'État et du Premier ministre.

D'autres obligations concernent la procédure de l'acte.

3. Les règles de procédure

L'administration peut être tenue de demander l'avis d'une autre autorité (3A) ou de l'intéressé (3B).

3A. La procédure consultative

La consultation peut être facultative. Par exemple, le Gouvernement peut décider de consulter le Conseil d'État sur une question juridique comme il l'a fait pour le port du voile islamique dans les écoles. Dans une telle hypothèse, l'administration peut prendre une décision différente de celle soumise pour avis, statuer avant que l'avis ne soit rendu et elle n'est pas tenue de suivre l'avis donné. Si elle s'estime liée par l'avis, sa décision est nulle car elle se dessaisit de sa compétence.

La consultation peut être obligatoire. Ainsi, l'avis du Conseil d'État doit être recueilli pour les projets de loi en vertu de l'article 39 de la Constitution. L'administration peut, ici, suivre l'avis (dit simple), ne pas s'y conformer et prendre une décision conforme à son projet soumis pour avis ou s'abstenir de prendre une décision.

Enfin, s'il s'agit d'un avis conforme, l'administration doit obligatoirement statuer dans le sens de l'avis rendu (sauf s'il est illégal) ou ne pas prendre de décision. Ainsi, un maire doit suivre l'avis de l'architecte des bâtiments de France pour délivrer un permis de construire concernant un terrain situé à proximité d'un monument historique.

Un décret de 2006 relatif à la création, la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif (modifié par un décret de 2009) a prévu pour le 9 juin 2009 la suppression des organismes consultatifs créés par voie réglementaire avant le 9 juin 2006 avec quelques exceptions (notamment les instances de dialogue social avec les agents publics) car « notre pays souffre d'une accumulation et d'une stratification des organismes consultatifs » (circulaire du Premier ministre de décembre 2008). Ce texte prévoit que tout nouvel organe consultatif doit être créé par décret, pour une période maximale de 5 ans et après étude attestant de l'intérêt de sa création. Plusieurs décrets sont donc intervenus pour recréer à compter du 9 juin 2009 les commissions administratives consultatives qui méritaient d'être pérennisées.

Suite aux recommandations du deuxième CIMAP (comité interministériel de modernisation de l'action publique) qui avait préconisé la suppression de 101 organismes, 64 commissions administratives consultatives comme celle relative aux marchés publics ont été supprimées en mai 2013.

La loi de 2011 sur la simplification du droit prévoit que l'administration peut décider de remplacer la consultation obligatoire d'un organisme consultatif pour un projet d'acte réglementaire par une consultation ouverte à tous sur un site internet pendant au moins 15 jours.

C'est également parfois l'avis de la personne concernée par la décision qui doit être recueilli.

3B. La procédure contradictoire

Il peut s'agir d'une consultation collective (3B1) ou individuelle (3B2).

3B1. La consultation collective

Elle s'impose pour de nombreux projets susceptibles d'affecter l'environnement. Ainsi, avant de prendre une déclaration d'utilité publique, l'administration doit recueillir l'opinion des habitants en procédant à une enquête publique.

Une loi de décembre 2012 impose la publicité des projets des actes réglementaires de l'État, de ses établissements publics et des autorités administratives indépendantes relatifs à l'environnement afin que le public puisse adresser à l'administration ses observations.

Une liste des consultations programmées doit être faite tous les 3 mois. Le texte accompagné d'une note de présentation est mis à disposition via internet ou une consultation papier pour ceux qui le souhaitent. La consultation doit durer au moins 21 jours et donne lieu à une synthèse des observations faisant état de celles prises en considération.

La consultation concerne parfois une seule personne.

3B2. La consultation individuelle

Elle s'impose lorsque l'administration prend une décision en considération de la personne (a) ou devant être motivée (b).

≡ Les décisions prises en considération de la personne (a)

Il s'agit, pour l'essentiel de sanctions. Dans cette hypothèse, l'administration doit respecter les droits de la défense, c'est-à-dire informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et lui permettre de présenter ses observations dans un délai raisonnable (CE 1944 Dame veuve Trompier Gravier : illégalité du retrait de l'autorisation d'exploiter un kiosque sur la voie publique sans que l'intéressé ait pu discuter les griefs formulés contre elle).

Il peut parfois s'agir de décisions qui ne constituent pas des sanctions, tel le fait de mettre fin aux fonctions du directeur de l'Agence France Presse pour convenance politique en dehors de toute considération disciplinaire (CE 1949 Nègre).

Une autre catégorie de décision ne peut être prise qu'après que l'intéressé ait été entendu.

≡ Les décisions devant être motivées (b)

Le décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers puis la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ont décidé que les décisions devant être motivées en vertu de la loi de 1979 sur la motivation des actes administratifs ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites et, s'il le souhaite, orales avec la représentation de la personne de son choix.

Cette obligation ne joue pas :

- si la décision est prise sur la demande de l'intéressé ;
- s'il s'agit d'un agent public ;
- en cas d'abus, d'urgence, de circonstances exceptionnelles, de nécessités liées à la conduite des relations internationales ou à l'ordre public ;
- si un autre texte prévoit une garantie identique (cas en matière d'extradition avec la loi du 10 mars 1927) ;
- si l'administration était tenue de prendre cette décision (hypothèse de compétence liée).

Il importe donc de savoir quelles décisions doivent être motivées selon la loi de 1979.

4. Les règles de motivation

L'obligation de motivation impose à l'administration de préciser dans un acte les raisons qui l'ont conduit à l'adopter.

Cette obligation a pour but de permettre une meilleure information de l'administré (pouvant éviter ainsi un inutile conflit), d'obliger l'administration à ne pas prendre des mesures pour des « raisons invouables » et de faciliter le contrôle du juge.

Cependant, la jurisprudence a toujours jugé qu'il n'y a pas d'obligation de motivation sauf exception jurisprudentielle ou textuelle. Parmi les textes imposant une motivation, on citera l'article 27 du Code Civil pour le refus de naturalisation, l'article L. 2121-6 du CGCT pour la dissolution des conseils municipaux et surtout la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public qui décide que plusieurs décisions doivent être motivées (4A) d'une certaine façon (4B).

4A. Le champ d'application de l'obligation de motivation

La loi de 1979 impose la motivation de plusieurs types d'actes (4A1) sauf exceptions (4A2).

4A1. Les actes concernés

Il s'agit, d'une part, des décisions individuelles défavorables à leur destinataire lorsqu'elles :

- restreignent l'exercice d'une liberté publique (c'est le cas des mesures de police) ;
- infligent une sanction ;
- subordonnent une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions (cas d'un permis de construire assorti de prescriptions) ;
- retirent ou abrogent une décision créatrice de droit ;
- opposent une prescription ;
- refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour ceux qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (par exemple, opposition à l'acquisition de la nationalité française par mariage) ;
- refusent une autorisation (cas, par exemple, du refus de déroger à la sectorisation scolaire).

Doivent, d'autre part, être motivées les décisions individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement, telle la dérogation au repos dominical.

La loi de simplification du droit du 17 mai 2011 ajoute, par ailleurs, dans les décisions devant être motivées le rejet d'un recours administratif préalable obligatoire.

Certaines de ces décisions peuvent, dans certains cas, ne pas être motivées.

4A2. Les exceptions

L'obligation de motivation ne s'impose pas :

- en cas d'urgence absolue mais l'intéressé peut, dans le délai du recours contentieux, demander à ce que lui soient communiqués les motifs de la décision dans le délai d'un mois .
- aux décisions implicites qui, par définition, ne peuvent pas être motivées. Cependant, là encore, l'intéressé peut demander que les raisons du refus lui soient données dans les mêmes délais ;
- si le secret (médical, professionnel, de la défense...) l'exige.

Pour être valable la motivation doit respecter certaines règles.

4B. Les modalités de la motivation

La motivation doit être écrite et explicite. Elle doit notamment, selon la loi de 1979, comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement.

L'acte administratif doit parfois respecter certains délais.

5. Les délais

Le silence gardé par l'administration pendant un certain délai peut donner naissance à une décision de refus ou d'acceptation.

Il peut également arriver qu'un délai soit donné à l'administration pour édicter un acte. En principe, un tel délai n'est qu'indicatif. Il n'en va autrement que si un texte le précise. Ainsi, en vertu de l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement ne peut plus prendre d'ordonnance après le délai fixé par la loi d'habilitation.

L'exécution de l'acte peut également susciter plusieurs questions.

SECTION 2. L'exécution de l'acte administratif unilatéral

Un acte administratif unilatéral produit ses effets à compter de son entrée en vigueur (1). Son exécution peut être source de difficultés (2).

1. L'entrée en vigueur de l'acte administratif unilatéral

Un acte administratif unilatéral est normalement applicable dès l'accomplissement des formalités de publicité (1A). Cette entrée en vigueur ne peut pas, en principe, avoir d'effet rétroactif (1B).

1A. La publicité de l'acte administratif unilatéral

Les cas des actes réglementaires (1A1) doivent être distingués de ceux qui n'ont pas un tel caractère (1A2).

1A1. Les actes réglementaires

La publication d'un acte réglementaire peut être faite de différentes façons (a) et produit certains effets (b).

≡ Les modalités de la publication (a)

S'agissant des décrets et ordonnances (pour celles de l'article 38 seules susceptibles d'avoir un caractère réglementaire), ils doivent être publiés au JO en vertu d'un décret — loi de 1870. Cette règle vaut également pour les décrets qui constituent un acte non réglementaire.

Pour les actes réglementaires des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des EPCI, ils doivent être publiés dans un recueil des actes administratifs ainsi qu'en décide la loi du 6 février 1992.

Les autres actes réglementaires doivent faire l'objet d'une « publication adéquate ». Par exemple, s'agissant d'un arrêté concernant l'Éducation nationale une publication au BOEN (bulletin officiel de l'Éducation nationale) suffit.

En application de l'ordonnance du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, un décret du 29 juin 2004 a décidé que certains actes pouvaient faire l'objet seulement d'une publication sous forme électronique qui suffit à les faire entrer en vigueur. Il s'agit, par exemple, des actes (réglementaires ou non) relatifs au budget de l'État (décrets et arrêtés concernant les répartitions, annulations, virements ou transferts de crédits, les fonds de concours...) ou à son organisation administrative (par exemple une délégation de signatures) ainsi que des actes (réglementaires ou non) des autorités administratives indépendantes.

La publication emporte des conséquences importantes.

≡ Les effets de la publication (b)

En principe, un acte réglementaire produit des effets de droit à compter de sa publication. Toutefois, la publication d'un acte peut ne pas suffire à son entrée en vigueur.

Parfois, d'autres formalités sont nécessaires pour qu'un règlement entre en vigueur. Ainsi les actes des collectivités locales ne sont exécutoires qu'après leur transmission au Préfet ou au sous-préfet. Les règlements de police doivent faire l'objet d'une signalisation adéquate (panneaux réglementant la vitesse, peinture interdisant le stationnement...).

L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire peut également être postérieure à sa publication.

Les règlements publiés au JO n'entrent en vigueur qu'un jour franc après leur publication à Paris (une publication le 20 décembre entraîne une entrée en vigueur le 22 décembre à 0 heure) et un jour franc après que le numéro du JO soit parvenu au chef-lieu dans le reste du pays. En cas d'urgence, le Gouvernement peut, cependant, retenir la date de publication (ordonnance du 20 février 2004).

De même, un règlement peut décider qu'il n'entrera en vigueur qu'à compter d'une certaine date.

Enfin, les dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application entrent en vigueur en même temps que ces dernières (ordonnance du 20 février 2004).

Pour les actes non réglementaires, les règles peuvent être différentes.

1A2. Les actes non réglementaires

S'agissant des actes ni réglementaires ni individuels, leur entrée en vigueur est normalement subordonnée à leur publication.

Pour les actes individuels, tout dépend de leur nature.

Ceux qui sont susceptibles de conférer des droits à leur destinataire (par exemple, la nomination d'un fonctionnaire) entrent en vigueur dès leur signature.

Ceux défavorables à leur destinataire comme la révocation d'un fonctionnaire entrent en vigueur, à l'égard de ces derniers, à compter de leur notification. En revanche, vis-à-vis des tiers pour qui l'acte peut-être favorable, l'entrée en vigueur se fait dès la signature de l'acte.

Pour les actes individuels des collectivités locales qui doivent être transmis au contrôle de légalité, l'entrée en vigueur est subordonnée à cette transmission et à leur notification.

Les actes collectifs tels les résultats d'un examen entrent en vigueur avec leur affichage.

Un permis de construire express entre en vigueur à compter de sa notification et de son affichage en mairie et sur le terrain concerné.

Enfin, les décisions implicites entrent en vigueur dès leur naissance (et leur affichage s'il s'agit d'un permis de construire).

En principe, un acte administratif unilatéral ne produit d'effets que pour l'avenir.

1B. La non-rétroactivité de l'acte administratif unilatéral

La non-rétroactivité des actes administratifs unilatéraux constitue un PGD (CE 1948 Société du journal l'Aurore).

Par exception, un acte administratif unilatéral est rétroactif :

- si une loi le prévoit ;
- s'il opère un retrait. Dans ce cas, l'acte retiré est censé n'avoir jamais existé ;
- s'il tire les conséquences d'une annulation juridictionnelle. Par exemple, lorsque l'administration reclasse un agent dont la révocation a été censurée au contentieux ;
- si le caractère rétroactif est « indispensable » (CE 1979 Association des professeurs agrégés des disciplines artistiques : à propos d'enseignants nommés avant que leurs obligations de service ne soient définies, le juge décide que l'administration peut donner un caractère rétroactif au règlement définissant ces obligations afin de pouvoir établir leur rémunération).

Une fois entré en vigueur, l'acte administratif unilatéral peut poser problème pour son exécution.

2. Les difficultés d'exécution de l'acte administratif unilatéral

L'administration peut rencontrer des oppositions à l'exécution d'un acte administratif unilatéral. Le juge judiciaire peut être confronté à un acte administratif (2A). Enfin, un particulier peut éprouver des difficultés pour obtenir communication d'un document administratif (2B).

2A. La contestation de l'exécution

L'exécution d'un acte administratif unilatéral peut être entravée par des administrés, soit parce qu'ils ont formé une demande de suspension de cet acte (2A1), soit parce qu'ils refusent de s'y soumettre (2A2).

2A1. Le référé suspension

Le particulier qui contestait un acte administratif unilatéral pouvait, à l'appui d'un recours en annulation contre cet acte, déposer une demande de sursis à exécution s'il invoquait un moyen sérieux de nature à entacher l'acte de nullité et si l'exécution de l'acte était de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable. Ces conditions étant strictement appréciées, le sursis était rarement accordé.

Depuis 2000, la procédure du sursis à exécution a été remplacée par celle du référé suspension (voir supra les pouvoirs du juge dans le cadre du référé).

Hormis par cette procédure, un particulier ne peut pas s'opposer à l'exécution d'un acte administratif unilatéral.

2A2. Le refus d'exécution

L'administré qui n'exécute pas un acte administratif unilatéral s'expose à certaines sanctions (a) et peut se voir contraint d'exécuter l'acte (b).

≡ Les sanctions de l'inexécution (a)

L'administration peut prononcer des sanctions administratives telles que la suspension du permis de conduire ou la fermeture d'un établissement.

Le juge peut également infliger des sanctions pénales à ceux qui, par exemple, auront contrevenu aux décrets et arrêtés de police légalement faits, se seront soustraits à un arrêté d'expulsion ou auront refusé de déférer à une réquisition.

Dans certains cas, l'administration peut contraindre le récalcitrant par la force.

≡ L'exécution forcée (b)

L'exécution forcée par l'administration d'une de ses décisions peut être autorisée dans deux cas.

D'une part, par une loi. Ainsi, par exemple, la loi de 1877 sur les réquisitions militaires prévoit que les réquisitions peuvent être assurées par la force et l'ordonnance de 1945 rend possible l'expulsion ou la reconduite à la frontière manu militari.

D'autre part, la jurisprudence a défini deux situations où l'exécution d'office était possible.

À propos de l'évacuation forcée d'une congrégation religieuse non autorisée d'un immeuble qu'elle occupait, le juge a décidé que la validité de l'exécution d'office était subordonnée à plusieurs conditions (TC 1902 Société immobilière de Saint-Just) :

- l'administré après avoir été mis en demeure continue de s'opposer à l'exécution de l'acte ;
- l'administration ne dispose pas d'autres solutions (notamment, aucune sanction administrative ou pénale n'est prévue) ;
- l'acte dont l'exécution d'office est prévue doit avoir son fondement dans un texte précis ;
- l'exécution d'office doit être limitée à ce qui est juste nécessaire pour que ce texte soit appliqué.

L'urgence est la seconde situation justifiant une exécution d'office indépendamment de l'absence de mise en demeure de l'administré ou de l'existence de sanctions (TC 1954 Office publicitaire de France : lacération d'affiches hostiles à l'OTAN apposées le long du trajet que devait emprunter un général américain).

Le juge judiciaire peut être amené à connaître de l'exécution d'un acte administratif unilatéral.

2B. L'attitude du juge judiciaire face à l'acte administratif unilatéral

Il se peut que le juge judiciaire saisi d'un litige relevant de sa compétence ait à examiner un acte administratif unilatéral pour rendre sa décision. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, il devrait s'agir d'une question préjudicielle obligeant le juge judiciaire à surseoir à statuer et à renvoyer la question au juge administratif. Cependant, l'adage selon lequel « le juge de l'action est juge de l'exception » voudrait qu'il s'agisse d'une question préalable à laquelle le juge judiciaire doit répondre.

L'état du droit est une combinaison de ces deux solutions. Les prérogatives du juge judiciaire face à un acte administratif unilatéral ne sont pas les mêmes selon qu'il statue en matière civile (2B1) ou pénale (2B2).

2B1. Les pouvoirs du juge civil

Ils ont été précisés par une décision du Tribunal des conflits (TC 1923 Septfonds relatif à un arrêté ministériel concernant la perte de marchandises dans le transport ferroviaire). Il faut distinguer le cas où le juge civil doit interpréter un acte administratif unilatéral (a) de celui où il doit juger de sa légalité (b).

≡ L'interprétation de l'acte administratif unilatéral (a)

S'agissant des actes réglementaires, le juge civil peut les interpréter, selon la jurisprudence Septfonds, parce que le juge civil pouvant interpréter les lois qui sont des normes générales et impersonnelles, il est logique qu'il en soit de même pour les règlements qui présentent également ces caractères.

Pour les actes non réglementaires, le juge civil ne peut pas les interpréter sauf en matière de contrôle des impôts indirects qui est de la compétence du juge judiciaire.

L'appréciation de la légalité d'un acte administratif unilatéral par le juge civil est encore plus restreinte.

≡ L'appréciation de la légalité de l'acte administratif unilatéral (b)

Ce pouvoir permet au juge judiciaire d'écarter l'application, à une affaire, d'un acte administratif (mais non de l'annuler). Elle n'est pas possible aussi bien pour les actes réglementaires que pour ceux qui n'ont pas ce caractère. Matter, dans ses conclusions sur la décision Septfonds, justifiait cette différence de traitement par le fait que « L'interprétation ne trouble pas, car elle suit, se conforme, applique. La déclaration d'illégalité refuse cette application, elle écarte le règlement, elle trouble l'opération du corps administratif ».

Il existe, cependant, quatre exceptions à cette interdiction :

- si l'acte en cause constitue une voie de fait ;
- si l'acte concerne le contentieux des impôts indirects qui relève du juge judiciaire ;
- s'il s'agit d'un règlement contraire au droit européen ou international ;
- s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge judiciaire (TC 2011 Soc. Green Yellow à propos du principe de non-rétroactivité des actes administratifs).

Le juge pénal bénéficie de pouvoirs plus étendus.

2B2. Les pouvoirs du juge pénal

Les solutions ont été données également par une décision du Tribunal des conflits (TC 1951 Avranches et Desmarests concernant deux personnes poursuivies pour délit de chasse). Ces solutions (a) se sont heurtées à la position de la chambre criminelle de la Cour de Cassation et ont été partiellement remises en cause par la loi (b).

≡ La jurisprudence du Tribunal des conflits (a)

Le Tribunal des conflits avait jugé que le juge pénal ayant plénitude de juridiction sur tous les points d'où dépend l'application ou non des peines de façon à ne pas retarder le cours de la justice pénale dont les enjeux (privation de liberté) peuvent être importants, il devait interpréter et apprécier la légalité des actes réglementaires ainsi qu'interpréter les actes non réglementaires.

La juridiction de partage pouvait justifier sa décision par l'article R 26-15e du Code pénal dans son ancienne rédaction qui prévoyait des sanctions pour ceux qui ont contrevenu aux « règlements de police légalement faits ». Cette formulation impliquait que le juge pénal puisse apprécier la légalité du règlement. Toutefois, le Tribunal a étendu cette compétence à tous les règlements même étrangers à la police.

En revanche, le Tribunal des conflits a décidé que le juge pénal ne pouvait pas apprécier la légalité d'un acte non réglementaire, sauf disposition législative contraire.

Cette solution n'est plus totalement d'actualité.

≡ Les oppositions (b)

La chambre criminelle de la Cour de Cassation avait décidé de limiter l'interprétation des actes réglementaires et l'appréciation de leur légalité à l'hypothèse où ils sont assortis de sanctions pénales dont le prononcé est demandé (Cass . crim . 1967 Canivet). Dès lors, qu'un acte réglementaire était invoqué comme moyen de défense et non plus comme fondement à la poursuite, le juge pénal devenait incompétent. Cette position était donc plus étroite que celle de la juridiction de partage qui déclarait expressément que le juge pénal était compétent dans les deux cas.

À la différence du Tribunal des conflits, la chambre criminelle donnait également compétence au juge pénal pour apprécier la légalité d'un acte administratif individuel dans la mesure où il était assorti de sanctions pénales dont le prononcé était demandé (Cass . crim . 1961 Dame Leroux). Cette position pouvait s'appuyer sur la nouvelle rédaction de l'article R 26-15e du Code pénal instituant des peines à l'encontre de ceux qui ont « contrevenu aux décrets et arrêtés de police légalement faits ». Le terme « contrevenu » implique une poursuite et la substitution des termes « décrets et arrêtés » à celui de « règlement » permet d'inclure les actes individuels puisqu'un décret ou un arrêté peuvent aussi bien constituer des actes réglementaires qu'individuels.

La loi du 22 juillet 1992 portant réforme du Code pénal a mis fin à cette querelle. En effet, l'article 111-5 du Nouveau Code pénal entré en vigueur en 1994 décide que le tribunal statuant en matière répressive a compétence « pour interpréter les actes administratifs réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal » qui lui est soumis.

Une dernière difficulté que l'on peut rattacher à l'exécution des actes administratifs est celle de leur communication.

Juge Civil TC 1923 Sept fonds			Juge Pénal TC 1951 Avranches et Desmarests et nouveau code pénal	
	Interprétation	Appréciation de la légalité	Interprétation	Appréciation de la légalité
Acte réglementaire	Oui	Non sauf si : – Voie de fait – Impôt indirect – Règlement contraire au droit européen – Illégalité établie par une jurisprudence bien fixée	Oui	Oui
Acte non réglementaire	Non sauf si impôt indirect		Oui	Oui

2C. La communication des documents administratifs

Le secret de l'action administrative a été largement atténué avec la loi du 17 juillet 1978 relative à l'amélioration des relations des administrés avec l'administration. Cette loi a été précisée par celles du 6 février 1992 relatif à l'administration territoriale de la République et du 12 avril 2000 relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ces textes précisent les documents qui peuvent être communiqués aux administrés (2C1) et le régime de cette communication (2C2).

2C1. La notion de document communicable

Seuls les documents administratifs peuvent être communiqués aux particuliers (a). Ceux qui n'ont pas un tel caractère sont exclus du droit à communication (b).

≡ Les documents administratifs (a)

Le droit à communication se limite aux documents administratifs.

Un document administratif ne se définit pas par sa forme. Il peut s'agir de documents écrits, sur supports informatiques et d'enregistrements sonores ou visuels.

L'auteur du document importe peu également puisqu'il peut avoir été élaboré par l'État, une collectivité locale, un établissement public et même une personne privée chargée de la gestion d'un service public. En outre, la loi de 2000 précise qu'un document administratif détenu par une administration doit être communiqué même s'il n'a pas été élaboré par elle.

Les documents administratifs se définissent par leur objet. Il s'agit d'une part des dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives et d'autre part des avis, prévisions et décisions.

Certains documents administratifs se trouvent écartés du droit à communication. Ce sont ceux :

- couverts par le secret public (défense, politique extérieure, sécurité publique, monnaie et crédit) ;
- qui sont mis à la disposition du public ou qui ont déjà fait l'objet d'une communication au demandeur ;
- réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de services (par exemple, données météorologiques vendues par Météo France) ;
- introuvables ;
- inachevés ;
- préparatoires.

Ne sont pas non plus communicables les documents qui ne présentent pas un caractère administratif.

≡ Les documents non administratifs (b)

Ne sont pas considérés comme administratifs et donc comme communicables :

- les actes régis par le droit privé tels les actes notariés ou de l'état civil ;
- les actes liés aux procédures juridictionnelles telle une mesure d'instruction ;
- les avis des juridictions administratives ;
- les actes des assemblées parlementaires.

La façon dont la communication peut se faire est également encadrée par la loi.

2C2. Le régime de la communication

La loi a précisé les personnes qui peuvent obtenir communication d'un document administratif (a) ainsi que les modalités de cette communication (b).

≡ Les personnes concernées (a)

Ne sont communicables qu'aux intéressés les documents administratifs comportant des informations nominatives, c'est-à-dire :

- une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable (cas d'une copie d'examen) ;
- portant atteinte aux secrets médical, commercial, industriel ou de la vie privée.

Les documents administratifs non nominatifs sont communicables à tous. Certaines règles encadrent également les modalités de la communication.

≡ Les modalités de la communication (b)

Le demandeur peut consulter gratuitement le document sur place ou en demander une copie (sous réserve que cela ne nuise pas à la conservation du document). Dans ce cas, il a le choix du support de communication (papier, disquette...). Les frais de copie sont à la charge du demandeur mais ne peuvent pas excéder le coût de la reproduction (ce qui exclut les frais d'expédition). Le demandeur peut avoir plusieurs copies mais l'administration n'est pas tenue de faire droit aux demandes abusives par leur caractère répétitif.

Au cas où l'administration refuse de communiquer un document à un administré, celui-ci peut saisir la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs) qui dispose d'un mois pour donner son avis (délai souvent non respecté). Une fois ce dernier rendu, l'administration a deux mois pour informer la CADA des suites qu'elle entend donner à son avis. Si l'administration persiste, l'administré peut former un REP contre ce refus sur lequel il devra être statué dans un délai de 6 mois. La saisine de la CADA est le préalable obligatoire avant tout recours juridictionnel.

L'acte administratif unilatéral peut disparaître dans différentes hypothèses.

SECTION 3. La disparition de l'acte administratif unilatéral

L'acte administratif unilatéral peut disparaître indépendamment de la volonté de son auteur.

C'est, d'abord, l'hypothèse de la caducité, (état d'un acte qu'un fait postérieur rend inefficace). Il s'agit, par exemple, du cas où la personne concernée par l'acte décède ou celui où elle n'a pas utilisé les droits conférés par l'acte dans le délai prévu (construction non entreprise dans les deux ans suivant la délivrance d'un permis de construire).

C'est, ensuite, l'hypothèse où l'acte fait l'objet d'une annulation juridictionnelle.

Enfin, on soulignera le cas des décisions inexistantes (décisions tellement illégales qu'elles sont considérées comme « nulles et non avenues »). Le recours contre un acte inexistant est ouvert sans délai et son retrait est toujours possible.

L'acte administratif unilatéral peut disparaître également par la volonté de son auteur ou, plus généralement, de l'administration (intervention du supérieur hiérarchique). Il s'agit de l'abrogation (1) et du retrait (2).

1. L'abrogation

L'abrogation est la disparition pour l'avenir d'un acte administratif unilatéral (l'acte cesse de produire des effets mais conserve ceux passés). L'abrogation doit se faire par un acte contraire (en respectant les principes du parallélisme des compétences et des procédures) et, s'agissant des actes individuels créateurs de droit, elle doit être motivée. L'administration peut être libre (1A) ou non (1B) de procéder à cette abrogation. Le Code des relations entre le public et l'administration de 2015 a codifié à droit constant les règles relatives à l'abrogation.

1A. L'abrogation facultative

Un acte réglementaire peut toujours être abrogé car il n'existe pas de droit acquis au maintien d'un règlement (CE 1961 Vannier : suppression de la diffusion d'émissions de télévision dans un format déterminé).

S'agissant des actes non réglementaires, il faut distinguer selon qu'ils sont ou non créateurs de droit. L'acte non réglementaire non créateur de droit peut toujours être abrogé. Il s'agit :

- des refus (de permis de construire, de séjour...);
- des décisions accordant des autorisations précaires comme les autorisations de police ou d'occupation privative du domaine public ;
- des nominations dans un emploi à la discrétion du Gouvernement (préfet, recteur...);
- des décisions conditionnelles tant que la condition n'est pas remplie ;
- des décisions obtenues par fraude (CE 1955 Silberstein : inscription à l'université sur présentation de faux diplômes) ;
- des déclarations d'utilité publique ;
- des décisions recognitives (reconnaissent l'existence d'une situation sans que leur auteur dispose d'un pouvoir d'appréciation) tels un relevé de notes ou la délimitation du domaine public naturel.

En revanche, les « décisions pécuniaires », c'est-à-dire accordant un avantage financier sur lequel l'administration n'a aucun choix sont désormais considérées comme créatrices de droit (CE 2002 Soulier).

Les décisions créatrices de droit ne peuvent être abrogées que dans cinq hypothèses. D'abord, dans les cas prévus par les textes. Ainsi pour un titre de séjour (il ne peut y être mis fin que pour des motifs d'ordre public). Ensuite, sur demande du bénéficiaire de la décision (même légale) et ce sans délai. Dans ce cas, la décision substituée doit être plus favorable et ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers. Également, dans le délai de quatre mois suivant l'intervention d'une décision expresse individuelle créatrice de droit illégale (même conditions que pour le retrait). Aussi, dans le cas où les conditions qui ont justifié leur naissance ont disparu. C'est le cas, par exemple, d'une subvention dont les conditions auxquelles elle est subordonnée ne sont plus remplies. Enfin, lorsqu'il existe un recours administratif préalable obligatoire, l'administration initiale peut procéder à l'abrogation jusqu'à l'expiration du délai imparti à l'administration supérieure pour se prononcer sur ce recours (hypothèse ajoutée par la codification de 2015).

Dans certains cas, l'administration est tenue de procéder à l'abrogation d'un acte administratif unilatéral.

1B. L'abrogation obligatoire

L'administration doit abroger un acte administratif illégal. Il faut, cependant, distinguer le cas des actes réglementaires (1B1) de ceux qui n'ont pas ce caractère (1B2).

1B1. Les actes réglementaires

Il faut dissocier le cas où l'acte est devenu illégal suite à des circonstances nouvelles (a), de celui où il est illégal dès l'origine (b).

≡ L'illégalité suite à un changement de circonstances (a)

Les règles à appliquer dans cette hypothèse ont été posées dans un arrêt de 1930 (CE 1930 Despujol à propos d'un touriste qui avait été verbalisé pour violation d'un arrêté municipal réglementant le stationnement des véhicules des touristes venus visiter le château du village). Cet arrêt distingue deux hypothèses.

Si un règlement devient illégal suite à un changement dans les circonstances de fait qui ont motivé son édicton, l'administration est tenue de satisfaire, à tout moment, une demande tendant à sa modification ou suppression formée par un administré qui y a intérêt.

Cette règle joue notamment en matière de police où les règlements doivent être adaptés à la situation. Si celle-ci change, l'administration doit en tenir compte en modifiant ou supprimant la mesure de police devenue inutile. Ainsi, par exemple, l'état d'urgence doit cesser de produire ses effets dès lors que les circonstances qui ont motivé son instauration ont disparu (CE 2005 Allouache).

Dans les domaines « où l'administration dispose de pouvoirs étendus pour adapter son action à l'évolution des circonstances de fait » (notamment en matière économique), il faut que le changement ait revêtu le caractère d'un « bouleversement » imprévisible pour justifier la modification ou la suppression de la mesure incriminée (CE 1964 Simonnet : possibilité de refuser la modification de la répartition des contingents de production de rhum entre différentes sucreries car la production de sucre et l'activité des entreprises n'a pas connu de bouleversement).

Si un règlement devient illégal suite à un changement dans les circonstances de droit (par exemple, intervention d'une loi, d'un traité ou même d'un PGD le rendant illégal), tout administré qui y a intérêt peut saisir le juge administratif d'une demande d'annulation du règlement devenu illégal dans le délai de deux

mois suivant l'intervention de l'acte qui a entraîné ce changement. Dans l'arrêt Despujol, le recours avait été rejeté comme formé hors délai car la loi invoquée n'ayant pas créé de situation juridique nouvelle, le requérant ne disposait pas d'un nouveau délai de 2 mois pour contester le règlement. Le Conseil d'État a, au contraire, fait une application positive des règles posées dans l'arrêt Despujol à propos de la loi de 1946 portant statut général des fonctionnaires qui prévoyait de réserver des concours aux fonctionnaires pour l'accès à certaines catégories d'emploi. Le décret portant statut particulier des bibliothécaires qui méconnaissait cette règle était illégal mais, faute d'avoir été attaqué dans les délais, il était devenu définitif. L'ordonnance de 1959 a repris la règle du statut de 1946 mais en l'étendant aux contractuels. Il y a donc une situation juridique nouvelle qui permet de demander la modification du décret (CE 1964 Syndicat national des cadres de bibliothèque).

L'arrêt Despujol précisait que le requérant pouvait demander seulement l'annulation du règlement dans un délai de deux mois. L'arrêt Syndicat national des cadres de bibliothèque indique qu'il peut également demander la modification du règlement dans ce délai.

Le décret du 28 juin 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers (aujourd'hui abrogé) est venu ajouter que la demande d'abrogation pouvait être faite à tout moment, ce que le Conseil d'État a validé en voyant dans cette règle un PGD (CE 1989 Compagnie Alitalia : illégalité de dispositions fiscales contraires à une directive européenne postérieure).

Enfin, le Conseil d'État a jugé que l'administration était tenue de modifier un règlement en cas de changement dans les circonstances de droit, et ce « dans un délai raisonnable » (CE 2002 Villemain à propos des changements à apporter à différents textes suite à la création du PACS).

La solution de l'arrêt Compagnie Alitalia concerne également les règlements illégaux dès l'origine.

≡ L'acte irrégulier ab initio (b)

L'arrêt Despujol n'envisageait l'obligation d'abrogation d'un règlement illégal que lorsque cette illégalité résultait d'un changement de circonstances.

Le Conseil d'État a, d'abord, eu des décisions fluctuantes en obligeant l'administration, lorsqu'un administré l'a sollicité, à abroger un règlement illégalement édicté (CE 1976 Leboucher et Tarandon). Puis il a décidé qu'il n'existait pas de telle obligation, sauf si la demande était faite dans le délai du REP (CE 1981 Société Afrique France Europe transaction).

Le décret de 1983 a édicté une telle obligation, et ce, sans condition de délai que le Conseil d'État a jugé inspirée d'un PGD (CE 1989 Compagnie Alitalia).

La loi sur la simplification du droit de 2007 prévoit l'obligation pour l'administration d'abroger les règlements illégaux ou sans objet, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé et ce, que cette situation existe dès l'origine ou suite à un changement de circonstances.

Les règles sont différentes pour les actes non réglementaires.

1B2. Les actes non réglementaires

À propos d'un acte de délimitation d'une circonscription cantonale, le Conseil d'État a décidé que l'administration est tenue d'abroger un acte administratif non réglementaire si trois conditions sont remplies (CE 1990 Association les verts).

D'abord, l'acte ne doit pas être créateur de droit. S'il est créateur de droit, il ne peut être abrogé que si son bénéficiaire le demande et dans le délai de 4 mois ou si les textes le prévoient.

Ensuite, l'illégalité doit provenir d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait (telle que l'évolution démographique imposant le redécoupage des cantons dans l'arrêt Association les verts précité). S'il est illégal dès l'origine, il n'y a aucune obligation car, pour les actes administratifs non réglementaires, l'exception d'illégalité n'existe pas.

Enfin, l'acte ne doit pas être devenu définitif (le délai juridictionnel pour le contester n'est pas expiré). Un acte administratif peut aussi être retiré.

Abrogation d'un acte administratif unilatéral

	Facultative	Obligatoire
Acte administratif réglementaire	Oui car aucun droit acquis au maintien d'un règlement : CE 1961 Vannier	Si illégal ou sans objet dès l'origine ou suite à un changement de circonstances de fait ou de droit
Acte non réglementaire non créateur de droits – Refus – Nomination dans un emploi à la discrétion du gouvernement...	Oui	Si : acte illégal suite à un changement de circonstances de droit ou de fait
Acte non réglementaire créateur de droits	Oui si : – un texte le permet – demande du bénéficiaire pour substituer un acte plus favorable et sans atteinte aux droits des tiers – l'acte est illégal et que l'administration intervient dans un délai de 4 mois – les conditions qui ont justifié l'acte ont disparu – il existe un recours administratif préalable obligatoire	Oui si : – Demande faite par l'intéressé – Acte illégal – Abrogation faite dans le délai de 4 mois

2. Le retrait

Le retrait est la disparition rétroactive d'un acte administratif. Ses règles sont différentes selon qu'il s'agit d'un acte réglementaire (2A) ou non (2B).

2A. Le retrait des actes réglementaires

La loi de codification de 2015 a modifié les règles en décidant que le retrait d'un règlement n'est possible que s'il est illégal et effectué dans le délai de 4 mois à compter de sa signature.

La situation est plus complexe pour les actes non réglementaires.

2B. Le retrait des actes non réglementaires

Si l'acte n'est pas créateur de droits, il pouvait toujours être retiré pour illégalité ou simple opportunité (CE 1947 Société Duchet : décision rejetant une demande d'autorisation).

La loi de codification de 2015 a modifié ce régime en l'alignant sur celui des décisions créatrices de droit sauf pour quelques exceptions :

- les décisions obtenues par fraude ;
- les subventions accordées sous condition si la condition ne s'est pas réalisée ;
- les sanctions infligées par l'administration peuvent toujours être retirées sans délai.

Si l'acte est créateur de droit, les règles du retrait avaient été posées par un arrêt ancien (CE 1922 Dame Cachet). Un arrêt est partiellement revenu sur la jurisprudence Cachet (CE 2001 Ternon). En plus de la motivation (loi de 1979), le retrait est subordonné à l'illégalité de l'acte (2B1) et à des conditions de délai (2B2).

2B1. L'illégalité de l'acte

Un acte individuel créateur de droits ne peut être retiré que s'il est illégal, sauf :

- autorisation législative contraire ;
- si le retrait est nécessaire pour assurer l'exécution d'une annulation juridictionnelle. Par exemple, l'annulation de la révocation d'un fonctionnaire implique sa réintégration qui peut imposer le retrait de la nomination de son successeur, notamment pour les emplois uniques comme administrateur de la comédie française ;
- si le retrait est demandé par l'intéressé lui-même à la double condition que soit substituée une décision plus favorable et qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits des tiers ;
- si l'intervention du supérieur hiérarchique de l'auteur de l'acte permet seule d'arrêter définitivement la position de l'administration. Tel est le cas si les textes organisent un recours hiérarchique permettant un retrait pour opportunité ou si le recours hiérarchique est un préalable au recours juridictionnel. La loi de simplification du droit de 2011 prévoit toutefois que l'autorité initiale peut retirer l'acte tant que l'autorité supérieure ne s'est pas prononcée mais seulement à raison de son illégalité.

À cette condition s'ajoute une condition de délai qui a été modifiée.

2B2. Les conditions de délai

L'arrêt Dame Cachet avait posé comme règle que le retrait d'un acte individuel créateur de droits illégal est possible tant que cet acte n'est pas définitif, c'est-à-dire tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ou, si le juge a été saisi pendant ce délai, tant que le juge ne s'est pas prononcé. Dans ce second cas, le retrait était limité à ce que le requérant a demandé au juge d'annuler.

Cette solution n'était pas sans poser des problèmes dans certains cas.

Tout d'abord, la solution de l'arrêt Dame Cachet implique que le retrait est possible tant que le délai contentieux court. Or, le décret du 28 novembre 1983 sur les relations entre l'administration et les usagers prévoit que les délais de recours ne sont pas opposables s'ils n'ont pas été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision. La combinaison de ces deux règles permettrait à l'administration de retirer indéfiniment un acte si elle n'a pas mentionné dans sa notification les délais ou voies de recours. Pour éviter qu'un texte voulu favorable aux administrés ne se retourne finalement contre eux, le Conseil d'État a décidé que dans cette hypothèse la possibilité de retrait restait limitée à la durée du recours contentieux (CE 1997 M^{me} de Laubier).

La loi de codification de 2015 a supprimé le régime particulier des décisions tacites. Elles sont traitées comme celles explicites à compter de 2016.

Enfin, le délai de recours contentieux peut ne pas avoir commencé à courir à l'égard des tiers si une décision notifiée à l'intéressé n'a pas été publiée. Dans ce cas, le retrait était toujours possible (CE 1966 Ville de Bagneux à propos du permis de construire d'une chapelle qui, à l'époque, n'était soumis à aucune mesure d'affichage). L'arrêt Ternon revient sur cette solution en décidant que le retrait d'une décision individuelle explicite créatrice de droit illégale n'est possible que dans un délai de quatre mois à compter de son adoption. Le retrait ne peut être opéré au-delà de ce délai que sur demande du bénéficiaire de l'acte ou en cas d'exception prévue par une loi, un règlement ou des normes européennes. L'arrêt Ternon entraîne ainsi une double rupture avec la jurisprudence Dame Cachet. D'une part, le point de départ du délai n'est plus la publicité mais la prise de décision. D'autre part, il découple le délai du retrait de celui du recours contentieux.

La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a également décidé qu'à partir du 1^{er} juillet 2007 un permis de construire explicite ou implicite ne peut être « retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur la demande explicite de son bénéficiaire ».

L'administration n'intervient pas que par la voie de l'acte unilatéral. Le contrat est aussi « un mode d'action publique et de production des normes » (titre du rapport public 2008 du Conseil d'État).

Retrait

	Acte administratif réglementaire		Acte administratif non réglementaire
Régulier	Non	Non créateur de droit	Oui si acte illégal et retrait dans les 4 mois Retrait possible sans délai pour : – les décisions obtenues par fraude – les sanctions prononcées par l'administration – les subventions accordées sous condition si la condition ne s'est pas réalisée
Irrégulier	Dans les 4 mois suivant sa signature	Créateur de droit CE 1922 Dame Cachet	Oui si : – Acte illégal sauf : – si loi contraire – si retrait nécessaire pour l'exécution d'un jugement – si demande de l'intéressé pour y substituer une décision plus favorable ne portant pas atteinte aux droits des tiers – si recours hiérarchique – Fait pendant le délai : – du recours contentieux si les délais de recours n'ont pas été notifiés à l'administré (CE 1997 Mme de Laubier) – de 4 mois à compter de l'édiction pour les actes administratifs individuels explicites ou implicites et au-delà seulement sur demande de l'administré ou exception textuelle (CE 2001 Ternon) – de 3 mois à compter de l'édiction pour les permis de construire, et au-delà sur demande du bénéficiaire (CE 2001 Ternon)

À retenir

L'élaboration d'un acte administratif unilatéral est soumise à plusieurs règles. Tout d'abord, l'acte doit être pris par une autorité compétente territorialement, matériellement et temporellement. Les règles de compétence connaissent des aménagements en cas d'absence de l'autorité normalement compétente (suppléance et intérim), d'activité importante (délégation) et de circonstances exceptionnelles (théorie du fonctionnaire de fait). Ensuite, l'administration peut avoir la possibilité ou l'obligation de consulter un organisme ainsi que la ou les personnes intéressée(s) par la décision. Enfin, l'administration est également parfois contrainte de motiver un acte individuel.

L'entrée en vigueur d'un acte administratif est subordonnée à l'accomplissement de formalités de publicité qui varient suivant la nature de l'acte. Cette application n'est jamais rétroactive sauf quelques exceptions. L'exécution d'un acte administratif peut être entravée par une demande de référé suspension faite devant le juge administratif ou un refus d'exécution de l'administré. Dans ce dernier cas, celui-ci s'expose à des sanctions administratives et pénales ou à une exécution forcée. Le juge judiciaire peut également lors d'un litige qui relève de sa compétence être confronté à un problème d'interprétation ou d'appréciation de la légalité d'un acte administratif. Le juge pénal dispose aujourd'hui de davantage de pouvoir que le juge civil. L'administration a l'obligation de communiquer aux administrés les documents administratifs.

L'administration peut mettre fin à un acte administratif. Cette suppression ne vaut que pour l'avenir en cas d'abrogation. Si un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droit peuvent toujours être abrogés, les décisions créatrices de droit ne peuvent être abrogées que dans certaines hypothèses. Par ailleurs, l'administration est parfois tenue de procéder à l'abrogation d'un acte, notamment en raison de son illégalité. L'administration peut également mettre fin de façon rétroactive à un acte administratif en le retirant. Les conditions du retrait varient en fonction de la nature de l'acte et ont été modifiées et simplifiées par le Code des relations entre le public et l'administration de 2015.

SOUS-TITRE 2. Le contrat administratif

Le contrat peut se définir comme l'acte dont le contenu règle les rapports entre les parties. Ses dispositions créent entre ces dernières et uniquement entre elles des droits et des obligations. L'administration peut passer des contrats de droit privé ou des contrats administratifs. La distinction entre ces deux types de contrat est importante (Section 1) car les seconds relèvent pour l'essentiel du droit public et de la compétence du juge administratif (Section 2).

CHAPITRE 1 La notion de contrat administratif

Il existe différents critères (section 1) qui permettent de qualifier un contrat d'administratif (section 2).

SECTION 1. Les critères d'identification du contrat administratif

C'est le juge qui, pour l'essentiel, a déterminé les critères du contrat administratif. L'un de ces critères est toujours obligatoire et concerne les parties au contrat (1). Les autres intéressent le contenu du contrat (2).

1. Le critère organique

Ce critère postule que pour qu'un contrat soit administratif il doit y avoir au moins une personne publique partie au contrat (1A). L'appréciation de ce critère peut parfois être large (1B).

1A. L'énoncé du critère

Trois situations peuvent se rencontrer. Un contrat peut être passé entre des personnes publiques (1A1). Il peut réunir des personnes publiques et privées (1A2) ou ne lier que des personnes privées (1A3).

1A1. Les contrats entre personnes publiques

Si toutes les parties à un contrat sont des personnes publiques, le contrat est présumé être administratif (TC 1983 UAP : contrat conclu entre le ministère des PTT et un établissement public). Ceci parce qu'un tel contrat est, comme l'a souligné le commissaire du gouvernement dans la décision UAP, « normalement à la rencontre de deux gestions publiques ». Ainsi sont, par exemple, des contrats administratifs les contrats de plan conclus entre l'État et une région (CE 1988 Ministre chargé du plan c. Communauté urbaine de Strasbourg).

Cependant la décision UAP précise que cette présomption peut être renversée, si eu égard à son objet, le contrat ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé. Tel est le cas d'un contrat conclu entre une commune et EDF pour la fourniture d'électricité puisqu'il s'agit d'un contrat entre un SPIC et son usager ou d'un contrat conclu entre le ministère de la défense et l'Union des groupements d'achats publics « portant sur la seule fourniture de véhicules automobiles usuels » (CE 2003 UGAP).

La personne publique peut passer un contrat avec une personne privée.

1A2. Les contrats entre personnes publiques et privées

Si au moins une partie au contrat est une personne publique le contrat pourra être administratif si un des autres critères du contrat est satisfait. À la différence de l'hypothèse précédente, le critère organique ne se suffit jamais à lui-même.

Une dernière hypothèse est celle où le contrat ne concerne que des personnes privées.

1A3. Les contrats entre personnes privées

Si aucune des parties au contrat n'est une personne publique, le contrat sera qualifié de droit privé

(CE 1984 CEMA et Cousteau à propos d'un contrat conclu entre l'Institut Français du Pétrole et le Centre d'Études Marines Avancé pour la construction d'un engin sous-marin).

Le critère organique est toutefois interprété soupagement par la jurisprudence

1B. L'aménagement du critère

S'il apparaît qu'une personne privée partie à un contrat conclu avec une autre personne privée agit pour le compte d'une personne publique, ce contrat pourra être administratif. Il en ira ainsi par application de la théorie du mandat (1B1) ou de la jurisprudence Peyrot (1B2).

1B1 La théorie du mandat

Une personne publique peut confier un mandat à une personne privée pour qu'elle la représente (a). L'existence d'un tel mandat est parfois déduite des circonstances (b). C'est ce que la doctrine désigne sous le terme de théorie du mandat ou du critère relationnel.

≡ Le mandat express (a)

Une personne publique peut conclure un mandat avec une personne privée afin qu'elle agisse pour son compte. Dans une telle hypothèse, les contrats passés par cette personne privée avec une autre personne privée seront donc conclus pour le compte de la personne publique et le critère organique est donc satisfait. Il en a été jugé ainsi, par exemple, pour le contrat passé par un syndicat d'initiative avec un particulier et concédant à ce dernier le lot d'une plage compte tenu de la convention passée entre une commune et le syndicat chargeant ce dernier d'organiser l'exploitation de la plage dans l'intérêt du développement de la station (CE 1936 Prade).

Dans certains cas, aucun mandat n'a été conclu formellement mais la jurisprudence déduit l'existence de celui-ci des faits de l'espèce.

≡ Le mandat tacite (b)

Il arrive parfois que le juge construise, à partir d'un faisceau d'indices, un mandat a posteriori entre une personne publique et une personne privée qui a passé un contrat avec une autre personne privée.

Ce mandat peut être déduit des modalités d'exécution de travaux. C'est ainsi qu'il a été jugé que le critère organique est satisfait pour les contrats passés entre des entrepreneurs et une SEM pour la construction de voies publiques dans une ZUP dont elle est concessionnaire car ces travaux sont réalisés sous le contrôle des ponts et chaussées, financés par des subventions pour les personnes publiques mais versées directement à la SEM et remis après achèvement aux personnes publiques concédantes dont la responsabilité en matière de garantie décennale est substituée à celle de la SEM (CE 1975 Société d'équipement de la région montpelliéraine).

Ce raisonnement a été étendu en dehors des opérations de travaux publics pour des personnes privées transparentes. Il a ainsi été décidé qu'un contrat conclu entre un manadier et un comité des fêtes a été passé pour le compte d'une commune compte tenu de la composition et du financement de ce comité (TC 1985 Laurent).

Le critère organique peut également être satisfait par application de la jurisprudence Peyrot.

1B2. La jurisprudence Peyrot

L'existence d'un mandat peut être déduite non des modalités d'exécution des travaux mais de leur nature. Le Tribunal des conflits a jugé que le critère organique était satisfait pour le contrat passé entre une SEM concessionnaire d'une autoroute et une entreprise privée relative à la construction de cette autoroute. La juridiction de partage a adopté cette solution parce que « la construction des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l'État » et que, dès lors, il doit en être de même pour les marchés de construction d'autoroutes passés par une SEM « agissant en pareil cas pour le compte de l'État » (TC 1963 Société entreprise Peyrot). La jurisprudence Peyrot a été appliquée à d'autres marchés concernant la voirie routière nationale tels ceux relatifs à la construction et l'exploitation de la route nationale et du tunnel de liaison sous les Vosges (TC 1984 SEM du tunnel de Sainte-Marie aux mines).

La jurisprudence Peyrot a été abandonnée. Le TC décide désormais « qu'une société concessionnaire d'autoroute qui conclut avec une autre personne privée un contrat ayant pour objet la construction, l'exploitation ou l'entretien de l'autoroute ne peut, en l'absence de conditions particulières, être regardée, comme ayant agi pour le compte de l'État ». C'est donc le juge judiciaire qui est compétent pour tous les contrats passés par les concessionnaires d'autoroute avec une entreprise privée. Le TC précise toutefois que les contrats passés antérieurement à sa nouvelle jurisprudence conservent leur caractère de droit public et relèvent du juge administratif (TC 2015 Mme Rispal c. soc. des autoroutes du sud de la France).

Lorsqu'un contrat est conclu entre une personne publique et une personne privée ou deux personnes privées dont l'une agissant pour le compte d'une personne publique, ce contrat ne peut être administratif que si un autre critère est présent.

2. Les critères matériels

Pour être administratif, un contrat doit, en plus du critère organique, satisfaire à l'un des autres critères dégagés par la jurisprudence (2A) et dont la portée doit être précisée (2B).

2A. L'apparition des critères

Un contrat dont l'une des parties est une personne publique ou agit pour son compte peut être administratif en raison de son objet (2A1) ou de son caractère exorbitant par rapport au droit commun (2A2).

2A1. Le critère finaliste

Ce critère a pour effet de qualifier d'administratif, le contrat qui a un lien étroit avec le service public.

Ce critère est apparu avec un arrêt par lequel la haute juridiction administrative se reconnaît compétente pour connaître du litige relatif à un contrat par lequel la ville de Montpellier a chargé M. Thérond de capturer les chiens errants et d'enlever les bêtes mortes au motif que la ville « a agi en vue de l'hygiène et de la sécurité de la population et a eu, dès lors, pour but d'assurer un service public » (CE 1910 Thérond).

En application de ce critère sont considérés comme administratifs trois types de contrats.

D'abord, ceux par lesquels l'administration assure « l'exécution même du service public » (CE 1956 Consorts Grimouard : les contrats passés entre l'administration des eaux et forêts et des particuliers pour des opérations de reboisement sont administratifs car ils constituent « l'une des modalités de l'exécution du service public de la reconstitution de la forêt française »).

Ensuite, il s'agit des contrats par lesquels une personne publique confie à une autre personne « l'exécution même du service public » (CE 1956 Époux Bertin : le contrat verbal conclu entre l'administration et un couple par lequel celui-ci s'est engagé à assurer la nourriture de réfugiés est un contrat administratif car il a eu pour objet de leur confier « l'exécution même du service public » du rapatriement des réfugiés). A contrario, un marché de transport de marchandises conclu « pour satisfaire les besoins du service public » n'est pas administratif (CE 1956 Société des transports Gondrand).

Enfin, ce sont les contrats par lesquels une personne publique emploie un agent dans un SPA (TC 1996 Berkani).

Un autre critère permet de qualifier un contrat d'administratif.

2A2. Le critère de l'exorbitance

Les juges du Palais royal ont décliné leur compétence pour un litige opposant une société à la ville de Lille pour la fourniture de pavés au motif « que le marché avait pour objet unique des fournitures à livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers ». A contrario, si les clauses du contrat avaient prévu des dispositions dérogeant au droit commun, il se serait agi d'un contrat administratif. Le critère de la « clause exorbitante du droit commun » était apparu (CE 1912 Société des granits porphyroïdes des Vosges).

Dans le même esprit, le Conseil d'État a décidé qu'un contrat soumis à un régime exorbitant du droit commun est un contrat administratif (CE 1973 Société d'exploitation électrique de la rivière du Sant : les contrats par lesquels EDF achète l'électricité des producteurs autonomes sont administratifs parce qu'un décret oblige EDF à conclure ces contrats et en cas de litige il faut saisir le ministre chargé de l'électricité avant tout recours juridictionnel). Dans cette hypothèse, les règles exorbitantes du droit commun ne résultent pas du contrat lui-même mais sont préexistantes.

Plusieurs précisions concernant la portée de ces critères doivent être apportées.

2B. La portée des critères

Les critères matériels sont alternatifs (2B1) et connaissent des insuffisances (2B2).

2B1. Des critères alternatifs

Lorsque le critère organique est satisfait, il suffit du critère finaliste ou de l'exorbitance pour qualifier le contrat d'administratif (CE 1956 Époux Bertin : lorsqu'un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée a pour objet l'exécution du service public, « cette circonstance suffit à elle seule à imprimer au contrat le caractère d'un contrat administratif »).

Ces critères ne donnent pas une satisfaction totale.

2B2 Des critères en dégénérescence

Les critères matériels posent des problèmes d'application (a) et n'ont pas un caractère absolu (b).

≡ Les difficultés de mise en œuvre des critères (a)

S'agissant du critère finaliste, deux problèmes se sont posés et ont fini par trouver une solution plus heureuse.

En premier lieu, il n'a pas toujours été aisé de déterminer si une personne participe ou non « à l'exécution même du service public ». Aujourd'hui, il est considéré que tout agent d'une personne publique gérant un SPA est un agent public quel que soit son emploi (TC 1996 Berkani à propos d'un cuisinier du CROUS).

En second lieu, la mise en œuvre du critère finaliste pouvait conduire à des découpages byzantins comme le montrent certaines jurisprudences. Ainsi une femme de service d'une école est employée, dans un premier temps, pour l'entretien des locaux et l'allumage du chauffage puis se voit confier, en plus de ces tâches, une garderie. Un litige étant survenu entre l'employée et la commune, la juridiction de partage décide que, pour la première période, Mme Mazerand ne participe pas à l'exécution même du service public et donc son contrat est un contrat de droit privé, à la différence de la seconde période où il devient administratif. Elle doit alors saisir le juge judiciaire et le juge administratif (TC 1963 Dame Mazerand).

Cette situation a été simplifiée car aujourd'hui le Tribunal des conflits décide que dans l'hypothèse où la situation juridique d'un agent est modifiée du fait d'un changement dans la nature de ses fonctions, il y a lieu de se référer, pour déterminer la juridiction compétente, aux fonctions qu'il exerçait au moment de la mesure litigieuse même si la période antérieure doit être prise en compte pour la détermination de ses droits (TC 1990 Demoiselle Salliège : un agent hospitalier chargé d'assister les malades dans leur déplacement (ce qui constitue une participation à l'exécution même du service public) et de travaux de buanderie (absence de participation à l'exécution même du service public) puis affecté seulement à ces derniers travaux doit saisir le juge judiciaire pour le litige concernant son licenciement).

La notion de clause exorbitante du droit commun se heurte également à un problème de définition. Ont été jugées exorbitantes du droit commun deux types de clauses.

D'une part, celles inexistantes en droit privé. Ainsi d'une clause qui octroie une exonération fiscale à l'exploitant d'un cirque-théâtre municipal (TC 1962 Consorts Cazautets).

D'autre part, celles inhabituelles en droit privé comme les clauses qui confèrent des droits au cocontractant ou lui imposent des sujétions tels l'engagement du maire à ne pas accueillir de cirque ambulant, la possibilité pour la commune de résilier unilatéralement le contrat en dehors de tout manquement du cocontractant à ses obligations contractuelles, l'obligation de mettre gratuitement la salle à la disposition de la commune pour certaines occasions et de respecter certains critères pour le contenu des spectacles (TC 1962 Consorts Cazautets) ou le pouvoir de résiliation unilatérale par la personne publique contractante du contrat en dehors de toute faute du cocontractant (TC 1999 UGAP).

Certaines clauses ont pu donner lieu à des qualifications surprenantes. Ainsi, le Conseil d'État a refusé de considérer comme une clause exorbitante du droit commun celle par laquelle une commune qui garantit un contrat de prêt s'engage à créer et recouvrer pendant toute la durée du prêt les impositions nécessaires au remboursement des annuités en cas de défaillance de l'emprunteur alors qu'une telle clause est exclue dans les contrats entre personnes privées (CE 1989 Société Calif).

Les critères matériels ne sont pas toujours opérationnels.

≡ Des critères non absolus (b)

Les critères matériels ne s'appliquent pas toujours. Certains contrats ont un caractère administratif malgré l'absence des critères finaliste ou de l'exorbitance par rapport au droit commun ou, au contraire, sont de droit privé alors même que ces critères sont satisfaits.

Certains contrats font l'objet d'une qualification textuelle. Ainsi sont, par exemple, toujours des contrats administratifs les marchés de travaux publics (loi du 28 pluviôse an VIII) ou les contrats d'occupation du domaine public (décret-loi du 17 juin 1938). Sont, au contraire, des contrats de droit privé les contrats emplois jeunes (art. L. 322-4-20 du Code du travail).

D'autres contrats sont toujours des contrats de droit privé par détermination jurisprudentielle. Ainsi des contrats d'un SPIC avec ses agents, exception faite du directeur et du comptable public (CE 1957 Jalenques de Labeau).

À partir de cette définition, on peut distinguer différents types de contrats administratifs.

Les critères jurisprudentiels du contrat administratif

1) Critère organique : au moins une personne publique est partie au contrat

- Un contrat entre une personne publique est présumé administratif sauf si eu égard à son objet, il ne fait naître que des rapports de droit privé : TC 1983 UAP.
- Un contrat entre une personne publique et une personne privée peut être administratif si la condition 2) est remplie.
- Un contrat entre personnes privées est un contrat de droit privé sauf si l'une d'elles agit pour le compte d'une personne publique et que la condition 2) est remplie.

ET

2) Critère matériel

- Critère finaliste : le contrat a pour objet l'exécution même du service public : CE 1910 Thérond.

OU

- Critère de l'exorbitance :
- le contrat contient une clause exorbitante de droit commun : CE 1912 Société des granits porphyroïdes des Vosges.

OU

- le contrat est soumis à un régime exorbitant de droit commun : CE 1973 Société d'exploitation électrique de la rivière du Sant.

SAUF

Qualification légale ou jurisprudentielle contraire.

SECTION 2. Les différentes catégories de contrat administratif

Il existe de nombreux types de contrats administratifs. Certains présentent plus d'importance (1) que d'autres (2).

1. Les principaux contrats administratifs

Il existe trois catégories principales de contrats administratifs d'un point de vue économique, numérique et juridique (encadrement par les textes et la jurisprudence) : les marchés publics (1A), Les contrats de délégation de service public (1B) et les contrats de louage de service (1C).

1A. Les marchés publics

Les marchés publics ont été définis par le Code des marchés publics de 2006 comme les « contrats conclus à titre onéreux » avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public (exceptions faites des EPIC) « pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ».

Une autre catégorie de contrat administratif présente une grande importance.

1B. Les contrats de délégation de service public

Reprenant les éléments dégagés par la jurisprudence, la loi MURCEF (Mesures Urgentes de Réformes à Caractère Économique et Financier) de 2001 définit la délégation de service public comme un « contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service ».

Une dernière catégorie de contrat administratif est importante numériquement.

1C. Les contrats de louage de service

Il s'agit des contrats conclus par l'administration pour recruter ses agents non-fonctionnaires.

Aux côtés de ces trois principales catégories de contrats administratifs, il existe d'autres variétés de contrats administratifs.

2. Les autres contrats administratifs

Il existe d'autres catégories de contrats administratifs qui ont économiquement moins de poids ou sont moins fréquents :

- les contrats financiers (emprunt, garantie...);
- les contrats de projet État-région ou les contrats État-entreprises publiques ou État-établissements publics (avec les universités, par exemple) qui fixent les objectifs des politiques à mener et les engagements financiers de l'État ;
- les offres de concours qui permettent à une personne de participer financièrement ou en nature à des travaux publics ;
- les contrats de partenariat qui ont été instaurés par une ordonnance du 17 juin 2004 pour associer les entreprises privées aux investissements et à l'exploitation d'équipements ou de services publics. Ils se différencient ainsi des marchés publics en ce qu'ils peuvent prendre la forme d'une prestation globale (conception, construction et maintenance d'un bâtiment) et des délégations car la rémunération n'est pas liée substantiellement aux résultats de l'exploitation mais doit reposer sur des critères de performance.

Les contrats qui ne s'inscrivent pas dans une de ces catégories sont parfois qualifiés par les auteurs de « contrats innomés » (terme qui désigne en droit privé les contrats qui ne relèvent pas d'une variété prévue et encadrée par la loi). Il s'agit, par exemple des contrats portant occupation du domaine public ou des contrats d'achat, de location ou de vente d'immeubles.

Les contrats administratifs obéissent à des règles particulières.

À retenir

Le contrat administratif peut se définir comme le contrat dans lequel est partie directement ou non (théorie du mandat ou application de la jurisprudence Peyrot) une personne publique et qui a un lien direct avec un service public ou contient une clause exorbitante du droit commun ou est soumis à un régime exorbitant du droit commun, hormis les cas où il fait l'objet d'une détermination textuelle ou jurisprudentielle. À partir de cette définition, on peut distinguer différents types de contrats administratifs dont les principaux sont les marchés publics, les DSP (délégations de service public) et les contrats de louage de service.

CHAPITRE 2 Le régime juridique des contrats administratifs

Des règles souvent dérogatoires au droit commun s'appliquent aux contrats administratifs (section 1) et font l'objet de sanctions devant le juge (section 2).

SECTION 1. Les règles régissant les contrats administratifs

Les règles relatives à la conclusion des contrats sont plutôt d'origine textuelle (1) tandis que celles qui régissent son exécution ont essentiellement été posées par le juge (2).

1. La formation des contrats administratifs

Les règles relatives à la formation des contrats administratifs sont semblables à celles qui concernent les contrats de droit privé de l'administration. Elles dérogent au droit privé en ce qu'elles portent souvent atteinte à la liberté contractuelle (1A) et à l'égalité des cocontractants (1B).

1A. Les atteintes à la liberté contractuelle

La capacité de l'administration (1A1) et sa liberté de choisir ses partenaires (1A2) sont encadrées.

1A1. Les limites à la capacité de contracter de l'administration

D'un point de vue organique, n'importe qui ne peut pas engager l'administration. L'autorité compétente pour signer un contrat peut varier.

Pour l'État, il s'agit du ministre. Cependant, s'il s'agit d'un contrat intéressant une assemblée parlementaire, c'est le président de l'assemblée qui est compétent. Les contrats conclus entre l'État et une collectivité locale ou un établissement public relèvent de la compétence du préfet.

Pour les contrats des collectivités locales et des établissements publics, c'est l'organe exécutif mais celui-ci ne peut agir que sur habilitation de l'organe délibérant.

Sur le plan matériel, l'administration ne peut pas conclure de contrats dans n'importe quel domaine. Ainsi sont prohibés :

- le fait de conférer par contrat à une personne privée un pouvoir de police (CE 1932 Ville de Castelnaudary) ;
- la conclusion de contrats dans un domaine où l'administration doit intervenir par voie réglementaire comme les aides aux établissements privés d'enseignement ;
- les avantages accordés par voie contractuelle aux fonctionnaires lorsqu'ils dérogent à leur situation réglementaire ou législative.

L'administration ne dispose pas toujours d'une totale liberté pour choisir ses partenaires.

1A2. Les limites au libre choix du cocontractant

Si pour certains contrats l'administration peut librement choisir son cocontractant (a), il n'en va pas de même pour les marchés publics (b).

Les contrats conclus intuitu personae (a)

Pour certains contrats, l'administration peut choisir son partenaire en considération de sa personne. C'est le cas notamment des :

- délégations de service public mais depuis la loi Sapin de 1993 l'administration doit recourir à une publicité par voie d'avis d'appel public à la concurrence au bulletin officiel d'annonces des marchés publics ;
- contrats de louage de service ;
- contrats d'assurance ;
- offres de concours.

Pour les marchés publics, le choix est plus encadré.

Les marchés publics (b)

Jusque 1956 pour l'État et 1971 pour les collectivités locales, l'adjudication était le mode normal de passation des marchés publics. Il s'agissait d'une procédure au terme de laquelle l'administration devait retenir le « moins-disant », c'est-à-dire le candidat qui lui proposait l'offre la moins chère.

Désormais, l'administration doit retenir le « mieux disant », c'est-à-dire celui qui lui présente « l'offre économiquement la plus avantageuse » ce qui ne s'apprécie pas exclusivement en terme financier (prix, qualité, délais, service après-vente, respect de l'environnement...).

L'appel d'offres est la procédure de droit commun pour les marchés publics. Il doit, en effet, être retenu pour tout marché de fournitures ou de services de l'État supérieur à 130 000 euros ou 200 000 euros s'agissant des collectivités locales ainsi que pour tout marché de travaux excédant 5 000 000 euros. Il s'agit de retenir le candidat, « sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ». L'administration peut choisir entre :

- l'appel d'offres ouvert qui permet à toutes les entreprises de proposer une offre,
- l'appel d'offres restreint où ne peuvent soumissionner que les entreprises (au moins 5) dont la candidature a préalablement été acceptée.

Dans les deux cas, pour les marchés de l'État, c'est la personne responsable du marché qui choisit le titulaire du marché après avis d'une commission d'appel d'offres.

Pour les collectivités territoriales, c'est cette commission qui attribue le marché.

D'autres procédures peuvent être utilisées :

- la procédure négociée qui permet à la personne publique de choisir « le titulaire du marché après consultation des candidats et négociation des conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux » ;
- le dialogue compétitif qui remplace l'ancien appel d'offres sur performances et qui est utilisé lorsque l'administration « n'est pas en mesure de définir les moyens aptes à satisfaire ses besoins ou d'évaluer ce que le marché peut offrir en termes de solutions techniques, financières ou juridiques » (réseau informatique, par exemple) ;
- la procédure adaptée qui s'applique aux marchés dont les seuils sont inférieurs à ceux prévus pour le recours à l'appel d'offres. Pour ces marchés, la personne publique détermine librement les modalités de mise en concurrence. Cependant, s'agissant des formalités de publicité, seuls les marchés inférieurs à 90 000 euros échappent aux règles édictées par le Code des marchés publics. La personne publique choisit alors les modalités de publicité adéquate ;
- le concours qui permet de choisir, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet concernant l'aménagement du territoire, l'urbanisme, l'architecture ou le traitement de données ;
- la procédure de conception-réalisation qui permet de choisir le titulaire du marché après avis d'un jury si l'entrepreneur doit, pour des raisons techniques être associé aux études de l'ouvrage qu'il s'agit de réaliser.

Les contrats administratifs peuvent également porter atteinte à un autre principe du droit civiliste des contrats.

1B. Les atteintes à l'égalité des cocontractants

Le contenu du contrat n'est pas toujours déterminé librement par les parties. En règle générale, l'administration impose à son cocontractant le contenu du contrat (1B1). Elle ne peut pas, cependant, insérer n'importe quelle clause dans le contrat (1B2).

1B1. Les clauses imposées

Il faut distinguer les cas des marchés publics (a) de celui des délégations de service public (b).

≡ Les marchés publics (a)

Pour les marchés publics, des cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés publics s'exécutent.

Les documents généraux sont :

- les cahiers des clauses administratives générales qui fixent les dispositions administratives applicables à une catégorie de marchés. Ils sont élaborés par la Commission centrale des marchés puis approuvés par arrêté ministériel (depuis 2001). Les CCAG sont au nombre de quatre (pour les marchés industriels, de travaux, de fournitures courantes et de services, de prestations intellectuelles) ;
- les cahiers des clauses techniques générales qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations de même nature.

Les documents particuliers sont :

- les cahiers des clauses administratives particulières qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché ;
- les cahiers des clauses techniques particulières qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l'exécution des prestations prévues au marché.

Ces cahiers des charges ont une valeur contractuelle dans la mesure où les parties sont libres de s'y référer ou non (dans la pratique c'est l'administration qui décide) et qu'ils peuvent déroger aux règles prévues lorsqu'elles décident de les appliquer.

Pour les délégations de service public la solution est différente.

≡ Les délégations de service public (b)

Pour les cahiers des charges des délégations de service public, on distingue :

- les clauses régissant les rapports entre le concédant et le concessionnaire (durée de la concession, garantie d'emprunt...) qui ont une valeur contractuelle ;
- les clauses qui concernent l'organisation et le fonctionnement du service public comme les tarifs ou les modalités d'accès au service qui ont une valeur réglementaire (CE 1996 Cayzeele).

Certaines clauses ne peuvent pas figurer dans un contrat administratif.

1B2. Les clauses interdites

Sont prohibées, les clauses contraires :

- à des prescriptions légales telles les clauses abusives au sens du Code de la consommation ;
- aux principes de la domanialité publique et aux nécessités du fonctionnement des services publics (CE 1985 Association Eurolat : illégalité de la clause par laquelle l'administration renonce à son pouvoir de résiliation unilatérale du contrat).

Ce pouvoir intéresse l'exécution des contrats administratifs.

2. L'exécution des contrats administratifs

En conséquence de l'article 1134 du Code civil (« les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »), un contrat a un caractère obligatoire entre les parties, ne peut être modifié que par accord entre ces parties qui sont dans une situation d'égalité. Cependant, les impératifs d'intérêt général expliquent que les contrats administratifs dérogent parfois à ces principes. En effet, l'administration dispose de certaines prérogatives (2A) et son cocontractant est dans une situation particulière par rapport aux contrats conclus entre particuliers (2B).

2A. Les prérogatives de l'administration

Un contrat administratif peut contenir des clauses exorbitantes du droit commun conférant certains pouvoirs à l'administration. Indépendamment de cette situation, l'administration dispose de prérogatives même en dehors de toute stipulation contractuelle. Certaines se rattachent au droit de surveillance et de contrôle du cocontractant conféré à l'administration (2A1). D'autres sont relatives à sa faculté d'intervenir sur l'étendue des obligations du cocontractant (2A2).

2A1. Le droit de contrôle et de direction

Ce droit (a) fait l'objet de différentes sanctions (b).

≡ L'étendue des pouvoirs (a)

Le pouvoir de contrôle de l'administration lui permet de vérifier que le cocontractant exécute le contrat conformément à ses obligations. Par exemple, sur un chantier, l'administration va vérifier la qualité des matériaux utilisés.

Le pouvoir de direction permet à l'administration de donner des instructions à son cocontractant (appelées « ordres de service » dans les marchés de travaux publics) pour la bonne exécution du contrat telles que la fixation de l'ordre des opérations à réaliser ou la prescription d'un procédé de réalisation des prestations demandées.

Si au cours de la mise en œuvre de ses prérogatives, l'administration constate une défaillance de l'entrepreneur (retard, malfaçon...) elle peut lui infliger une sanction.

≡ Les sanctions (b)

Il existe plusieurs types de sanctions.

Ce sont, d'une part, les sanctions pécuniaires. Il s'agit en premier lieu des pénalités de retard. Lorsque l'entreprise ne respecte pas les délais, elle doit payer une somme d'argent à l'administration dont le montant est prévu au contrat. En second lieu, les amendes ou dommages-intérêts viennent, même si le contrat ne le prévoit pas, sanctionner le cocontractant qui ne respecte pas ses obligations contractuelles et qui cause ainsi un préjudice à l'administration.

D'autre part, il existe des sanctions qui écartent le cocontractant de l'exécution du contrat. Certaines sont des sanctions coercitives. Si le cocontractant ne remplit pas ses obligations, l'administration peut, momentanément, se substituer à lui (mise en régie pour les marchés de travaux et mise sous séquestre pour les délégations de service public) ou lui substituer un tiers (exécution par défaut des marchés de fournitures), et ce, aux frais et risques du cocontractant. La poursuite de l'exécution du contrat se fait donc avec le personnel et le matériel du cocontractant si l'administration se substitue à lui. En cas de recours à un tiers, c'est le cocontractant initial qui supporte les frais supplémentaires générés. Par ailleurs, la résiliation sanction permet de mettre fin au contrat.

La mise en œuvre de ces sanctions présente certains traits communs.

D'abord, les sanctions ne peuvent être prononcées qu'après la mise en demeure du cocontractant sauf clause contraire ou urgence.

Ensuite, les sanctions doivent être motivées et notifiées au cocontractant qui doit pouvoir présenter ses justifications.

Les sanctions peuvent être prononcées sans recours au juge excepté pour les amendes et la déchéance du concessionnaire d'un service public à moins d'une clause contraire pour cette dernière sanction.

Enfin, en cas de recours du cocontractant, le juge n'annule pas une sanction disproportionnée mais accorde des dommages et intérêts. Le juge se reconnaît, cependant, un tel pouvoir d'annulation pour les contrats qui ont nécessité des investissements importants amortissables sur le long terme et pour les contrats à caractère réglementaire tels que les contrats d'abonnement au téléphone (CE 1979 Mme Bourgeois).

L'administration dispose d'autres prérogatives.

2A2. Le droit d'intervenir sur les obligations du cocontractant

L'administration peut porter atteinte au caractère immuable (a) et obligatoire (b) du contrat.

≡ Le droit de modification unilatérale du contrat (a)

Son origine appelle plusieurs observations.

Il s'agit d'un pouvoir ancien (CE 1902 Compagnie nouvelle du gaz de Déville-lès-Rouen : une commune peut demander à son concessionnaire de l'éclairage au gaz d'utiliser l'électricité et, en cas de refus, de changer de prestataire).

Ce pouvoir existe même sans texte ou stipulations contractuelles en ce sens (CE 1983 Union des transports publics urbains et régionaux).

Il a pour fondement les principes de continuité et de mutabilité du service public lorsqu'il s'agit d'une délégation de service public ou la satisfaction de l'intérêt général pour les autres contrats.

Ce pouvoir connaît certaines limites.

En premier lieu, son champ d'application est encadré. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un pouvoir discrétionnaire puisque la modification du contrat doit être justifiée par des considérations d'intérêt général (accroissement des besoins de la population, souci d'assurer un service d'une meilleure qualité...). Ensuite, les contrats dont le contenu est défini entièrement par voie législative ou réglementaire ne peuvent pas être modifiés directement. Leur modification ne peut être effectuée que par changement des dispositions législatives ou réglementaires. Enfin, ce pouvoir ne peut pas concerner directement les clauses financières du contrat. En revanche, celles-ci peuvent être indirectement modifiées suite au changement apporté unilatéralement par l'administration à d'autres clauses du contrat.

En second lieu, le cocontractant a droit à une indemnisation intégrale des charges supplémentaires impliquées par les transformations du contrat (CE 1910 Compagnie générale française des tramways).

L'administration peut également mettre fin au contrat indépendamment de toute faute commise par son cocontractant.

≡ Le droit de résiliation unilatérale (b)

L'administration peut décider de résilier unilatéralement un contrat administratif si des considérations d'intérêt général le justifient. Ainsi, elle peut mettre fin à des contrats d'achat d'alcool compte tenu de l'augmentation de la production qui conduit l'État à disposer de stocks importants qu'il peut difficilement écouler et dont l'acquisition est onéreuse (CE 1958 Distillerie de Magnac-Laval).

Ces considérations d'intérêt général expliquent que ce droit existe indépendamment des clauses du contrat. Le cocontractant n'étant pas fautif a droit à une indemnisation totale du préjudice subi.

Toutefois, le Conseil d'État a récemment accepté qu'un contrat administratif qui n'a pas pour objet l'exécution même d'un service public puisse prévoir la faculté pour le cocontractant de résilier unilatéralement le contrat si l'administration méconnaît ses obligations contractuelles. Cette possibilité est subordonnée à l'obligation pour le cocontractant :

- de mettre à même l'administration de s'opposer à la résiliation pour un motif tiré de l'intérêt général,
- de poursuivre l'exécution du contrat si l'administration invoque un tel motif sous peine de voir le contrat résilier à ses torts exclusifs. Le cocontractant peut toutefois contester ce motif devant le juge administratif (CE 2014 Soc. Greenke location).

Le cocontractant dispose également d'autres droits.

2B. La situation du cocontractant

Le cocontractant est soumis à des obligations (2B1) et bénéficie de certains droits (2B2) qui peuvent présenter une originalité par rapport au droit commun.

2B1. Les obligations du cocontractant

Le cocontractant doit exécuter correctement (a) et personnellement (b) le contrat.

≡ L'exécution correcte du contrat (a)

Le cocontractant se doit, d'une part, d'exécuter ponctuellement ses obligations, c'est-à-dire en respectant les délais.

D'autre part, il doit réaliser intégralement les obligations mises à sa charge.

Il ne peut pas ainsi opposer à l'administration « l'exception d'inexécution », c'est-à-dire qu'en cas de manquement de l'administration à ses obligations, le cocontractant ne peut pas cesser d'exécuter les siennes. Il peut seulement saisir le juge d'une action en indemnité. Cette règle s'explique par le principe de continuité du service public ou, plus généralement, la satisfaction de l'intérêt général (pour les contrats qui ne concernent pas un service public).

Le cocontractant n'est délié de ses obligations qu'en cas de force majeure, c'est-à-dire d'événement extérieur aux parties, imprévisible dans sa survenance et irrésistible dans ses effets.

Il pèse sur le cocontractant une autre obligation.

≡ L'exécution personnelle du contrat (b)

L'obligation d'exécution personnelle du contrat n'empêche pas la sous-traitance qui est le fait pour le cocontractant de confier une partie de l'exécution du contrat à un tiers. Cependant, c'est le cocontractant qui reste responsable de la bonne exécution du contrat vis-à-vis de l'administration.

La cession du contrat (en cas de décès du cocontractant, de mise en règlement judiciaire...) nécessite l'accord de l'administration.

En contrepartie de ces obligations, le cocontractant bénéficie également de certains droits.

2B2 Les droits du cocontractant

Le cocontractant peut exiger que l'administration exécute de bonne foi le contrat. Pour cette exécution, le cocontractant peut se voir reconnaître certaines prérogatives de puissance publique (monopole, occupation temporaire de terrains privés...). Mais le cocontractant bénéficie essentiellement de garanties financières. Il a bien évidemment droit au paiement du prix convenu (a) mais également à être indemnisé des charges non initialement prévues (b).

≡ Le droit au paiement du prix convenu (a)

Ce prix peut faire l'objet d'une variation. Ainsi le prix peut être :

- actualisé en cas de décalage entre la conclusion et l'exécution du contrat ;

- ajustable s'il est déterminé par rapport à une référence représentative de l'évolution du prix de la prestation (par exemple, le prix du baril de pétrole pour la livraison d'essence) ;
- révisable lorsqu'il est fixé par rapport à un indice résultant de plusieurs paramètres (prix, salaire...).

Pour les contrats s'exécutant sur une longue période, le cocontractant peut recevoir :

- une avance (paiement d'une partie du prix avant qu'un commencement d'exécution ait lieu) par exception à la règle du service fait ;
- un acompte (paiement du prix correspondant à la fraction de la prestation déjà réalisée).

Le cocontractant peut également être indemnisé des charges non initialement prévues.

≡ Le droit à l'indemnisation des charges nouvelles (b)

L'aggravation des charges du contrat peut résulter ou non des agissements de l'administration cocontractante.

- Le droit à indemnité lié à l'attitude de l'administration contractante

Deux théories trouvent ici application. Il s'agit, d'une part, de la théorie de « l'équation financière du contrat » stricto sensu et, d'autre part, de la théorie du fait du prince (ou de l'aléa administratif).

- La théorie de « l'équation financière du contrat »

Cette expression est tirée de la formule du commissaire du gouvernement Blum dans ses conclusions sur l'arrêt *Compagnie générale française des tramways*. Lorsque l'administration modifie le contrat ou le résilie en tant que partie au contrat, elle doit indemniser complètement son cocontractant afin que l'équilibre financier initial du contrat (équilibre entre les avantages et charges du cocontractant) soit rétabli (CE 1910 *Compagnie générale française des tramways*).

Ce droit au rétablissement de l'équilibre financier a inspiré d'autres théories.

- La théorie du fait du prince (ou de l'aléa administratif).

Il existe des divergences doctrinales sur le champ d'application de cette théorie.

Pour certains auteurs, cette théorie désigne seulement l'hypothèse où la situation du cocontractant est aggravée du fait d'une mesure prise par l'administration contractante mais en une autre qualité que celle de partie au contrat. L'indemnisation du cocontractant vise ici à dissuader l'administration de modifier indirectement le contrat après l'avoir signé.

D'autres auteurs incluent dans la théorie du fait du prince, non seulement cette hypothèse, mais également celle où l'administration intervient en tant que partie au contrat.

L'indemnisation intégrale du cocontractant pour fait du prince est subordonnée à deux conditions.

L'une tient au caractère imprévisible de la mesure incriminée (CE 1926 *Pouillard* : l'augmentation du prix du charbon et du coût de la main d'œuvre rendait prévisible l'autorisation par les pouvoirs publics d'augmenter le tarif pratiqué par les chemins de fer).

L'autre dépend de la nature de la mesure. Les mesures générales (loi ou règlement) qui ont pour effet d'aggraver les conditions d'exécution d'un contrat n'ouvrent pas droit à indemnisation sauf si est affecté un élément essentiel du contrat (CE 1939 *Compagnie des chemins de fer de l'ouest* : décret venant décider d'une diminution de 10 % de toutes les dépenses publiques et qui concerne donc le contrat par lequel l'État s'était engagé à verser une somme d'argent à la compagnie). Les mesures particulières relatives à un contrat donnent lieu à indemnisation.

Le cocontractant peut être indemnisé pour une aggravation de ses charges indépendante de l'administration contractante.

- Le droit à indemnité lié à des aléas extérieurs aux parties

Deux théories sont ici susceptibles de jouer.

- La théorie des sujétions imprévues

Elle concerne le domaine des travaux publics. Lorsqu'une entreprise de travaux publics se heurte à des difficultés techniques exceptionnelles, imprévisibles au moment de la conclusion du contrat, et étrangères à sa volonté, elle peut demander une indemnisation couvrant la totalité des coûts supplémentaires entraînés par ces difficultés. Ainsi pour du rocher en masse compacte ou des nappes d'eau.

Une dernière théorie a un champ d'application plus large.

- La théorie de l'imprévision

Cette théorie est apparue en 1916 (CE 1916 *Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux* : suite à l'augmentation importante du prix du charbon, le concessionnaire de l'éclairage au gaz, fabriqué à partir du charbon, demanda à la ville l'indemnisation du préjudice causé par cette hausse).

Quatre conditions doivent être réunies pour que la théorie puisse être retenue.

Tout d'abord, l'événement à l'origine de la modification des conditions d'exécution du contrat doit être extérieur aux parties. Tel était le cas dans l'affaire Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux où la hausse du prix du charbon s'expliquait par la première guerre mondiale qui avait entraîné une occupation par l'ennemi des zones productrices et une difficulté des transports maritimes.

Ensuite, il doit être imprévisible pour les parties lors de la conclusion du contrat. Cette condition était remplie dans l'arrêt Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux puisque le contrat avait été conclu à une époque où la guerre de 1914 et les bouleversements économiques qu'elle a engendrés ne pouvaient pas être connus.

L'événement doit également entraîner un bouleversement de l'économie du contrat, c'est-à-dire un déficit dépassant l'aléa normal du contrat comme dans l'affaire Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux. Au contraire, un surcoût de 2 ou 7 % n'entraîne pas un tel bouleversement (CE 1982 Soc. routière Colas à propos de l'augmentation des charges sociales spécifiques à la Martinique).

Enfin, ce bouleversement doit être temporaire car s'il est définitif on est en présence d'un cas de force majeure qui permet aux parties de demander au juge la résiliation du contrat avec indemnité. Si dans l'arrêt Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, le Conseil d'État qualifie les circonstances de l'espèce de cas de force majeure, il a réservé, par la suite, cette dénomination aux hypothèses où le bouleversement du contrat est définitif et où ainsi l'événement présente véritablement un caractère irrésistible. Ainsi pour le déficit chronique du concessionnaire de transport public auquel il n'apparaissait pas possible de mettre fin compte tenu du fait que les redevances payées par les usagers avaient atteint un niveau important qu'il n'était pas possible de dépasser raisonnablement (CE 1932 Compagnie des tramways de Cherbourg).

Lorsque ces conditions sont remplies, la théorie de l'imprévision produit une double conséquence.

D'une part, le cocontractant et l'administration doivent rechercher une solution pour adapter le contrat à la situation mais en cas d'échec, le cocontractant est en droit d'obtenir de l'administration une indemnité partielle car celle-ci ne couvre pas l'aléa normal rencontré dans l'exécution de tout contrat (entre 5 et 10 % des charges supplémentaires supportées par le cocontractant). Cette indemnisation limitée s'explique par le fait que l'événement en cause n'est pas imputable à l'administration contractante.

D'autre part, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat sous peine de perdre tout droit à indemnisation. En effet, la théorie de l'imprévision a pour but de permettre d'assurer la continuité du service public ou, plus généralement, la satisfaction de l'intérêt général puisqu'elle ne se limite pas aux délégations de service public.

Comme le montrent les différents arrêts cités, le contentieux lié au contrat est assez important.

Le droit à indemnisation du cocontractant

Théorie	Conditions	Montant de l'indemnisation
Théorie de l'équation financière du contrat – Modification unilatérale du contrat CE 1902 Compagnie nouvelle du gaz de Devillelez-Rouen – Résiliation unilatérale du contrat CE 1958 Distillerie Magnac Laval	– But d'intérêt général – Exlu pour : • les contrats dont les clauses sont définies entièrement par voie légale ou réglementaire • les clauses financières du contrat – But d'intérêt général	Intégrale
Fait du prince	– Modification du contrat par l'administration cocontractante mais à un autre titre que celui de partie au contrat – Caractère imprévisible de la mesure prise – Mesure particulière au contrat ou générale si elle affecte dans ce cas un élément essentiel du contrat	Intégrale

Théorie	Conditions	Montant de l'indemnisation
Sujétions imprévues	– Marché de travaux publics – Difficulté technique : • exceptionnelle • imprévisible • extérieure	Intégrale
Force majeure CE 1932 Compagnie des tramways de Cherbourg	Evènement : – extérieur – imprévisible – irrésistible	Intégrale
Imprévision CE 1916 Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux	Evènement : – extérieur – imprévisible – qui entraîne un bouleversement de l'économie du contrat temporairement	Partielle

SECTION 2. Le contentieux des contrats administratifs

Différents recours doivent être envisagés (1) qui donnent au juge administratif des prérogatives variables (2).

1. La nature des recours contentieux

Les litiges relatifs aux contrats peuvent donner lieu à un contentieux d'interprétation (1A) un plein contentieux (1B) ou un contentieux de l'annulation (1C).

1A. Le contentieux de l'interprétation

Il porte sur le sens à donner aux stipulations contractuelles, soit sur renvoi du juge judiciaire, soit à la demande des parties en cas de litige né et actuel. Seul un ministre peut former un recours en interprétation en dehors de tout litige né et actuel.

Plus souvent, le juge sera saisi d'un recours de plein contentieux (RPC).

1B. Le contentieux de pleine juridiction

C'est le contentieux par lequel les parties demandent au juge du contrat de statuer sur les litiges qui les opposent concernant la conclusion, l'exécution ou la disparition du contrat.

Dans un premier temps, le RPC a été ouvert aux « concurrents évincés » donc à des tiers au contrat afin de pouvoir demander l'annulation du contrat ou de certaines de ses clauses (CE ass 2007 Société Tropic Travaux Signalisation).

Récemment, le RPC a été élargi à tous les tiers susceptibles d'être lésés « de façon suffisamment directe et certaine » dans leurs intérêts par la passation ou les clauses du contrat (CE 2014 Département du Tarn et Garonne).

Excepté pour les marchés de travaux publics, le requérant doit saisir le juge d'une décision administrative (principe de la liaison du contentieux ou de la décision préalable) et être représenté par un avocat.

Le juge administratif peut aussi être saisi d'une demande d'annulation.

1C. Le contentieux de l'annulation

Le juge administratif peut être saisi par la voie du recours pour excès de pouvoir (1C1) ou du déferé préfectoral (1C2).

1C1. Le REP

En principe, les contrats administratifs sont exclus du champ du REP (a) mais il existe des exceptions (b).

≡ L'exclusion des contrats du champ du REP (a)

Il en résulte, d'une part, que le REP formé contre un contrat est irrecevable (CE 1985 Association les amis de la terre : une association ne peut pas former un REP contre un contrat conclu entre l'État et une société visant à réduire les pollutions causées par ses usines). Ceci parce que le REP doit être formé contre un acte unilatéral. Or, le contrat est un acte bilatéral. De plus, il existe pour les parties au contrat un recours parallèle (le RPC).

D'autre part, en application du principe de l'effet relatif des contrats (le contrat ne crée des droits et obligations qu'à l'égard des parties), un contrat ne peut pas être invoqué comme source de légalité à l'appui d'un REP formé contre un acte administratif unilatéral (CE 1988 Ministre chargé du plan c. Communauté urbaine de Strasbourg : la Communauté urbaine de Strasbourg ne peut pas contester la décision du Premier ministre décidant d'implanter le synchrotron à Grenoble en soutenant que cette décision viole le contrat de plan État-région qui prévoyait que l'État défendrait la candidature de Strasbourg). Il n'en va autrement que si les stipulations contractuelles invoquées ont acquis une valeur réglementaire (CE 1906 Syndicat des copropriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey- Tivoli à propos des clauses réglementaires d'une concession de service public).

Par exception, le REP est ouvert dans deux cas.

≡ Les exceptions (b)

Un REP peut être formé, d'une part, contre un « acte détachable » du contrat.

Il s'agit en premier lieu des actes relatifs à la conclusion du contrat qui peuvent être contestés par les parties mais plus par les tiers (CE 1905 Martin : REP formé par un conseiller général contre la délibération du conseil général décidant de conclure un contrat de concession de tramways).

Les concurrents évincés qui disposent désormais du RPC pour demander l'annulation du contrat ne sont plus recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes détachables (CE ass 2007 Société Tropic Travaux Signalisation). Cette solution a été élargie à tous les tiers susceptibles d'être lésés « de façon suffisamment directe et certaine » dans leurs intérêts par la passation ou les clauses du contrat (CE 2014 Département du Tarn et Garonne).

Ce sont également les actes relatifs à l'exécution ou la résiliation du contrat. Une distinction doit être opérée entre deux catégories de personnes. Les tiers peuvent former un REP contre les actes relatifs à l'exécution ou la résiliation du contrat (CE 1906 Syndicat des copropriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli). Les parties ne peuvent utiliser que le RPC contre les décisions concernant l'exécution ou la résiliation d'un contrat. Il existe, cependant, une exception pour les décisions d'exécution ou de résiliation des contrats à caractère réglementaire, c'est-à-dire dont les dispositions sont fixées par les lois ou règlements, tels les contrats d'embauche des agents publics.

D'autre part, les tiers peuvent former un REP contre :

- les clauses réglementaires d'un contrat administratif (CE 1996 Cayzeele : concession de service public) ;
- les contrats relatifs à l'organisation des services publics ;
- le contrat de recrutement d'un agent non titulaire car celui-ci est soumis à un statut préétabli. Le préfet peut également demander l'annulation d'un contrat.

1C2. Le déféré préfectoral

Le préfet peut déférer au juge administratif de sa propre initiative ou sur demande d'un tiers lésé les contrats des collectivités locales qui doivent lui être transmis tels les contrats d'emprunt et concessions.

Les contrats directement exécutoires sans transmission au préfet ne peuvent être déférés par le préfet que si celui-ci a été saisi en ce sens par un tiers lésé.

Le juge ainsi saisi dispose de différentes prérogatives.

2. Les pouvoirs du juge administratif

Le juge administratif peut interpréter un contrat (2A), y mettre fin (2B) ou accorder des dommages et intérêts (2C).

2A. Le pouvoir d'interprétation

Le juge administratif peut interpréter les dispositions d'un contrat dans le cadre du contentieux de l'interprétation dans la limite des questions qui lui sont posées par les parties.

Il peut également être amené à interpréter les stipulations du contrat lorsqu'il est saisi dans le cadre d'un autre contentieux que celui de l'interprétation.

Le juge administratif peut aussi décider qu'un acte juridique cessera de produire des effets.

2B. Le pouvoir de mettre fin à un acte juridique

Le juge administratif peut annuler (2B1) ou résilier (2B2) un acte juridique.

2B1 Le pouvoir d'annulation

Ce pouvoir lui permet de mettre fin à un acte avec effet rétroactif. Son étendue varie selon que le juge est saisi dans le cadre d'un RPC (a) ou d'un REP (b).

≡ Dans le cadre du RPC (a)

Le juge administratif peut annuler le contrat si celui-ci est entaché d'illégalité (c'est un moyen d'ordre public). L'illégalité d'une clause peut entraîner la nullité du contrat si elle présente un caractère essentiel dans la conclusion du contrat.

Cette illégalité peut résulter de la violation des règles de fond s'appliquant à la formation du contrat administratif, telles que l'absence de consentement des parties ; le vice du consentement suite à l'erreur, la violence ou le dol ; l'absence d'objet licite ou de cause.

L'illégalité peut également résulter du non-respect des règles de compétence ou de procédure comme la violation des règles de passation des marchés publics. L'annulation ne sera prononcée que s'il s'agit d'un vice d'une particulière gravité (CE 2009 Commune de Béziers).

S'agissant des mesures prises par l'administration contractante à la suite du contrat, le juge administratif ne peut pas les annuler si elles sont injustifiées mais seulement accorder des dommages- intérêts au cocontractant en cas de préjudice subi.

Ce principe admet, cependant, des exceptions pour :

- les décisions résiliant un contrat pour lequel le partenaire de l'administration a dû réaliser des investissements importants ;
- les mesures intéressant les contrats conclus entre deux personnes publiques en application de la loi du 2 mars 1982 et ayant pour objet l'organisation d'un service public ;
- les mesures de résiliation injustifiées pour lesquelles le juge ne peut pas les annuler mais peut ordonner à l'administration de reprendre les relations contractuelles à compter d'une date qu'il détermine (CE 2011 Commune de Béziers dit « Béziers II »).

Les pouvoirs du juge administratif sont moins étendus dans le cadre du REP.

≡ Dans le cadre du REP (b)

Le juge administratif saisi d'un REP ne peut pas annuler le contrat puisqu'il ne peut connaître que des REP formés contre un acte détachable du contrat. Si l'acte approuvant la conclusion d'un contrat est annulé, le tiers ou l'une des parties peut saisir le juge d'une injonction de prononcer la résolution du contrat (CE 2011 Soc. Ophrys).

Le juge administratif peut aussi résilier un contrat administratif.

2B2 Le pouvoir de résiliation

Il permet au juge de mettre fin au contrat pour l'avenir si la résiliation est demandée :

- par l'une des parties à titre de sanction pour manquement grave de l'autre partie à ses obligations contractuelles ;
- par l'une des parties ou un tiers à titre de sanction pour illégalité du contrat ;
- par le cocontractant suite à une modification unilatérale du contrat par l'administration entraînant un bouleversement de l'économie du contrat ;
- par le cocontractant en raison de la survenance d'un cas de force majeure.

Le juge administratif peut, enfin, condamner une partie à réparer les préjudices qu'elle a causés.

2C. Le contentieux de la réparation

Un contrat est susceptible de donner naissance à une responsabilité contractuelle (2C1), extra-contractuelle (2C2) et quasi-contractuelle (2C3).

2C1. La responsabilité contractuelle

Il peut s'agir d'une responsabilité pour faute. En effet, le cocontractant qui manque à ses obligations contractuelles commet une faute qui engage sa responsabilité. Sauf disposition contraire, une faute simple suffit à engager la responsabilité de la partie fautive.

La partie poursuivie ne peut s'exonérer qu'en cas de force majeure ou de faute de l'autre partie mais non, en principe, pour fait du tiers.

En cas de force majeure, de modification ou de résiliation du contrat dans un but d'intérêt général, de fait du prince, de sujétions imprévues ou d'imprévision, l'administration est tenue d'indemniser son cocontractant alors qu'elle n'a commis aucune faute.

La responsabilité contractuelle prévaut sur la responsabilité extra-contractuelle (CE 1972 Soc. Unitchadienne : une société dont une remorque a été détruite au cours d'un transport de munitions effectué pour l'armée ne peut pas invoquer la responsabilité de l'État sur le terrain de la responsabilité pour risque exceptionnel de voisinage car elle est liée à celui-ci par un contrat).

2C2. La responsabilité extra-contractuelle

En cas de nullité du contrat, par exemple, pour violation des règles de compétence, le cocontractant de l'administration peut invoquer la responsabilité délictuelle de cette dernière (CE 2007 Commune de Boulogne-Billancourt : le cocontractant dont le contrat a été annulé en raison d'une faute de l'administration peut prétendre au paiement du bénéfice que lui aurait assuré l'exécution du contrat).

L'administration peut également se prévaloir des règles de la garantie décennale (CE 1973 Trannoy). Un dernier type de responsabilité peut aussi jouer.

2C3. La responsabilité quasi-contractuelle

La théorie de l'enrichissement sans cause (action de in rem verso) permet au demandeur d'obtenir le remboursement des dépenses utiles qu'il a exposées s'il existe :

- un appauvrissement du demandeur ;
- un enrichissement du défendeur ;
- un lien de cause à effet entre l'appauvrissement et l'enrichissement ;
- une absence de juste cause à l'enrichissement ;
- une absence d'autre action à la disposition du demandeur.

La théorie a été retenue, par exemple pour les travaux ou services effectués en vertu d'un contrat qui a été annulé ou pour les travaux effectués en dehors de tout contrat.

À retenir

La formation des contrats administratifs porte parfois atteinte à la liberté contractuelle et à l'égalité entre cocontractants. Ainsi, le contrat doit être signé par l'autorité exécutive compétente et ne peut pas concerner certains domaines. De même, le choix du cocontractant est plus ou moins encadré selon la nature du contrat. Certaines clauses sont parfois imposées par l'administration et d'autres sont prohibées.

L'exécution d'un contrat administratif présente également certaines spécificités par rapport au droit commun. L'administration dispose d'un pouvoir de contrôle et de direction sur son cocontractant sanctionné par des sanctions à caractère pécuniaire ou pouvant amener à écarter le cocontractant. L'administration peut, même si aucune clause ne le prévoit, modifier ou résilier unilatéralement le contrat pour des motifs d'intérêt général sous réserve d'indemniser totalement le cocontractant. Ce dernier bénéficie également d'un droit à indemnisation plus ou moins large avec les théories du fait du prince, des sujétions imprévues, de l'imprévision et de la force majeure.

Le contrat administratif peut donner lieu à différents types de contentieux. D'abord, le juge administratif peut être amené à interpréter certaines dispositions du contrat. Ensuite, le juge administratif peut être saisi d'un contentieux de la légalité. Le REP n'est ouvert que contre les actes détachables du contrat avec une étendue variable selon que le requérant est un tiers ou une partie au contrat. Les tiers peuvent également former un REP contre les clauses réglementaires du contrat, les contrats relatifs à l'organisation des services publics et les contrats de recrutement des non-titulaires. Le RPC permet aux parties d'obtenir l'annulation ou la résiliation du contrat (disparition du contrat sans effet rétroactif). Enfin, le juge administratif peut accorder des dommages et intérêts sur un fondement contractuel, extra-contractuel ou quasi-contractuel.

* * *

Mais les moyens de l'administration ne s'arrêtent pas là. Au-delà de ses moyens juridiques, l'administration dispose pour mener son action de moyens plus matériels comme le domaine public (sous-titre 1), et de la possibilité de réaliser des travaux publics (sous-titre 2) et d'exproprier (sous-titre 3) afin d'accomplir ses missions.

TITRE 2. Les conséquences de l'action administrative : le principe de responsabilité

La responsabilité peut se définir comme l'obligation qui est faite à une personne de réparer le dommage causé à une autre. À l'origine, l'administration était irresponsable en vertu du principe selon lequel le souverain ne peut mal faire. Puis la responsabilité de l'administration a été reconnue selon des règles dérogatoires au droit commun dont l'application relève du juge administratif (TC 1873 Blanco). Il convient donc de préciser l'étendue (sous-titre 1) et les modalités de la responsabilité de l'administration (sous-titre 2).

SOUS-TITRE 1. L'étendue de la responsabilité de l'administration

En principe, seule une faute permet d'engager la responsabilité de l'administration (chapitre 1). Cependant, dans certaines hypothèses, la responsabilité de l'administration pourra être engagée même en l'absence de faute (chapitre 2).

CHAPITRE 1 La responsabilité pour faute

Il existe différents types de faute (section 1) qui peuvent parfois se rencontrer (section 2).

SECTION 1. Les différents types de faute

Le Tribunal des Conflits a décidé, à propos du recours du propriétaire d'un journal contre la saisie de ce journal par le Général commandant l'état de siège, que ce requérant entendait seulement contester cet acte de police et ne reprochait aucun fait personnel au militaire (TC 1873 Pelletier). C'est à partir de cette décision que l'on a distingué la faute de service (1), qui engage la responsabilité de l'administration devant le juge administratif, et la faute personnelle (2), qui permet d'engager la responsabilité de l'agent devant le juge judiciaire.

1. La faute de service

Toute faute de l'administration (1A) n'engage pas nécessairement sa responsabilité (1A).

1A. La notion de faute de service

Le commissaire du gouvernement Laferrière a défini la faute de service comme un « acte dommageable impersonnel qui révèle un administrateur plus ou moins sujet à l'erreur ». La faute de service peut résulter d'un acte administratif comme d'un acte matériel (par exemple, un accident de véhicule) et d'une action comme d'une abstention.

Des auteurs ont été tentés d'établir une classification des fautes de service.

Ainsi, Duez a établi une classification tripartite en distinguant le fonctionnement anormal du service, le retard dans le fonctionnement du service et l'absence de fonctionnement du service.

Odent distingue quant à lui la faute de service dont l'auteur est identifié de la faute de service qui reste anonyme.

Il faut parfois un certain degré de faute pour pouvoir engager la responsabilité de l'administration.

1B. La gradation des fautes de service

À la différence du droit civil où toute faute entraîne la responsabilité de la personne, en droit administratif, il existe plusieurs degrés dans la faute. À l'origine, il existait trois types de fautes de service : la faute simple, la faute lourde et la faute d'une exceptionnelle gravité. Cette dernière était requise pour engager la responsabilité des services psychiatriques, pénitentiaires et de recouvrement des créances publiques.

Depuis les années 60, il n'existe plus que deux types de fautes de service : la faute simple et la faute lourde.

Il est difficile de définir ces deux fautes. On peut juste préciser que la faute lourde est une faute plus grave que la faute simple.

En principe, une faute simple suffit pour engager la responsabilité de l'administration. Dans certains domaines, il faut une faute lourde.

Cette exigence d'une faute lourde peut être justifiée par trois considérations :

- la difficulté de l'action administrative ;
- son caractère régalien ;
- la prise en compte de l'intérêt des administrés. En effet, il arrive que des textes excluent la responsabilité de l'administration. Le juge décide que cette irresponsabilité ne joue qu'en l'absence de faute lourde. À la différence des deux premières hypothèses, l'instauration d'une faute lourde est ici favorable aux administrés. Cette prise en compte des intérêts du justiciable a conduit depuis une dizaine d'années à un abandon de la faute lourde (1B1) qui ne subsiste plus que dans quelques hypothèses (1B2).

1B1. Les domaines où la faute lourde a disparu

La faute lourde a disparu dans les domaines hospitalier (a), pénitentiaire (b). Son abandon dans le domaine de la police (d) est davantage discuté.

≡ Le service public hospitalier (a)

À l'origine, la jurisprudence distinguait entre l'organisation et le fonctionnement du service, où une faute simple suffisait pour engager la responsabilité de l'administration, et les actes médicaux, où il fallait une faute lourde. L'acte médical a été défini comme l'acte qui ne peut être effectué que par un chirurgien ou un médecin (diagnostic, thérapie...) ou qui ne peut être fait que sous leur contrôle comme par exemple une injection faite par une infirmière (CE 1959 Rouzet). Quant aux actes relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service, il s'agit, par exemple, des soins courants du patient.

Depuis 1992, le Conseil d'État a abandonné l'exigence d'une faute lourde pour les actes médicaux (CE 1992 V. : une faute simple suffit pour une anesthésie péridurale).

Cet abandon de la faute lourde a été étendu au domaine pénitentiaire.

≡ Le service pénitentiaire (b)

À l'origine, le Conseil d'État exigeait une faute d'une exceptionnelle gravité pour engager la responsabilité de l'État. Depuis 1958, il exigeait une faute lourde. Depuis 2003, une faute simple suffit (CE 2003 Chabba à propos du décès d'un détenu). Cet abandon de la faute lourde ne se limite pas au cas du décès d'un détenu (CE 2008 garde des Sceaux : vol et dégradation d'effets personnels d'un détenu).

Récemment c'est pour les services fiscaux que la faute lourde a été délaissée.

≡ Les services fiscaux (c)

La faute lourde ne s'appliquait que si deux conditions étaient réunies selon la jurisprudence (CE 1990 Bourgeois).

D'une part, le dommage devait concerner les procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt.

D'autre part, il fallait que la situation fiscale du contribuable présentait une difficulté particulière.

Certains auteurs considéraient que la faute lourde se justifie par la complexité de ce domaine. On peut cependant discuter cet argument. D'une part, parce que le droit fiscal n'est pas plus compliqué que d'autres branches du droit comme les marchés publics, par exemple. D'autre part, en admettant même qu'il existe une certaine complexité, elle est due à la multiplicité et à l'instabilité des textes fiscaux.

Autrement dit, c'est l'État qui est à l'origine de cette situation. Or, comme le dit un adage, « nul ne peut alléguer sa propre turpitude ».

Désormais une faute simple suffit à engager la responsabilité de l'État même si c'est une opération d'établissement ou de recouvrement de l'impôt qui est concernée : CE 2011 M. Krupa.

En matière de police, l'abandon de la faute lourde ne fait pas l'unanimité chez les auteurs.

≡ Les services de police (d)

Certains auteurs, distinguent deux types d'activité.

D'une part, les activités juridiques de police, qui, étant réalisées tranquillement derrière un bureau, ne présentent pas de difficultés particulières et pour lesquelles par conséquent une faute simple suffit

(CE 1966 Société des Films Marceau : l'illégalité de l'interdiction de la projection d'un film constitue une faute simple qui engage la responsabilité de la commune).

Au contraire, pour les actions matérielles de police, qui se déroulent sur le terrain, il faut une faute lourde compte tenu de leur difficulté (CE 1925 Clef : à propos d'une opération de maintien de l'ordre public dans la rue).

Cependant, on peut penser que la distinction se fait entre les activités de police difficiles et celles non difficiles, indépendamment de leur caractère juridique ou matériel. En premier lieu, la réglementation de

la circulation et du stationnement à Paris constitue une activité difficile exigeant une faute lourde alors qu'il s'agit d'une activité juridique (CE 1972 Marabout). De même, une activité matérielle qui ne présente pas de difficultés particulières engage la responsabilité de l'administration en cas de faute simple (CE 1951 Dame Aubergé : concernant une personne blessée par le coup de feu tiré par un CRS après avoir franchi un barrage qui était mal signalé). La plupart des auteurs continuent d'affirmer que la responsabilité des services de police sera engagée pour faute lourde si l'activité est jugée difficile.

On peut toutefois penser que la faute lourde a été abandonnée pour l'ensemble des activités de police puisque le Conseil d'État s'est contenté d'une faute simple dans de nombreuses hypothèses où l'activité pouvait être considérée comme difficile. Il en va ainsi pour les activités de secours (CE 1998 Commune de Hannapes : lutte contre l'incendie), la police spéciale du maire lui permettant d'interner d'office des aliénés mentaux (CE 1999 Société AGF), la police des bruits de voisinage (CE 2003 Commune de Moissy-Cramayel) ou encore la police spéciale des édifices menaçant ruine (CE 2006 Commune de Baalon).

Seules certaines activités continuent d'engager la responsabilité de la puissance publique qu'en cas de faute lourde.

1B2. Les domaines où la faute lourde reste exigée

Pour trois services publics la faute lourde reste encore d'actualité.

≡ Les services de contrôle

À l'origine, le Conseil d'État exigeait une faute lourde pour engager la responsabilité des services de contrôle. Puis le Conseil d'État a abandonné la faute lourde pour certaines activités comme le contrôle du licenciement des représentants syndicaux (CE 1984 Société Gallice) ou le contrôle technique des navires (CE 1998 Améon). Cependant, on ne peut pas en conclure que la faute lourde a été abandonnée pour l'ensemble des activités de contrôle puisqu'elle a été maintenue dans trois domaines :

- le contrôle de légalité des actes des collectivités locales (CE 2000 Commune de Saint-Florent),
- le contrôle des commissions bancaires sur les établissements de crédit (CE 2001 Kechichian),
- l'exercice par l'État de son pouvoir de mandatement d'office en cas de carence d'un établissement public ou d'une collectivité locale à assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ainsi que de son pouvoir de substitution d'office en cas de refus d'un maire d'exercer son pouvoir de police (CE 2007 Ministre de l'Intérieur et commune de Carcheto-Brutisco : absence de faute lourde dans l'absence de substitution d'office du préfet à un maire qui n'avait pris aucune mesure pour éviter la divagation du bétail).

≡ Les services postaux et de communication

Certaines dispositions du Code des Postes et des Télécommunications prévoient l'irresponsabilité de l'État, par exemple, pour la perte des correspondances ordinaires ou le dysfonctionnement des services téléphoniques à l'égard des tiers. Le Conseil d'État a limité cette immunité à l'absence de faute lourde (CE 1981 Madame Doublet). Depuis 1990, ce contentieux a été transféré au juge judiciaire mais les solutions restent identiques (Cour de Cassation 1998 Cabane).

C'est également le juge judiciaire qui connaît du contentieux relatif à la justice.

≡ Le service de la Justice

Une loi de 1972 prévoit qu'un dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire n'engage la responsabilité de l'État qu'en cas de faute lourde.

Le juge judiciaire définit la faute lourde comme résultant d'un fait ou d'une série de faits qui traduisent l'incapacité de la justice à remplir sa mission (Cour de Cassation 2001 Bolle et Laroche : une série d'anomalies dans l'instruction de l'affaire du petit Grégory constitue une faute lourde).

Dans un premier temps, la Cour de cassation refusait d'appliquer ce texte aux personnes qui n'avaient pas la qualité d'usager du service public de la justice. Les tiers sont désormais également concernés (Cass. 1^{re} civ. 2008 Consorts Jacquot : les ayants droit d'une personne qui s'est suicidée en prison sont recevables à agir en réparation de leur préjudice personnel pour faute lourde du service public de la justice). En revanche, les collaborateurs du service public de la justice relèvent d'un régime de responsabilité sans faute (Cass. 1^{re} civ. 1996 Morand : à propos d'un mandataire judiciaire).

Concernant la justice administrative, il n'existe pas de loi mais le Conseil d'État a adopté un principe général du droit selon lequel seule une faute lourde permet d'engager la responsabilité de l'État en cette matière. Celle-ci est toutefois écartée si la faute lourde résulte du contenu même de la décision juridictionnelle ou concerne une décision de justice définitive (CE 1978 Darmont). Toutefois, la responsabilité de l'État sera engagée pour faute lourde si le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (CE 2008 Gestas).

Par exception à ce principe, la responsabilité de l'État est engagée pour faute simple lorsque la requête du justiciable n'a pas été jugée dans un délai raisonnable (CE 2002 Magiera).

C'est parfois la responsabilité de l'agent qui peut être recherchée.

2. La faute personnelle

La faute personnelle a été définie par Laferrière comme celle « qui révèle l'homme avec ses passions, ses faiblesses et ses imprudences ». On peut distinguer la faute personnelle commise pendant le service (2A) et celle réalisée en dehors de celui-ci (2B).

2A. La faute personnelle commise pendant le service

La faute personnelle peut être une faute commise pendant le service mais qui s'en détache compte tenu de sa gravité.

Il s'agit, d'une part, des fautes intentionnelles telles que le détournement de fonds opéré par une receveuse des Postes (CE 1937 Demoiselle Quesnel) ou les actes de violence commis par un préposé des Postes sur un usager à qui il venait de remettre un colis (TC 1987 Kessler).

Il s'agit, d'autre part, des négligences importantes comme le tir à balles réelles sur des appelés du contingent ordonné par un officier (CE 1999 Moine) ou l'excès de zèle commis par le secrétaire général d'une préfecture dans l'arrestation et la déportation de juifs (CE 2002 Papon).

Il existe un autre type de faute personnelle.

2B. La faute personnelle commise en dehors du service

La faute personnelle peut, d'une part, être commise en dehors des fonctions mais avec les moyens du service. Tel est le cas du gardien de la paix qui tue l'un de ses collègues à son domicile en manipulant son arme de service (CE 1973 Sadoudi).

D'autre part, elle peut être dépourvue de tout lien avec le service (CE 1991 Société des Assurances Les Mutuelles Réunies : fait pour un pompier qui n'est pas en service d'allumer volontairement un incendie).

Il arrive parfois qu'interviennent en même temps une faute de service et une faute personnelle.

	Faute de service		Faute personnelle
Définition	Acte dommageable impersonnel qui révèle un administrateur plus ou moins sujet à l'erreur		Faute qui révèle l'homme avec ses passions, ses faiblesses et ses imprudences
	Faute lourde	Faute simple	
Illustrations	– Contrôle de légalité des actes locaux – Contrôle des établissements de crédits par les commissions bancaires – Exercice par l'État de son pouvoir de mandatement d'office ou de substitution d'office – Certains actes des services postaux et de communication – Justice judiciaire et administrative	Autres hypothèses	– Faute commise pendant le service mais qui s'en détache en raison de sa gravité compte tenu de son caractère intentionnel ou des négligences importantes commises – Faute commise en dehors du service avec des moyens du service ou sans aucun lien avec celui-ci
Effets	Responsabilité de l'administration et compétence du juge administratif		Responsabilité de l'agent devant le juge judiciaire

SECTION 2. Les hypothèses de cumul

À l'origine, la jurisprudence considérait que la faute de service et la faute personnelle étaient exclusives l'une de l'autre. Ensuite, le juge a accepté que les deux types de faute se rencontrent (1), ce qui a nécessité de revoir les relations entre l'administration et ses agents (2).

1. Du cumul de fautes au cumul de responsabilité

La jurisprudence a d'abord accepté le cumul de fautes (1A) puis le cumul de responsabilités (1B).

1A. Le cumul de fautes

C'est l'hypothèse où un dommage est dû à la fois à deux faits distincts, l'un constituant une faute de service et l'autre une faute personnelle. Dans cette hypothèse, la victime peut, au choix, demander réparation de l'ensemble de son dommage soit à l'administration devant le juge administratif, soit à l'agent devant le juge judiciaire (CE 1911 Anguet : M. Anguet est dans un bureau de Poste qui ferme avant l'heure réglementaire. Un agent lui conseille de sortir par une porte de service et, alors qu'il gagne cette porte, il est expulsé violemment par des agents de la Poste et a une jambe cassée. Son dommage est dû à la fois à une faute personnelle, la violence commise par les agents et à une faute de service, la fermeture prématurée du bureau de Poste).

Une autre hypothèse de cumul s'est dégagée.

1B. Le cumul de responsabilités

Il s'agit de la situation où un même fait à l'origine du dommage constitue à la fois une faute personnelle et une faute de service. Dans cette hypothèse, la victime peut également demander réparation de l'intégralité de son dommage soit à l'administration soit à l'agent (CE 1918 Époux Lemonnier : une commune organise une fête avec une épreuve de tir à proximité d'un chemin de randonnée. Des promeneurs inquiets ont averti le maire. Celui-ci prend des mesures qui s'avèrent insuffisantes puisqu'un promeneur va être blessé par une balle. Ce dommage est dû à une faute personnelle du maire puisque, averti du danger, il n'a pas pris les mesures qui s'imposaient. Mais il s'agit également d'une faute de service qui est la mauvaise organisation de cette activité).

Le cumul de responsabilités a été élargi à l'hypothèse où une faute personnelle est commise en dehors des fonctions mais avec un lien avec le service (CE 1949 Demoiselle Mimeur : un soldat cause un accident de véhicule alors qu'il utilisait à des fins personnelles un véhicule de l'armée qui lui avait été confié pour accomplir une mission). Cette évolution jurisprudentielle favorable à la victime fait que l'administration peut être condamnée à réparer l'ensemble d'un dommage alors qu'elle n'en est que

partiellement responsable (hypothèse du cumul de fautes) voire aucunement responsable (hypothèse de l'arrêt Mimeur). C'est pourquoi il a fallu revoir les relations entre l'administration et ses agents.

2. Les relations entre l'administration et ses agents

Il existe des droits réciproques de l'administration (2A) et de ses agents (2B).

2A. Les droits de l'administration à l'égard de ses agents

Dans l'hypothèse où il existe un cumul de fautes, la réparation doit être répartie entre l'administration et l'agent en proportion de la gravité de la faute (CE 1951 Delville : le dommage incombe pour moitié à l'État et pour moitié à l'agent à propos d'un accident de véhicule qui est dû à l'usure des freins, qui constitue une faute de service ainsi qu'à l'ivresse du chauffeur, faute personnelle).

L'administration peut demander à l'agent le remboursement de la totalité de la somme qu'elle a versée à la victime si l'agent est à l'origine de la faute de service (CE 1951 Laruelle : un militaire, par des manœuvres, arrive à induire en erreur le gardien d'un dépôt d'automobiles afin de pouvoir utiliser un véhicule sans ordre de mission. En utilisant ce véhicule, il cause un accident. La victime obtient la condamnation de l'administration pour faute de service (insuffisance de surveillance du garage d'automobiles). Comme c'est l'agent qui, par son comportement, est à l'origine de la faute de service, l'administration peut lui demander la totalité du remboursement). Autrement dit, la faute de service dont peut se prévaloir la victime ne peut pas être invoquée par l'agent.

Il en va de même dans l'hypothèse où il existe une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service. Le lien avec le service permet à la victime de demander réparation à l'administration mais ensuite cette dernière peut se retourner contre l'agent (CE 2008 Mazière : condamnation d'un appelé du contingent à rembourser à l'État la totalité des sommes versées par ce dernier suite aux conséquences de l'accident causé par le militaire

qui s'était écarté de l'itinéraire direct qu'il aurait dû suivre pour effectuer sa mission afin de retirer de l'argent d'un distributeur pour le compte d'un autre appelé qu'il avait pris à son bord sans autorisation. Ce détour « pour répondre à des fins privées constitue une faute personnelle »).

L'agent dispose également de certains droits.

2B. Les droits de l'agent contre l'administration

Si, dans l'hypothèse d'un cumul de fautes, la victime choisit de demander réparation à l'agent pour l'ensemble de son dommage, ce dernier peut ensuite se retourner contre l'administration pour demander le remboursement de la somme versée à la victime correspondant à la faute de service (CE 1951 Delville).

Dans l'hypothèse où un agent serait condamné pour faute personnelle par le juge judiciaire alors que le dommage est dû en fait à une faute de service, l'agent peut demander à l'administration le remboursement total de la somme versée à la victime. Ce principe a été posé pour les fonctionnaires par la loi de 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires.

Pour les agents qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire, il s'agit d'un principe général du droit (CE 1963 CHR de Besançon).

La responsabilité de l'administration peut également être engagée sans qu'elle ait commis de faute.

	Cumul de fautes	Cumul de responsabilités
Définition	Le dommage est dû à 2 faits distincts, l'un constitutif d'une faute de service, l'autre d'une faute personnelle	Un même fait à l'origine du dommage constitue à la fois une faute personnelle et une faute de service Faute personnelle commise en dehors des fonctions mais en lien avec le service
Effets	La victime peut demander réparation de l'intégralité de son dommage soit à l'administration devant le juge administratif, soit à l'agent devant le juge judiciaire	
Action de l'administration ou de l'agent initialement condamné suite au recours de la victime	Réparation finale répartie entre l'agent et l'administration en proportion de la gravité de la faute	
		Réparation finale incombant à l'agent en cas de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service

À retenir

La faute de service engage la responsabilité de l'administration et relève de la compétence du juge administratif. Elle a été définie comme un acte dommageable impersonnel qui révèle un administrateur plus ou moins sujet à l'erreur. En principe, une faute simple suffit à engager la responsabilité de l'administration.

Toutefois, dans certains domaines de plus en plus limités, il faut une faute lourde (certains services de contrôle, certaines activités des services postaux et de communication, le service de la justice). La faute personnelle engage la responsabilité de l'agent devant le juge judiciaire. C'est celle qui révèle l'homme avec ses passions, ses faiblesses et ses imprudences. Dans deux situations, la victime peut demander l'ensemble de la réparation de son dommage, soit à l'administration devant le juge administratif, soit à l'agent devant le juge judiciaire. La première est celle du cumul de fautes (le préjudice est imputable à deux faits distincts constituant l'un une faute de service, l'autre une faute personnelle). La seconde est celle du cumul de responsabilités (hypothèse où un même fait à l'origine du dommage est constitutif à la fois d'une faute de service et d'une faute personnelle et hypothèse où le dommage résulte d'une faute personnelle commise en dehors des fonctions mais en lien avec le service). Dans ces deux cas, l'administration ou l'agent initialement condamné à réparer l'entier préjudice dispose d'actions pour obtenir du juge administratif le remboursement des sommes versées correspondant à la part du dommage qui ne lui est pas imputable.

CHAPITRE 2 La responsabilité sans faute

Dans certaines hypothèses, la responsabilité de l'administration peut être retenue alors même qu'elle n'a commis aucune faute. Il existe deux fondements à cette responsabilité sans faute. Dans certaines hypothèses, la responsabilité s'explique par le risque que l'administration a fait courir aux administrés (section 1). Dans d'autres hypothèses, la responsabilité repose sur le principe d'égalité devant les charges publiques, c'est-à-dire que l'administration va faire supporter au nom de l'intérêt public à un individu une contrainte que ne supporteront pas les autres citoyens. Il est donc équitable, pour rétablir l'équilibre, de réparer le préjudice subi (section 2).

SECTION 1. La responsabilité pour risque

Si la responsabilité pour risque a d'abord été reconnue par le juge (1), elle a ensuite connu de nombreux prolongements législatifs (2).

1. Les hypothèses d'origine jurisprudentielle

La responsabilité pour risque a d'abord concerné les agents (1A) puis les tiers (1B) et, enfin, les usagers (1C).

1A. La responsabilité de l'administration à l'égard de ses collaborateurs

Il faut distinguer le cas des agents permanents (1A1) de celui des collaborateurs occasionnels du service public (1A2).

1A1. Les agents permanents

La responsabilité pour risque professionnel a été dégagée par le premier arrêt qui reconnaît l'existence d'une responsabilité sans faute (CE 1895 Cames : ouvrier d'un arsenal de l'État blessé par une projection métallique résultant d'un marteau-pilon). Cette jurisprudence est aujourd'hui rarement appliquée puisque les agents de l'État sont couverts soit par la législation sur les accidents du travail pour ceux qui n'ont pas la qualité d'agent public, soit par la législation sur les pensions pour les agents publics.

Cette législation sur les pensions prévoit une indemnisation forfaitaire pour les dommages corporels. Pendant longtemps, la jurisprudence a considéré que l'existence de ce forfait empêchait l'agent de demander une réparation supérieure à celle prévue par le forfait afin d'obtenir une réparation totale de son préjudice. Puis le Conseil d'État a changé sa jurisprudence.

Désormais, il y a réparation, sur le fondement du risque professionnel, des dommages non corporels (préjudice moral, esthétique...). En revanche, si l'agent veut obtenir pour son préjudice corporel une indemnisation supérieure à celle prévue par le forfait, il doit prouver une faute de l'administration (CE 2003 M^{me} Moya-Caville).

La jurisprudence Cames a inspiré la jurisprudence sur les collaborateurs occasionnels du service public.

1A2. Les collaborateurs occasionnels du service public

Lorsqu'un particulier est blessé en apportant une aide momentanée à un service public, il peut obtenir la réparation des dommages subis sans avoir à établir une faute de l'administration. Pour ce faire, il faut qu'il ait été apportée au service public (a) une collaboration qui revêt certaines formes (b).

L'existence d'un service public (a)

La jurisprudence est assez large pour reconnaître l'existence d'un service public. Ainsi, dès lors qu'un particulier lutte contre un incendie, il participe à un service public, même si la commune ne dispose pas du service de lutte contre l'incendie (CE 1943 Chavat).

La plupart des hypothèses de collaboration occasionnelle concernent les services de secours (CE 1957 Commune de Grigny : aide apportée à une personne victime d'une intoxication par le gaz).

En dehors des hypothèses de sauvetage, la collaboration occasionnelle au service public a été reconnue dans des hypothèses diverses (CE 1970 Consorts Appert-Collin : maire écrasé par son tracteur alors qu'il nivelait un terrain pour le transformer en terrain de sport).

Une collaboration revêtant certaines formes doit avoir été apportée à un service public.

L'existence d'une collaboration (b)

Concernant son origine, la collaboration peut être imposée par l'administration (Cour de Cassation 1956 Docteur Giry : réquisition d'un médecin pour déterminer les causes d'une intoxication au gaz).

Ensuite, la collaboration peut avoir été demandée ou acceptée par l'administration. Ici, le collaborateur éventuel peut refuser (CE 1946 Commune de Saint-Priest-la-Plaine : un maire demande à des habitants d'une commune de tirer le feu d'artifice pour le 14 juillet).

Enfin, la collaboration peut être apportée sans que l'administration en ait connaissance. Dans cette hypothèse, il faut que la collaboration réponde à une urgente nécessité (CE 1990 Commune de Couëron : il y a urgente nécessité à porter secours à des accidentés de la route).

Concernant son déroulement, la collaboration doit, d'une part, être effective (CE 1980 Gambini : l'individu qui assiste à l'interpellation d'une personne par des policiers sans leur prêter main forte ne collabore pas au service public).

D'autre part, il faut que la personne ne soit pas liée au service public à un autre titre que celui de collaborateur occasionnel. Ainsi, un agent du service public ne peut pas être collaborateur occasionnel (CE 2003 CPAM du Béarn : le médecin du SAMU qui est blessé dans la chute d'un hélicoptère qui se rendait sur les lieux d'un accident n'a pas la qualité de collaborateur occasionnel du service public). De la même façon, l'usager d'un service public n'est pas collaborateur occasionnel si le concours qu'il apporte n'excède pas les avantages qu'il retire du service public (CE 1961 Kormann : à propos d'une jeune fille qui est blessée en ramassant des balles lors d'une épreuve sportive organisée pour le baccalauréat).

Si la collaboration occasionnelle doit être gratuite, elle peut être rémunérée pour les requis et ceux qui interviennent dans le cadre de leur activité professionnelle (CE 2009 Chevillard à propos du pilote d'hélicoptère d'une entreprise de sauvetage ayant tenté de porter secours à des marins).

La jurisprudence Cames a trouvé des échos dans d'autres domaines.

1B. La responsabilité née des dangers administratifs

Il existe une responsabilité sans faute pour les risques liés aux objets (1B1) ou aux activités (1B2) dangereux.

1B1. Les choses dangereuses

Cette responsabilité est apparue avec les explosifs (CE 1919 Regnault-Desrozier : explosion d'un fort dans lequel étaient stockées des grenades).

Elle a été étendue aux armes et engins dangereux dans le domaine de la police. Pour que la responsabilité s'applique deux conditions sont exigées.

Il faut, d'une part, que l'arme ou l'engin, soit considéré comme dangereux. C'est le cas s'il s'agit d'une arme à feu (CE 1949 Lecomte et Daramy : passants blessés ou tués par des tirs au cours d'une opération de police).

D'autre part, la responsabilité sans faute ne concerne que les tiers par rapport aux opérations de police. Si le dommage touche la personne visée par l'opération de police, une faute simple doit être démontrée (CE 1951 Dame Aubergé : automobiliste touché par le tir d'un policier après avoir franchi un barrage).

La responsabilité pour risque concerne également les ouvrages publics exceptionnellement dangereux (CE 1973 Dalleau : la route du Littoral à la Réunion étant qualifiée d'ouvrage public exceptionnellement dangereux, l'usager qui a reçu une pierre sur son véhicule est indemnisé sans avoir à prouver de faute).

Parfois, ce n'est pas d'un bien de l'administration mais de son activité que vient le danger.

1B2. Les activités dangereuses

On peut distinguer les méthodes (a) des situations dangereuses (b).

≡ Les méthodes dangereuses (a)

Les mesures de liberté surveillée prévues par l'ordonnance de 1945 sur les mineurs délinquants engagent la responsabilité sans faute de l'État pour les dommages causés aux tiers en raison du « risque spécial » qu'elles leur font courir (CE 1956 Thouzellier : vols commis par des jeunes délinquants après qu'ils se soient échappés du foyer dans lequel ils étaient placés).

La responsabilité sans faute de l'organisme auprès de qui est placé un mineur se trouve également engagée sur le fondement de la garde à l'égard des tiers, dans la mesure où la « responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur » se trouve transférée à cet organisme (CE 2005 GIE Axa courtage : à propos de l'incendie allumé par des mineurs placés au titre d'une mesure d'assistance éducative prévue par l'article 375 du Code civil). La jurisprudence Axa courtage concerne aussi les usagers (CE 13 nov. 2009 garde des

Sceaux c. Asso. Tutélaire des inadaptés : autres enfants placés victimes des actes de leurs coréligionaires). Les auteurs sont divisés sur le fait d'affirmer que la garde constitue ou non un fondement autonome par rapport au risque.

La responsabilité pour risque spécial a été étendue aux dommages causés aux tiers par des aliénés mentaux lors de sorties d'essai (CE 1967 Département de la Moselle : incendie allumé par un fou lors d'une sortie d'essai) ainsi qu'aux permissions de sortie accordées aux détenus (CE 1981 Theys : meurtre commis par un détenu lors d'une permission).

La responsabilité sans faute a été également élargie à certains actes médicaux. Ce sont ici les usagers et non plus les tiers qui sont concernés. Il s'agit des actes médicaux pour lesquels il existe un risque connu mais dont la réalisation est exceptionnelle et où l'état du patient est sans rapport avec son état initial (CE 1993 Bianchi : s'agissant d'une artériographie où la probabilité d'accident est de 1/2500 et où la personne est sortie de l'hôpital totalement paralysée).

Certaines situations peuvent aussi présenter un risque.

≡ Les situations dangereuses (b)

Lorsque l'administration place une personne dans une situation dangereuse, elle doit en assumer les conséquences en l'indemnisant des préjudices subis (CE 1962 Perruche : pillage des biens du consul de France à Séoul alors qu'il avait reçu l'ordre de rester à son poste après que les troupes nord-coréennes aient envahi la ville ; CE 2007 Schwartz : infirmière qui a développé la sclérose en plaque après avoir été vaccinée contre l'hépatite B ainsi que l'y obligent les règles de sa profession).

Les travaux publics peuvent également donner naissance à une responsabilité sans faute.

1C. La responsabilité pour dommages accidentels de travaux publics

Le Conseil d'État a décidé que « le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement » (CE 2006 Commune de Bollène).

S'agissant des usagers, ils sont indemnisés sauf si l'administration prouve qu'elle a entretenu normalement l'ouvrage public (CE 1968 Dame Marron : spectatrice blessée en tombant dans les escaliers d'un théâtre mal éclairé).

La doctrine est divisée sur le fondement de la réparation. Certains auteurs considèrent qu'il s'agit d'une responsabilité pour faute présumée tandis que d'autres auteurs affirment qu'il s'agit d'une hypothèse de responsabilité sans faute.

C'est cette dernière analyse qu'a confirmée la jurisprudence (CE 1990 Université de Lille 1). D'autres hypothèses de responsabilité pour risque résultent de la loi.

2. Les hypothèses législatives

Le législateur a décidé d'indemniser le « risque social » (René Chapus) résultant d'infractions (2A), d'aléas thérapeutiques (2B) ou d'autres causes (2C).

2A. La réparation des dommages résultant d'une infraction

Les dommages résultant d'infractions commises lors d'un attroupement ou rassemblement (2A1), d'autres infractions (2A2) ou d'actes de terrorisme (2A3) sont indemnisés sur le fondement du risque.

2A1. La responsabilité de l'État du fait des attroupements ou rassemblements

Il s'agit d'une responsabilité prévue par la loi mais dont les conditions d'application (a) et le régime juridique (b) ont été précisés par la jurisprudence.

≡ Les conditions d'indemnisation (a)

Il faut, d'une part, que le dommage résulte d'un crime ou d'un délit (TC 1961 Dame Jean : une simple bousculade survenue lors d'un rassemblement ne constitue pas un crime ou un délit). Cependant, il ne faut pas que la manifestation ait eu pour but de commettre des crimes ou délits (CE 2000 AGF : la loi a été appliquée pour des pillages de magasins et des dégradations de véhicules commis par des jeunes après un rassemblement pour protester contre la mort de l'un de leurs camarades qui s'était noyé alors qu'il était poursuivi par la police pour un vol).

D'autre part, il faut que cette infraction ait été commise dans le cadre d'un attroupement ou d'un rassemblement. L'occupation d'une entreprise par ses salariés pendant une « longue période » (près d'un an en l'espèce) qui implique « l'organisation de permanence et la mise en œuvre concertée de moyens destinés à empêcher l'accès à l'établissement » ne constitue pas un attroupement ou un rassemblement (CE 2009 Soc. BDA).

Les règles applicables à cette situation ont évolué.

Le régime de l'indemnisation (b)

La personne responsable n'a pas toujours été la même.

À l'origine, la réparation incombait aux habitants de la commune dans laquelle les crimes et délits avaient été commis.

Cette réparation a été transférée aux communes par la loi de 1884 sur les responsabilités communales.

Puis une loi de 1914 a transféré la réparation à l'État, sauf dans certaines hypothèses où elle restait à la charge de la commune.

Enfin, depuis une loi de 1983, c'est l'État qui est responsable pour les crimes et délits commis lors des attroupements et rassemblements.

D'autre part, s'agissant de la compétence juridictionnelle, c'était le juge judiciaire qui était initialement compétent. En revanche, la compétence judiciaire est devenue une anomalie à partir du moment où la réparation a été transférée aux communes et à l'État qui sont des personnes publiques.

C'est pourquoi, depuis une loi de 1986, c'est le juge administratif qui est compétent en cas de litige relatif à l'application de cette loi.

Récemment, ce texte a été utilisé pour condamner l'État à réparer les dommages causés à une personne blessée au visage par un tir de flash ball lors d'échauffourées sur la place de la Bastille lors de la fête de la musique (elle n'était pas visée par le tir) dès lors que les policiers étaient victimes de jets de projectiles, constituant des délits commis par violence par attroupement (le TA n'a pas souhaité retenir le fondement de la responsabilité pour usage d'armes dangereuses invoqué par le demandeur) : TA Paris 2013 Clément Alexandre.

Une infraction commise dans d'autres circonstances peut également donner lieu à réparation sur le fondement du risque.

2A2. L'indemnisation des victimes de certaines infractions

C'est une loi de 1977 qui a institué une indemnisation au bénéfice de victimes de certaines infractions.

Il s'agit d'une réparation totale pour les atteintes aux personnes résultant, soit d'une infraction ayant entraîné la mort ou une incapacité de travail d'au moins un mois, soit d'un attentat aux mœurs ou d'une agression sexuelle.

D'autre part, la réparation est plafonnée pour la victime d'un dommage aux biens résultant d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance qui ne peut pas obtenir une réparation suffisante de son préjudice et qui se trouve ainsi dans une situation matérielle grave.

L'indemnité (réservée aux personnes à faibles ressources dans le second cas) est versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

2A3. L'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme

Cette indemnisation intégrale mise en place par une loi de 1986 est versée par le fonds précité et concerne les dommages aux personnes de toute nationalité victimes d'un attentat commis en France ou de nationalité française si l'acte de terrorisme est commis à l'étranger.

C'est également dans le domaine médical qu'ont été créés plusieurs fonds d'indemnisation.

2B. L'indemnisation des victimes d'aléas thérapeutiques

Depuis une loi de 1964, l'État est responsable des dommages résultant d'une vaccination obligatoire. Une loi de 1991 prévoit une possibilité d'indemnisation par un fonds des personnes qui ont contracté le SIDA lors d'une transfusion.

Une loi de 1988 crée une indemnisation pour les personnes victimes de recherches biomédicales pour lesquelles aucun bénéfice individuel direct n'était attendu.

L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM) mis en place par une loi de 2002 répare les incapacités permanentes d'au moins 24 % ou les incapacités temporaires supérieures à 6 mois résultant d'un accident médical lorsque la responsabilité des établissements de santé ne peut pas être engagée.

D'autres types de dommage sont également pris en charge par la solidarité nationale.

2C. Les autres régimes législatifs de responsabilité pour risque

Les dommages causés par l'armée en temps de paix suite à des manœuvres, exercices de tirs... sont indemnisés sur le fondement d'une responsabilité sans faute (loi de 1877, ordonnance de 1959).

Une loi de 1924 prévoit que les dommages causés à la surface du sol par les aéronefs engagent, sans faute à prouver, la responsabilité de leurs propriétaires.

Des lois de 1965 et 1968 instituent une responsabilité de plein droit pour les dommages causés par les exploitants d'installations nucléaires et de navires nucléaires.

Une indemnisation des victimes d'une maladie professionnelle ou d'un préjudice lié à une exposition à l'amiante par un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a été décidée en 2000. Cette indemnisation est exclusive de toute possibilité de recours juridictionnel.

La responsabilité sans faute de l'administration peut être engagée sur un autre fondement.

SECTION 2. La responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques

Les travaux publics (1), les activités régulières de l'administration (2) ainsi que les lois et traités (3) sont concernés par cette responsabilité.

1. La responsabilité pour dommages prévisibles de travaux publics

Cette hypothèse s'intitule ainsi pour être distinguée du dommage accidentel de travaux publics. L'expression de « dommage permanent » souvent employée est moins appropriée car le dommage ne revêt pas toujours un caractère définitif (Conseil d'État 1931 Commune de Vic-Fezensac : absence de réparation de la gêne occasionnée au riverain d'une place publique par la chute sur son toit des feuilles des arbres ornant cette place car il s'agit d'une obligation normale de voisinage ; CE 1992 Société bac Montalembert : indemnisation pour le bruit et la difficulté d'accès à un hôtel résultant de la construction d'un parc de stationnement. Cet arrêt montre que le dommage peut ne pas être permanent).

Les actes réguliers de la puissance publique peuvent également engager sa responsabilité.

2. La responsabilité du fait des activités administratives régulières

Il arrive parfois qu'une activité matérielle (2A) ou juridique (2B) de l'administration, bien que régulière, engage sa responsabilité.

2A. Les activités matérielles

Elles peuvent engager la responsabilité de l'administration même en dehors de toute faute (CE 1926 Sieur Walter : le fait qu'un feu allumé par les pompiers sur ordre du maire pour enrayer le développement d'une épidémie se soit propagé à un immeuble voisin engage la responsabilité de la commune).

Il en va de même pour des actes administratifs légaux.

2B. Les activités juridiques

La responsabilité de l'administration peut être engagée pour les actes administratifs individuels (2B1) ou réglementaires (2B2) légaux.

2B1. Les actes administratifs individuels

Ce sont les actes qui concernent une ou plusieurs personnes déterminées. On peut distinguer les décisions d'abstention (a) des décisions positives (b).

≡ Les décisions d'abstention (a)

Lorsque l'administration refuse pour des motifs liés à l'ordre public d'utiliser la force publique pour exécuter une décision de justice ou un acte administratif, cette abstention peut entraîner la responsabilité de l'administration si elle est génératrice d'un préjudice pour le particulier ainsi « sacrifié » sur l'autel de l'intérêt général (CE 1923 Couitéas : le propriétaire de terrains en Tunisie, occupés par des indigènes, obtient une décision de justice prononçant leur expulsion. L'administration coloniale refuse le concours de l'armée pour appliquer cette décision, compte tenu des massacres que cela aurait engendrés. Le refus d'utiliser la force publique est légal mais M. Couitéas a droit à une indemnisation pour rupture d'égalité devant les charges publiques).

≡ Les décisions positives (b)

Une décision positive légale de l'administration engage sa responsabilité dans les mêmes conditions que précédemment (CE 1995 Lavaud : décision d'un office public de HLM de supprimer dix immeubles dans le quartier des Minguettes à Lyon, ce qui a eu pour effet d'entraîner une forte diminution du chiffre d'affaires d'un pharmacien).

Cette responsabilité a ensuite été étendue aux actes administratifs réglementaires.

2B2. Les actes administratifs réglementaires

Ce sont des actes de nature générale et impersonnelle. Ils engagent également la responsabilité de l'administration en l'absence de faute de celle-ci si l'acte est générateur d'un préjudice indemnisable (CE 1963 Commune de Gavarnie : pour accéder au cirque de Gavarnie, il existait deux chemins étroits. Le maire de la commune a pris un arrêté qui réservait l'un des chemins aux piétons. Un commerçant, situé sur l'autre chemin, a subi une perte de son chiffre d'affaires puisque les piétons s'arrêtaient plus facilement dans sa boutique. L'arrêté pris par le maire est légal mais le commerçant a droit à une indemnité).

Le dommage peut également trouver sa source dans d'autres actes.

3. La responsabilité du fait des lois et des conventions internationales

Le juge administratif accepte de réparer les conséquences dommageables d'une loi (3A) ou d'une convention internationale (3B).

3A. La responsabilité du fait des lois

La responsabilité de l'État ne sera retenue que si une loi impose une charge (3A1) et qu'elle n'a pas exclu une réparation (3A2).

3A1. Une loi imposant une charge

La responsabilité du fait des lois concerne toutes les mesures de nature législative :

- loi ordinaire (CE 1938 Soc. des produits laitiers La Fleurette : interdiction de la fabrication de tout produit pouvant remplacer la crème naturelle et ne provenant pas exclusivement du lait) ;
- ordonnance prise sur le fondement de l'ancien article 92 de la Constitution (CE 1963 Bovero : interdiction de l'exécution des jugements prononçant l'expulsion de leur logement des familles de militaires servant en Afrique du nord) ;
- loi constitutionnelle (CAA Paris 2003 Mme Demaret : article 76 de la Constitution qui restreint le corps électoral pour la ratification des accords de Nouméa).

La charge doit résulter de la loi elle-même (CE 2010 M. Abolivier : le préjudice résultant de la perte de valeur des actions de la société UTA ne résulte pas de la loi de 1994 modifiant les statuts de cette société mais de la décision d'Air France d'être absorbée par cette société et des mauvais résultats du nouveau groupe créé).

La volonté du législateur est également prise en considération.

3A2. Une loi n'excluant pas une indemnisation

La responsabilité de l'État ne peut pas être retenue lorsqu'il résulte que la volonté du législateur est d'écarter cette responsabilité.

Pendant un temps, le juge administratif considérait que si la loi avait pour objet un intérêt général prééminent (santé publique, environnement...), elle traduisait la volonté implicite du législateur d'exclure toute indemnisation.

Cette solution est aujourd'hui abandonnée (CE 2003 Association pour le développement de l'aquaculture en région Centre : pisciculteurs victimes des dommages causés par des cormorans protégés par une loi de 1976 relative à la protection de la nature).

Le Conseil d'État a également décidé que le silence du législateur sur une possible indemnisation n'exclut pas, par principe, celle-ci (CE 2005 Soc. coopérative agricole Ax'ion : à propos de la fermeture des silos d'une coopérative sur le fondement de la loi sur les établissements dangereux).

Le Conseil d'État a, par ailleurs, condamné l'État à indemniser le particulier victime d'une loi inconstitutionnelle (loi contraire à un traité) en retenant comme fondement les « obligations » de l'État « pour assurer le respect des conventions internationales » (CE 2007 Gardedieu : à propos d'une loi de validation qui méconnaît l'article 6-1 de la CEDH reconnaissant le droit à un procès équitable). Le fondement de l'indemnisation n'est donc pas ici le principe d'égalité devant les charges publiques.

La jurisprudence Gardedieu a été étendue aux lois méconnaissant les PGD de l'UE (CE 2014 SEPR : si la responsabilité de l'État peut être engagée du fait d'une loi qui méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, tel ne peut pas être le cas lorsqu'une société se plaint de l'interprétation donnée par la Cour de cassation à un article du Code du travail manquant selon elle de clarté car « elle critique ainsi non pas la loi elle-même mais la portée qui lui a été ultérieurement conférée par la jurisprudence »).

La responsabilité sans faute a été étendue aux traités internationaux.

3B. La responsabilité du fait des traités

Le principe d'une telle responsabilité a été reconnu en 1966 (CE 1966 Compagnie générale d'énergie radio électrique : une société réquisitionnée par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale demande réparation à l'État du préjudice causé par un traité reportant à plus tard l'examen des créances liées au problème des réparations à la charge de l'Allemagne).

En revanche, la responsabilité sans faute de l'État pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ne peut pas être retenue pour « les actes pris par les organes de la Communauté européenne » ou « les actes par lesquels les autorités nationales se bornent, sans disposer d'aucun pouvoir d'appréciation, à en assurer la mise en œuvre » (CE 2003 Soc. Gillot).

La responsabilité sans faute pour les conventions internationales est comme celle pour les lois « un produit de luxe » selon l'expression du professeur Chapus. Elle a été retenue notamment pour ceux privés de recours contre une personne qui bénéficie d'une immunité diplomatique (CE 2011 Melle Susilawati). Dans ce dernier arrêt, le Conseil d'État réintroduit expressément la condition de l'incorporation régulière dans l'ordre juridique interne de la convention posée en 1966.

Responsabilité sans faute fondée sur le risque	Responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques
Régimes d'origine jurisprudentielle	Responsabilité pour dommage prévisibles de travaux publics
Les collaborateurs occasionnels du service public : Particulier participant à une mission de service public sur réquisition, sollicitation ou spontanément en cas d'urgente nécessité et non lié à un autre titre au service public	Responsabilité du fait des actes administratifs réglementaires – Actes matériels – Actes juridiques › Actes administratifs individuels + décisions d'abstention + décisions positives › Actes administratifs réglementaires
Les dangers administratifs – Les choses dangereuses › Explosifs (tiers) › Armes et engins dangereux (tiers) › Ouvrages publics exceptionnellement dangereux (usagers) – Les méthodes dangereuses › Liberté surveillée (tiers) › Mineurs placés (tiers et usagers) › Sorties d'essai des aliénés (tiers) › Permissions de sortie des détenus (tiers) › Actes médicaux à risques exceptionnels (usagers) – Situations dangereuses (agents)	Responsabilité du fait des Lois et des Traités
Les dommages accidentels de travaux publics (tiers et usagers)	
Régimes d'origine légale	
Dommage résultant d'une infraction – Responsabilité de l'État du fait des attroupements et des rassemblements – Atteintes aux personnes ou aux biens résultant de certaines infractions – Victimes d'actes de terrorisme Victimes des aléas thérapeutiques Autres régimes légaux – Dommages causés par l'armée en temps de paix – Dommages causés par les aéronefs au sol – Dommages causés par les explosions d'installations nucléaires – Victimes de l'amiante	

À retenir

La responsabilité de l'administration peut être retenue alors même qu'elle n'a commis aucune faute. Il existe deux fondements à cette responsabilité sans faute. Dans certaines hypothèses, la responsabilité s'explique par le risque que l'administration a fait courir aux administrés. Le juge administratif a créé cette responsabilité pour les collaborateurs de l'administration puis l'a étendue aux dangers administratifs résultant de choses ou activités dangereuses mises en œuvre par l'administration puis aux dommages accidentels de travaux publics. Le législateur a également instauré des régimes de responsabilité pour risque concernant principalement les victimes de certaines infractions ou d'aléas thérapeutiques. Dans d'autres hypothèses, la responsabilité repose sur le principe d'égalité devant les charges publiques car l'administration a fait peser au nom de l'intérêt général sur un individu une contrainte que ne supporteront pas les autres citoyens. Tel est le cas pour les dommages prévisibles de travaux publics, les activités administratives régulières, les lois et les traités.

SOUS-TITRE 2. Les effets de la responsabilité de l'administration

La réparation n'interviendra qu'à certaines conditions (chapitre 1) et peut revêtir différentes formes (chapitre 2).

CHAPITRE 1 Les conditions de la réparation

Les caractères (section 1) et origines (section 2) du préjudice peuvent conduire à ce que l'administration ne soit pas tenue de réparer un dommage.

SECTION 1. Les caractères du préjudice

Le préjudice doit répondre à certaines conditions qui sont communes (1) ou non (2) aux régimes de responsabilité pour faute et sans faute.

1. Les caractères communs aux deux régimes de responsabilité

Pour donner lieu à réparation le préjudice doit être certain (1A) et appréciable en argent (1B).

1A. Un préjudice certain

Un préjudice certain est un préjudice sûr, réel, évident.

Par exemple, si un étudiant a reçu tardivement son diplôme, il ne peut pas demander réparation du fait qu'ainsi il n'a pas pu trouver un emploi puisque rien ne garantissait son recrutement. En revanche, il y a un préjudice certain qui est la perte d'une chance de trouver un travail (CE 1987 Legoff).

Un préjudice futur peut être certain si sa réalisation ne fait aucun doute (CE 1982 Hospice civil de Lyon : renouvellement de l'appareillage orthopédique d'un enfant).

Le préjudice doit également pouvoir être évalué en argent.

1B. Un préjudice appréciable en argent

Cette condition ne pose pas de difficulté pour les préjudices corporels ainsi que pour les dommages aux biens. Une expertise permet au besoin de les chiffrer avec exactitude.

Les préjudices moraux ont donné lieu à une indemnisation plus tardive qui couvre aujourd'hui leurs différentes formes :

- douleur physique (le mal éprouvé suite à un accident) ;
- préjudice esthétique (plaies au visage...) ;
- troubles dans les conditions d'existence (les perturbations dans la vie de tous les jours comme le fait de ne plus pouvoir faire de vélo pour un sportif amateur) ;
- douleur morale (le chagrin éprouvé par une personne suite à la disparition d'un proche). Certaines conditions relatives au préjudice sont spécifiques à chaque régime de responsabilité.

2. Les caractères propres à chaque régime de responsabilité

Le préjudice doit présenter des caractères qui varient selon que s'applique un régime de responsabilité pour faute (2A) ou sans faute (2B).

2A. Les conditions relatives à la responsabilité pour faute

En principe, la responsabilité pour faute est une responsabilité pour faute prouvée, c'est-à-dire, qu'il appartient au requérant d'établir que son préjudice a pour origine une faute commise par l'administration.

Cependant, dans certaines hypothèses, il existe une présomption de faute. Ce sont les cas où les circonstances de survenance du dommage ne peuvent s'expliquer que par la réalisation d'une faute.

Ainsi lorsqu'un malade sort d'un établissement hospitalier dans un état pire que celui dans lequel il est entré, son état « révèle » qu'une faute a été commise (CE 1962 Meier : injection intra veineuse ayant provoquée la paralysie d'un membre).

Le Conseil d'État a créé une nouvelle hypothèse de présomption de faute dans le cas de la violation du secret professionnel par l'aide sociale à l'enfance (CE 2012 Consorts B).

La plupart des auteurs affirment qu'une telle présomption existe également à l'égard des usagers des ouvrages publics. Pour de tels dommages, la jurisprudence retient la responsabilité de l'administration sauf si celle-ci établit l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage. Cependant, on peut plutôt penser que, dans cette hypothèse, il ne s'agit pas d'un régime de responsabilité pour faute présumée mais plutôt d'un régime de responsabilité sans faute ainsi que l'a expressément affirmé le Conseil d'État (CE 1990 Université de Lille 1).

D'autres conditions concernent la responsabilité sans faute.

2B. Les conditions relatives à la responsabilité sans faute

Il faut un préjudice anormal. La définition (2B1) et l'étendue (2B2) de cette condition font débats.

2B1. La notion d'anormalité

Selon certains auteurs le préjudice doit revêtir deux caractères :

- être anormal ce qui inclut la gravité du préjudice ;
- être spécial, c'est-à-dire limité à quelques personnes.

D'autres auteurs regroupent la spécialité et la gravité sous le terme d'anormalité. La doctrine diverge également sur le champ d'application de ces conditions.

2B2. Le champ d'application de l'obligation d'anormalité du préjudice

Certains auteurs affirment que l'existence d'un préjudice anormal et spécial est exigée pour tous les régimes de responsabilité sans faute.

D'autres limitent cette exigence aux régimes fondés sur la rupture d'égalité devant les charges publiques.

Le juge exige un préjudice anormal dans certaines hypothèses se rattachant à la responsabilité pour risque (CE 1993 Bianchi : la paralysie résultant d'une artériographie cérébrale est un préjudice dont « la réalisation est exceptionnelle » (une victime sur 2 500 examens) et d'une « extrême gravité »).

Mais c'est essentiellement dans les régimes fondés sur la rupture d'égalité devant les charges publiques que le Conseil d'État a refusé d'indemniser le requérant au motif que son préjudice n'était pas spécial et / ou grave (CE 1966 Compagnie générale d'énergie radio électrique : en raison du nombre

important de personnes concernées par le traité reportant l'examen des créances sur l'Allemagne suite à l'occupation, il n'y a pas de spécialité du préjudice).

L'origine exacte du préjudice doit également être recherchée.

SECTION 2. L'imputabilité du préjudice

Pour obtenir réparation, la victime doit établir un lien de causalité (1) et il ne doit pas exister de causes d'exonération (2).

1. Un lien de causalité

Le préjudice doit résulter d'une activité administrative (1A) et le requérant doit demander réparation de ce préjudice à l'administration responsable de cette activité (1B).

1A. Un lien avec une activité administrative

Le préjudice doit avoir son origine directe dans un acte ou un fait imputable à l'administration (CE 1905 Tomaso Grecco : la personne blessée par un coup de feu lors de la tentative de capture d'un taureau qui s'était échappé ne peut obtenir de réparation de l'État dès lors qu'il n'est pas établi que le tir peut être attribué à un gendarme ; CE 2007 M^{me} P : une aide-soignante vaccinée contre l'hépatite B dans le cadre de son activité professionnelle qui a contracté une sclérose en plaques n'établit pas le lien entre sa maladie et cette vaccination obligatoire dès lors que les symptômes de cette maladie s'étaient développés chez elle avant la vaccination).

Il faut également actionner le bon responsable.

1B. Le rattachement de l'activité au responsable

La victime doit identifier la personne publique responsable de l'activité incriminée (CE 1988 Le Goff : lorsqu'une personne porte secours à un malade mental qui s'est échappé d'un hôpital psychiatrique et qui se noie dans un étang, elle ne collabore pas au service public hospitalier mais au service public de la police administrative puisque la commune a la responsabilité des secours à porter aux personnes en danger sur son territoire).

Lorsque certains événements sont à l'origine du dommage, la responsabilité de l'administration pourra disparaître ou être atténuée.

2. Les causes d'exonération

Certaines causes sont communes aux deux régimes de responsabilité (2A) et d'autres sont spécifiques à l'un ou l'autre (2B).

2A. Les causes communes

La faute de la victime (2A1) et la force majeure (2A2) peuvent supprimer ou atténuer la responsabilité de l'administration qu'elle soit fondée ou non sur la faute.

2A1. La faute de la victime

Lorsque la victime a contribué exclusivement ou en partie à la réalisation de son dommage, la responsabilité de l'administration ne pourra pas être engagée ou ne le sera que partiellement (CE 1921 Commune de Montségur : un enfant qui a la jambe sectionnée par la chute d'un bénitier auquel il

s'est suspendu est seul responsable de son dommage et donc ses parents ne peuvent pas demander réparation à la commune ; CE 1988 ONF : un véhicule dont la roue a été endommagée après avoir roulé dans un trou situé sur la chaussée n'engage la responsabilité de l'État que pour 50 % car si le dommage est dû à l'absence de signalisation du trou par la DDE, il est dû aussi au fait que la victime roulait trop vite).

La force majeure constitue l'autre circonstance exonératoire en matière de responsabilité pour faute ou sans faute.

2A2. La force majeure

Elle est traditionnellement définie par les auteurs comme un événement extérieur, imprévisible dans sa survenance et irrésistible dans ses effets (CE 1986 Commune du Val d'Isère : une avalanche d'une violence exceptionnelle ne constitue pas un cas de force majeure car 3 autres avalanches ont déjà eu lieu au même endroit ; CE 1987 Société des grands travaux de Marseille : l'administration n'est pas responsable du débordement d'un canal puisque celui-ci est dû à la conjonction exceptionnelle d'une pluviométrie importante, d'une crue de la Garonne et de fortes marées).

Deux autres événements peuvent également dispenser l'administration de réparation.

2B. Les causes spécifiques à la responsabilité pour faute

Deux événements n'ont un effet exonératoire que lorsque la responsabilité de l'administration est engagée sur la base d'une faute : le fait du tiers (2B1) et le cas fortuit (2B2).

2B1. Le fait du tiers

Il s'agit de l'acte imputable ni à l'administration poursuivie ni à la victime (CE 1996 Ville de Cilaos : la commune de Cilaos n'est responsable que pour un tiers du décès de collégiens qui se sont noyés lors d'un cyclone en tentant de traverser un radier submergé car le maire aurait dû prendre des mesures pour empêcher les enfants de quitter le collège. Un tiers du dommage est dû à l'État qui n'a pas surveillé suffisamment les élèves).

Le cas fortuit est plus rarement retenu.

2B2. Le cas fortuit

Le cas fortuit est un événement qui comme la force majeure est imprévisible et irrésistible mais qui n'est pas externe à l'administration (CE 1971 Ville de Fréjus : rupture d'un barrage due à l'expulsion de la roche de l'ouvrage sous la pression de l'eau).

La réparation obéit à des règles bien définies.

Les causes d'exonération

Les causes d'exonération	Responsabilité pour faute	Responsabilité sans faute
Faute de la victime : fait imputable à la victime	Oui	Oui
Force majeure : événement extérieur, imprévisible et irrésistible	Oui	Oui
Fait du tiers : fait imputable ni à la victime, ni à l'administration	Oui	Non
Cas fortuit : fait interne à l'administration, imprévisible et irrésistible	Oui	Non

À retenir

Pour donner lieu à réparation le préjudice doit être certain (réel) et appréciable en argent. S'il s'agit d'un régime de responsabilité pour faute, la victime devra établir que le préjudice résulte d'une faute de l'administration sauf dans quelques cas où il existe une présomption de faute. Dans les cas de responsabilité sans faute, la victime doit démontrer que son préjudice est grave et spécial (limité à quelques personnes). La victime doit également veiller à demander réparation à la personne publique responsable de l'activité incriminée. Si le dommage trouve son origine dans une faute de la victime ou un cas de force majeure, la réparation pourra être réduite ou supprimée. Il en ira de même pour les régimes de responsabilité pour faute si le dommage est dû à un fait du tiers ou un cas fortuit.

CHAPITRE 2 Les modalités de la réparation

L'évaluation du dommage (section 1) et la nature de la réparation (section 2) peuvent être faites de différentes façons.

SECTION 1. L'évaluation du préjudice

Le moment (1) et la façon (2) dont sera évalué le préjudice sont déterminés par le juge.

1. La date d'évaluation du préjudice

S'agissant des dommages causés aux biens, le préjudice est évalué à la date de la survenance du dommage.

Pour les dommages aux personnes, le préjudice est évalué le jour où le juge statue depuis 1947 (CE 1947 Veuve Aubry).

L'évaluation du préjudice doit, en principe, être faite dans une demande adressée à l'administration.

2. Le chiffrage du préjudice

La victime ne peut pas saisir directement le juge, elle doit d'abord lier le contentieux, c'est-à-dire, demander à l'administration la réparation de son dommage et le chiffrer.

Il y a cependant une exception pour les dommages trouvant leur origine dans un ouvrage public ou des travaux publics, où la victime peut directement saisir le juge.

La réparation peut prendre différentes formes.

SECTION 2. La nature de la réparation

En principe, la réparation se fait par équivalent, c'est-à-dire, en argent : l'administration est condamnée à verser à la victime des dommages et intérêts sous la forme d'un capital ou plus rarement d'une rente. Toutefois, si l'administration le souhaite, elle peut effectuer une réparation en nature (reconstruire un mur détruit, par exemple).

Le droit à une réparation intégrale du préjudice donne droit également aux paiements des intérêts.

Les intérêts moratoires sont ceux qu'aurait perçus la victime en cas de placement de l'indemnité principale depuis le jour de la condamnation.

Ils sont calculés au taux de l'intérêt légal.

Les intérêts compensatoires sont ceux qui résultent du retard du paiement en raison de la mauvaise volonté du débiteur.

Les intérêts capitalisés sont les intérêts produits par les intérêts en cas de non-paiement. Ils sont dus au bout d'un an et chaque année et doivent être demandés par la victime.

À retenir

Le préjudice est évalué au moment de la survenance du dommage pour les biens et le jour où le juge statue pour les personnes. Préalablement, la victime doit saisir l'administration d'une demande chiffrée de réparation à l'exception du domaine des travaux publics. La réparation se fait, en principe, en argent mais peut parfois être en nature et elle inclut les intérêts.